**LICENCE 2E ANNEE**

**2026-2027**

# DROIT ADMINISTRATIF

# Semestre 1

## FASCICULE DE TRAVAUX DIRIGES


**Cours de BENJAMIN DEFOORT**

***Professeur à CY Cergy Paris Université***


Equipe pédagogique :

- Yassine Benyettou, vacataire
- Clémence Billard, Enseignante-chercheuse contractuelle
- Mohamed Chaouachi, Doctorant, vacataire
- Clara Damage, ATER
- Adèle Kauffmann, ATER
- Bastien Petit, doctorant contractuel
- Ludovic Risselin, Doctorante, vacataire
- Sara Rodrigues, Elève avocate, vacataire
- Diabelly Sambake, Doctorante, vacataire

Programme des séances :

Séance n° 1 : Méthodologie
Séance n° 2 : La notion de service public
Séance n° 3 : Le régime du service public (cas pratique)
Séance n° 4 : La notion de police administrative
Séance n° 5 : Le régime de la police administrative (cas pratique)
Séance n° 6 : Les sources constitutionnelles
Séance n° 7 : Les sources internationales (cas pratique)
Séance n° 8 : Correction du Galop d'Essai
Séance n° 9 : Les limites du principe de légalité
Séance n° 10 : La répartition des compétences juridictionnelles (cas pratique)

Bibliographie indicative :


- Y. Gaudemet, *Droit administratif*, 26e éd., LGDJ, « Manuel », 2026.
- P. Delvolvé, *Le droit administratif*, Dalloz, « Connaissance du droit », 8e éd., 2024.
- G. Dumont, J. Sirinelli, *Droit administratif*, 16e éd., Dalloz, « HyperCours », 2025.
- P.-L. Frier, J. Petit, *Précis de droit administratif*, Montchrestien, 29e éd., 2026.
- B. Seiller, *Droit administratif* (t. 1 : Les sources et le juge ; t. 2 : L'action administrative), Flammarion, 10e éd., 2025.
- P. Weil, D. Pouyaud, *Le droit administratif*, PUF, « Que Sais-Je ? », 27e éd., 2024.
- B. Plessix, *Droit administratif général*, LexisNexis, 6e éd., 2026.


Les principales décisions du Conseil d'État et du Tribunal des Conflits auxquelles le cours fait référence sont accessibles sur leurs sites internet respectifs ; pour les plus importantes, elles également reproduites et commentées dans l'ouvrage suivant :


- M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, *Les grands arrêts de la jurisprudence administrative* (GAJA), Dalloz, 25e éd., 2025.

# SEANCE N° 1 :
# METHODOLOGIE

## I/ Considérations générales

- Avant tout, les notions fondamentales abordées en première année, et notamment dans le cadre du cours d'institutions administratives, sont réputées comprises et assimilées. Vous êtes donc invités à vous reporter, en tant que de besoin, à vos cours de L1.

- Ensuite, il est attendu de vous, lors de chaque séance de travaux dirigés, que :
    - Vous ayez intégralement lu la partie du cours correspondant au thème de la séance de TD de la semaine ;
    - Vous ayez lu intégralement le fascicule de travaux dirigés dans la partie correspondant au thème de la séance ;
    - Vous ayez travaillé, et au besoin fiché, l'ensemble des documents qui composent cette partie ;
    - Vous ayez préparé l'exercice demandé et soyez en mesure de remettre une copie à votre chargé de TD ;
    - Vous soyez en mesure de participer oralement de façon active et constructive lors de la séance.

- Enfin, les travaux dirigés ont pour but d'approfondir les connaissances vues en cours (et non de s'y substituer). Le TD n'est donc pas un second cours ; il a pour fonction de vous préparer à l'examen. Cela suppose, d'une part, que vous travailliez parallèlement le contenu du cours et des documents qui composent les fiches de travaux dirigés, et d'autre part, que vous prépareriez chaque semaines les exercices qui vous seront donnés et qui constituent autant d'entraînements pour l'examen terminal. Cet examen proposera, au choix, un sujet théorique (dissertation) et un sujet pratique (cas

pratique). Il vous incombe de maîtriser aussi bien l'un que l'autre de ces deux exercices.

## II/ Conseils méthodologiques sommaires

### A/ La dissertation

Plus encore que de se faire comprendre, ou de montrer qu'on a compris, l'objectif dans tout exercice de type « dissertation » est de convaincre son lecteur et de le « prendre par la main ». S'agissant d'une dissertation, il faut faire plus qu'une synthèse de ce qui a pu être lu sur un sujet donné (ce n'est pas une question de cours) : il s'agit de développer une idée – une thèse – et une argumentation sur un sujet donné. Les développements, organisés dans un plan, sont la réponse argumentée et étayée à la problématique que vous aurez identifiée en introduction et qui, selon vous, est au cœur du sujet donné.

*1°) Travail préparatoire*

- Il faut aller du plus simple au plus complexe (mobilisation des connaissances et délimitation du sujet)
- Mais attention à l'ordre dans lequel vous travaillez : le piège est de voir un thème à travers un sujet et se précipiter pour noter au brouillon tout ce qu'on connaît sur le thème en essayant de tout caser…
    - D'abord : analysez le sujet et ses termes. Il peut exister mille sujets sur un même thème qui appelleront différentes manières de les traiter efficacement. Commencez donc par définir les termes et ainsi circonscrire ce qui pourrait vous paraître sujet à difficulté.
    - Répondez au sujet : ne vous bornez pas à traiter le thème. Vous risqueriez de vous retrouver à devoir faire une synthèse bancale, et à vous forcer à essayer de faire rentrer vos connaissances dans le sujet. C'est l'analyse du sujet, de ses termes et de la manière dont ils sont agencés (et faites-vous confiance sur ce point) qui va commander la construction de la problématique.
    - Ce n'est que dans un second temps, une fois un début de problématique en main (un angle d'attaque) que vous pourrez commencer à mobiliser l'ensemble de vos connaissances pour voir où elles peuvent utilement s'intégrer dans votre discours.

*2°) Plan*

La construction du plan est très importante : elle traduit la clarté de la pensée et la problématisation de la réflexion.

Il n'existe pas de plan-type ! Les corrigés qui vous seront proposés ne sont que des exemples de plans cohérents et satisfaisant aux exigences à la fois formelles et substantielles de l'exercice et du sujet donné. Mais il est bien entendu toujours possible qu'un plan adopté par un étudiant soit tout aussi bon. L'important étant, bien entendu, de toujours motiver son choix.

- **Toujours ...**
    - répondre au sujet, c'est-à-dire tout le sujet mais rien que le sujet.
        - Lors de la rédaction de chaque partie, vous devez vous demander : en quoi ce que j'écris répond au sujet ?
    - construire le plan de façon à ce qu'il existe un lien entre les parties (ex : complémentarité, opposition, nuance, condition, parallélisme entre 2 aspects).
    - reprendre le libellé exact du titre dans l'annonce de plan.
    - espacer sa présentation
    - respecter une symétrie et une homogénéité dans la formulation des intitulés (autant que possible).
    - structurer chaque partie et chaque sous-partie : intégrer systématiquement un « chapeau introductif » après un titre (preuve d'une construction cohérente du déroulement logique de votre pensée) ; marquer un alinéa pour chaque idée ; rédiger une transition entre chaque partie et chaque sous-partie.
    - rédiger les intitulés de manière à exprimer une idée ou porter une appréciation (qualifier les titres).
        - Pas de titre : A/ La loi B/ La jurisprudence.

- **Ne jamais ...**
    - écrire de titre trop long.
    - utiliser des couleurs différentes (interdiction ABSOLUE ! le collège c'est fini !)
    - rédiger un titre sous forme de phrase avec un verbe conjugué.
    - écrire un titre en bas de page.
    - opter pour un plan dont les intitulés forment une seule phrase entrecoupée de points de suspension.

3°) *Introduction*

- Faire une accroche (rattachez le sujet à un problème général ou d'actualité et évoquer en quoi le sujet donné peut l'illustrer, le contredire, etc.).
    - Attention, l'accroche est un exercice difficile : mieux ne pas faire d'accroche et attaquer directement les termes du sujet plutôt que de faire une accroche bancale ou hors de propos.
- Définir les termes du sujet ; élément de contexte ; définir les enjeux du sujet (pourquoi le sujet vous a-t-il été posé ? ; identifier une problématique ; annonce de plan)
    - La problématique est une question ; l'annonce du plan est la réponse argumentée à cette question
    - La problématique n'est pas que la reformulation du sujet ! La problématique est la question qui fait que le sujet est intéressant et n'appelle pas de réponse évidente en deux lignes.
        - C'est parce qu'il est possible de trouver une problématique que le sujet que l'on vous donne n'est pas simplement une question de connaissance dans un QCM.

<u>B/ Le cas pratique</u>

Le cas pratique est un exercice délicat qui nécessite une certaine maturité juridique. Mais c'est l'exercice fondamental en droit. Il se réduit à un travail de qualification : c'est-à-dire la capacité à traduire juridiquement une situation de fait donnée.

La méthode est essentielle dans un cas pratique : c'est l'ESSENTIEL même (bien plus que la solution, c'est le raisonnement juridique qui est attendu).

2 impératifs doivent être respectés :

- <u>Décomposez</u> les problèmes juridiques (si plusieurs questions se posent ou si une question appelle l'examen de plusieurs éléments)
- Et <u>structurez</u> votre devoir en conséquence (pas besoin de plan apparent pour autant, mais il faut une structure claire et simple)

1° Dans la forme, les exigences minimales (oubliez notamment le sacro-saint plan en deux parties, structurez librement votre copie, MAIS STRUCTUREZ-LA !).

2° Dans le fond, il convient de respecter, pour chaque question isolée, le syllogisme juridique sur chaque question, votre raisonnement doit prendre la forme canonique du syllogisme juridique. 1/ On sait que… 2/ Or, …. 3/ Donc…

- Majeure : règle de droit (+ le cas échéant, solution du problème précédent lorsque plusieurs questions sont en lien).
    - Loi
    - Jurisprudence
    - Interprétation de la règle (de la loi par le juge, et le cas échéant, de la jurisprudence par vous)
    - La règle étant parfois obscure ou incomplète, vous devrez dans certains cas argumenter pour défendre l'interprétation de la règle de droit que vous proposez.
    - La règle de droit permet d'identifier une catégorie juridique (la définition d'une notion) et le régime juridique de cette catégorie.

- Mineur : situation de fait du cas qui vous est soumis (à ce stade, il est très important de s'attacher à présenter les faits de la manière la plus juridique possible → c'est là que réside le travail de qualification juridique).
    - C'est dans le travail de qualification juridique que consiste bien souvent le cas pratique, c'est ici que vous devez faire preuve d'intelligence et d'argumentation.
    - Doit résulter de la règle de droit (et notamment de son interprétation par le juge, voire par vous en cas d'absence de règles suffisamment précises) et sa confrontation avec la situation de fait, une ARGUMENTATION vous permettant d'établir (ou non) si la situation de fait rentre dans la catégorie juridique identifiée dans la règle.
    - J'insiste vous DEVEZ ARGUMENTER au stade de l'interprétation et de la qualification juridique (application du fait au droit): car la qualification juridique ne résulte pas de la logique mécanique (sinon, nous n'aurions plus besoin de juge et nous pourrions nous contenter de confier nos litiges à des ordinateurs).
    - Le travail (ou méthode) de qualification juridique peut se faire en 2 temps :
        - Quelles sont les alternatives proposées (quelles sont les catégories juridiques raisonnablement envisageables) ? Identifiez bien l'alternative (2, 3 ou plus de branches) qui se pose à vous.
        - Quelle est la bonne selon vous ; vous devez justifier votre choix.

- Conclusion : résulte de l'application du droit à ces faits
    - Il faut toujours conclure un cas pratique, même si vous avez un doute, même si une alternative a été ouverte.
    - Vous devez toujours indiquer la (ou les) raison(s) vous ayant conduit à privilégier telle ou telle solution.

Il faut que votre construction, et que votre raisonnement, traduisent clairement cette structure. Quitte à être un peu « lourd » au début, il faut vraiment montrer que l'on suit ce chemin.

# SEANCE N° 2 :
# LA NOTION DE SERVICE PUBLIC

**Cours de BENJAMIN DEFOORT**
***Professeur à CY Cergy Paris Université***

Liste des documents :

- Document n° 1 : CE, Sect., 27 octobre 1999, *Rolin* : Rec., p. 327, concl. A. Daussun ; *AJDA*, 1999, p. 1008, chron. P. Fombeur et M. Guyomar ; *RDP*, 2000, p. 269, note G. Eckert
- Document n° 2 : CE, ord., 5 octobre 2007, n° 298773, *Sté UGC-CINÉ-CITÉ* (extrait), Rec., p. 418
- Document n° 3 : TC, 21 mars 2005, *Alberti-Scott* : *AJDA* 2005, p. 964 ; *JCP G* 2005, IV, 2084 ; *DA*, 2005, comm. n° 94 ; *RFDA* 2006, p. 119, obs. J.-F. Lachaume
- Document n° 4 : D. Truchet, « Renoncer à l'expression "service public" », *AJDA* 2008, p. 553 ;
- Document n° 5 : G. Marcou, « Maintenir l'expression et la notion de "service public" », *AJDA* 2008, p. 833

Exercice : Dissertation

*

## Document n° 1 : CE, Sect., 27 octobre 1999, *Rolin*

Vu 1°) sous les n° 171169 et 171170 les requêtes enregistrées le 20 juillet 1995, présentées par M. Philippe ROLIN, demeurant 16, rue des Tanneurs à Lagny-sur-Marne (77400) ; M. ROLIN demande que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir les règlements des jeux instantanés, dénommés "Banco" et "Bingo", édictés le 30 mai 1995, par le président-directeur général de La Française des Jeux ;
- ordonne le sursis à exécution des ces décisions ;
- condamne la société "La Française des Jeux" à lui verser les sommes de 2 000 F et 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°) sous le n° 172384 la requête enregistrée le 1er septembre 1995, présentée par M. Philippe ROLIN, demeurant 16, rue des Tanneurs à Lagny-sur-Marne (77400) ; M. ROLIN demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite par laquelle le président-directeur général de La Française des Jeux a rejeté sa demande tendant à retirer de la vente les billets en circulation des jeux dénommés "Tac au Tac", "Millionnaire" et "Bingo" émis à compter du 17 mars 1995, date de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui a annulé l'article 3 du décret n° 87330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale ;
- condamne la société "La Française des Jeux" à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
(…)

*Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des décisions :*

Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 : "Dans le délai d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi, le gouvernement fixera par décret les conditions d'organisation et les modalités d'une loterie dont le produit sera, après prélèvement d'une somme de 100 millions, affecté à la caisse de solidarité contre les calamités agricoles, rattaché selon la procédure des fonds de concours au chapitre 14 du budget des pensions (retraites de combattant) dont le crédit sera réduit à due concurrence" ; qu'en application du décret du 9 novembre 1978 pris sur le fondement de ces dispositions, le gouvernement a confié l'organisation et l'exploitation de cette activité de loterie à la société "La Française des Jeux", laquelle a le caractère de personne morale de droit privé ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions législatives précitées ni des caractéristiques générales des jeux de hasard que la mission dont la société "La Française des Jeux" a été investie en application du décret du 9 novembre 1978 revête le caractère d'une mission de service public ; qu'ainsi les décisions prises par le président-directeur général de ladite société n'ont pas le caractère d'actes administratifs ; que dès lors, les conclusions de M. ROLIN tendant à l'annulation, d'une part, des décisions prises le 30 mai 1995 par le président-directeur général de La Française des Jeux au sujet des jeux instantanés dénommés "Banco" et "Bingo" et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté sa demande tendant à ce que soient retirés de la vente les billets des jeux dénommés "Tac au Tac", "Millionnaire" et "Bingo" émis à compter du 17 mars 1995, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; […]

DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 171169, 171170 et 172384 de M. ROLIN sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. [...]

## **Document 2 : CE, ord., 5 octobre 2007, n° 298773, *Sté UGC-CINÉ-CITÉ* (extrait)**

(…) Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...) et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement.../ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société d'économie mixte « Palace Epinal » , qui exploite à Epinal un cinéma composé de six salles, a demandé le 19 janvier 2006 à la commission départementale d'équipement cinématographique des Vosges l'autorisation d'ouvrir un nouveau multiplexe de dix salles, pour remplacer le précédent, autorisation qui lui a été délivrée le 24 avril 2006 ; que la SOCIETE UGC-CINE-CITE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à ce qu'il soit ordonné à la ville d'Epinal d'organiser une procédure de passation de la délégation du service public de spectacle cinématographique respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence préalable ;

Considérant qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu 'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si la société d'économie mixte « Palace Epinal », qui n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique, a, en vertu de ses statuts, une mission d'intérêt général en vue d'assurer localement l'exploitation cinématographique, son activité, eu égard notamment à l'absence de toute obligation imposée par la ville d'Epinal et de contrôle d'objectifs qui lui auraient été fixés, ne revêt pas le caractère d'une mission de service public confiée par la commune, qui n'avait ainsi à consentir aucune délégation à cet égard ; qu'il suit de là que le juge des référés n'a pas entaché d'erreur de droit son ordonnance, laquelle est suffisamment motivée, en jugeant que le projet de création de salles de la société d'économie mixte ne relevait pas de la procédure de délégation de service public ;

Considérant que le juge des référés n'a pas considéré qu'il ne pouvait être saisi dans la mesure où la personne publique s'est abstenue de mettre en œuvre une procédure de délégation conforme aux exigences légales mais a jugé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le projet de la société d'économie mixte «Palace Epinal » n'était pas réalisé dans le cadre d'une délégation de service public ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE UGC-CINE-CITE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy (…)

D E C I D E :
Article 1er : La requête de SOCIETE UGC-CINE-CITE est rejetée (…)

## **Document n° 3 : TC, 21 mars 2005, *Alberti-Scott AJDA***

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 février 2004, l'expédition du jugement du 10 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de Mme Olympia X tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 1996 par le maire de Tournefort (Alpes-Maritimes) pour obtenir remboursement des frais de pose d'un compteur d'eau, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 24 février 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 10 mars 2004, le mémoire présenté par Mme X, qui s'en remet à la sagesse du Tribunal des conflits sur la question de compétence ; Vu, enregistré le 16 juin 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que le litige concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune de Tournefort, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié (…)

Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant que le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial ; qu'il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service ; qu'en revanche le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager ;

Considérant que la commune de Tournefort, qui exploite en régie un service de distribution d'eau non doté d'un budget annexe, prélève à ce titre sur les usagers une redevance tenant compte de leur consommation

d'eau mesurée par les compteurs installés à l'initiative de la commune ; qu'ainsi, ce service présente un caractère industriel et commercial, nonobstant la circonstance que ces redevances ne couvriraient qu'une faible partie du coût annuel du service ; que, par suite, le litige opposant Mme X à la commune de Tournefort au sujet du remboursement de la pose d'un compteur d'eau concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X à la commune de Tournefort.
Article 2 : Le jugement du 24 février 1998 du tribunal de grande instance de Nice est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 octobre 2003.

## **Document n° 4 : D. Truchet, « Renoncer à l'expression "service public" », *AJDA* 2008, p. 553.**

Le moment est sans doute venu de bannir l'expression « service public » de notre vocabulaire juridique. C'était impensable il y a dix ans car, en renonçant au mot, on aurait aussi abandonné la chose, c'est-à-dire la place du service public dans l'architecture du droit administratif et son rôle essentiel pour l'« interdépendance sociale » (Duguit) : cela aurait été juridiquement, politiquement et socialement inacceptable.

Mais le droit français est aujourd'hui mûr pour le remplacer dans son vocabulaire par « service d'intérêt général ». La législation et la jurisprudence françaises ont fait évoluer le service public pour qu'il soit euro-compatible. Le droit communautaire a rendu le service d'intérêt général franco-compatible. La modification par le traité de Lisbonne de l'article 16 du traité de Rome, désormais appelé « traité sur le fonctionnement de l'Union européenne », et surtout le protocole n° 9 sur les services d'intérêt général sont de nature à lever nos dernières réticences, notamment grâce à la reconnaissance des services non économiques d'intérêt général à côté des services d'intérêt économique général.

Cette manifestation symbolique de convergence des droits communautaire et français n'aurait pas seulement l'avantage de mettre fin à une querelle de mots qui n'a plus d'objet. Elle améliorerait l'intelligibilité interne de notre droit. L'expression « service public » couvre des réalités si diverses et supporte tant de pesanteurs historiques qu'elle n'a plus guère de valeur juridique explicative. « Service d'intérêt général » est plus précis et plus exact : il met l'accent sur la mutation du service public en obligations d'intérêt général comportant dans la seule mesure nécessaire les droits exclusifs ou spéciaux, les aides ou les prérogatives de puissance publique dont a besoin l'opérateur pour s'en acquitter convenablement sous le contrôle de la collectivité publique.

Je le répète : ce changement sémantique n'est envisageable que parce que le service d'intérêt général est aujourd'hui apte à promouvoir les valeurs essentielles de justice sociale et d'efficacité économique qui

caractérisaient le service public. Il le fait d'une manière plus réaliste que ce dernier en termes de marché et mieux ajustée à la diversité des besoins. L'expérience du service universel que nous avons acquise avec la poste et les communications électroniques le confirme.

Le service d'intérêt général paraît apte aussi à remplacer presque mot pour mot le service public dans les raisonnements du droit administratif. Parler d'intérêt général, c'est réaffirmer l'objectif fondamentale de ce dernier. Nos méthodes d'identification ne seraient pas bouleversées : le service d'intérêt général n'est pas moins un « label » que le service public (sans doute l'est-il même davantage en raison de l'approche sectorielle privilégiée par l'Union européenne). Associé en tant que de besoin à la puissance publique et dans le respect de la concurrence, il peut servir à qualifier les actes, les agents, les biens, les travaux etc. comme le service public dans ses derniers avatars.

J'avoue cependant une hésitation : il faudrait utiliser aussi les expressions « service d'intérêt économique général » (celui qui fonctionne comme « l'industriel ordinaire » du bac d'Eloka ?) et « service non économique d'intérêt général ». Or elles sont lourdes et, pire, fallacieuses, car même à objet économique, un service d'intérêt général poursuit des objectifs sociaux. Mais, après tout, « spa » et « spic » (qui ne recouvrent pas exactement la distinction communautaire), ce n'était pas enthousiasmant non plus, et plus très clair...

## **Document n° 5 : G. Marcou, « Maintenir l'expression et la notion de "service public" », *AJDA* 2008, p. 833.**

Dans la tribune du 24 mars, Didier Truchet propose que le droit français renonce à l'expression « service public », au motif que la notion de « service d'intérêt général » du droit communautaire incorpore, après le traité de Lisbonne, le contenu de la notion traditionnelle de service public.

Il s'agit au contraire d'une raison de plus de maintenir l'expression et la notion de service public. En effet, le droit communautaire fait droit aujourd'hui à la notion de service public dans ce qu'elle a d'universel, malgré les mises en cause doctrinales dont elle fait l'objet dans divers pays, notamment en Italie et en Espagne. Quant à sa fonction, la notion de service public est bien l'expression de l'« interdépendance sociale » ; quant à son contenu, elle correspond à la détermination par les pouvoirs publics de l'offre (niveau et/ou caractéristiques du service offert) en fonction du niveau de satisfaction des besoins qu'ils estiment nécessaires d'assurer (cf. G. Marcou *in* F. Moderne et G. Marcou (dir.), *L'idée de service public dans le droit des Etats de l'Union européenne*, L'Harmattan, 2001, p. 386 et s.). Telle est la réalité du service public dans tous les pays, que sa notion trouve place ou non dans leur système juridique. Mais, précisément, aucune autre doctrine juridique que celle du service public, n'a pu donner à cette réalité une expression aussi synthétique et aussi forte. C'est ce qui explique son succès dans de nombreux pays européens, dans l'ensemble de l'Amérique

latine (cf. J.-L. Salomoni, *Teoria general de los servicios publicos*, Buenos Aires, 1999) et même aujourd'hui en Russie (*Les services publics et le droit*, Institut de législation et de droit comparé, Moscou 2007, p. 383 et s., en russe) et qu'elle ait surmonté toutes les « crises » qui, selon bien des auteurs, la condamnaient.

Peut-on prétendre que la notion de « service d'intérêt économique général », inscrite au détour d'un chapitre sur les règles de concurrence (aujourd'hui art. 106-2 du traité de Rome), et celle de « service d'intérêt général » que la Commission en a déduite soient plus claires et précises que la notion de service public ? C'est la jurisprudence de la Cour de justice qui en a précisé les contours et le régime, tout comme le Conseil d'Etat n'a cessé de le faire avec la notion de service public, et récemment encore avec ses grands arrêts de 2007. La notion de service public n'est pas moins adaptée au nouveau contexte de marché ; les juristes savent bien qu'il s'agit d'une notion matérielle, et non organique, qu'elle est apparue dans un contexte d'économie de marché, et pour Duguit les services publics constituaient aussi la limite de l'intervention de l'Etat ; le service public ne s'identifie ni à l'administration ni au monopole. Enfin, l'approche sectorielle privilégiée jusqu'ici par la Commission européenne justifie plus que jamais le recours à une vision globale qui donne un sens aux dispositions particulières.

Or, la notion de service public, bien plus que celle de service d'intérêt général, peut être reconnue comme une notion scientifique, en raison de l'importance de l'élaboration doctrinale à laquelle elle a donné lieu et de ses liens avec la théorie de l'Etat, avec les progrès de la garantie juridique des droits fondamentaux et avec l'économie des fonctions collectives. Les notions du droit communautaire - service d'intérêt général, service universel - peuvent être analysées au contraire à la lumière de la notion de service public telle qu'on l'a rappelée, comme peuvent l'être des notions en usage dans d'autres pays dont le système juridique ne connaît pas la notion de service public, comme par exemple en Allemagne la *Daseinsvorsorge* (les services nécessaires à la vie de la collectivité) ou aux Etats-Unis les *Public Utilities*. Pourquoi devrait-on alors renoncer à l'avantage d'en avoir fait une notion fondamentale du droit public positif ?

# SEANCE N° 3 :
# LE REGIME DU SERVICE PUBLIC

Liste des documents :

- Document n° 1 : CE, 27 septembre 2006, *François Bayrou et a.*, *AJDA* 2006, p. 2056, chr. C. Landais et F. Lenica, *RFDA* 2006, p. 1147, concl. E. Glaser, note R. De Bellescize
- Document n° 2 : CE, ass., 31 mai 2006, *Ordre des avocats au barreau de Paris*, n° 275531.
- Document n° 3 : CE. Sect., 20 novembre 1964, *Ville de Nanterre*, *AJDA* 1964, p. 705.
- Document n° 4 : CE Ass. 9 novembre 2016, *Fédération de la libre pensée de Vendée*, req. n° 395223.
- Document n° 5 : CE, 29 juin 2023, *Association Alliance Citoyenne et autres, Ligue des droits de l'homme*, n° 458088, 459547, 463408.
- Document n° 6 : CE, ass., 5 mai 2026, Fédération des acteurs de la solidarité et autres, n° 502860 (extraits)

Exercice : Cas pratique

*

## Document n° 1 : CE, 27 septembre 2006, *François Bayrou et a.*

(…) Considérant, en deuxième lieu, que le Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958, prévoit en son neuvième alinéa que tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ; que l'article 20 de la loi du 6 août 1986 modifiée rappelle en conséquence, en son deuxième alinéa, que les opérations de transfert qu'il régit ne peuvent concerner les entreprises visées par ces dispositions ; que l'exploitation d'une entreprise ne peut avoir les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait au sens de ces textes que si elle est exercée à l'échelon national ; qu'en l'espèce, aucune des sociétés dont s'agit, chargées de la construction et de l'exploitation de réseaux autoroutiers selon le régime prévu à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, ne s'est vu attribuer de concession, à l'échelon national, pour l'ensemble des autoroutes ; qu'il ne résulte d'aucun principe, d'aucune règle de valeur constitutionnelle, ni d'aucune loi que l'exploitation des concessions autoroutières doive être érigée en service public national ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUTOROUTIER n'est pas fondée à soutenir que le Premier ministre a, par les décrets attaqués (décrets de privatisation des autoroutes), méconnu la portée des dispositions précitées ;

## **Document n° 2** : CE, ass., 31 mai 2006, *Ordre des avocats au barreau de Paris*

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, dont le siège est 11, place Dauphine à Paris cedex 01 (75053) ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
*Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;*

Considérant que l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ratifiée par la loi du 9 décembre 2004 de simplification administrative, dispose dans son article 2 que : Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation : a) Montre ou bien que, compte-tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d'urgence ; b) Expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposé peut être succinct./ L'évaluation est réalisée avec le concours d'un organisme expert choisi parmi ceux créés par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat : Il est créé un organisme expert chargé de procéder en liaison avec toute personne intéressée à l'évaluation prévue à l'article 2 de l'ordonnance susvisée. Il est rattaché au ministre chargé de l'économie et des finances ; que selon l'article 2 du même décret : Cet organisme expert fournit aux personnes publiques qui le demandent un appui dans la

préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat. A ce titre, il peut, en fonction de chacune des demandes : -rendre une expertise sur l'économie générale des projets de contrats ; -assister les personnes publiques dans le cadre de l'élaboration des projets de contrat. Cette assistance peut porter sur la négociation des contrats. / Il élabore un rapport annuel ainsi que tout document utile organisant un retour d'expériences. / Il propose au ministre chargé de l'économie et des finances, en tant que de besoin, les évolutions de textes qui lui paraissent nécessaires ;

Considérant que, si les dispositions de l'article 2 du décret attaqué qui autorisent la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat à assister les personnes publiques qui le lui demandent dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat vont au delà des termes de l'habilitation donnée par l'ordonnance du 17 juin 2004, le Premier ministre pouvait légalement, dans l'exercice du pouvoir réglementaire qui lui est constitutionnellement reconnu, attribuer de nouvelles compétences à cet organisme dès lors que d'une part, s'agissant de l'Etat et de ses établissements publics, il s'est borné à organiser le bon fonctionnement des services et que, d'autre part, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il ne leur a offert qu'une simple faculté qui n'a pu avoir pour effet de restreindre leurs compétences ;

Considérant que les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique ; qu'en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence ; qu'à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée ; qu'une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci ;

Considérant qu'en chargeant la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat d'apporter aux personnes publiques qui le lui demandent un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat, l'article 2 du décret attaqué s'est borné à mettre en oeuvre la mission d'intérêt général, qui relève de l'Etat, de veiller au respect, par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public, du principe de légalité ; qu'en particulier, en prévoyant que cet organisme peut fournir un appui dans la négociation des contrats, le décret attaqué n'a pas entendu permettre à cette mission de les négocier en lieu et place d'une personne publique contractante autre que l'Etat ; qu'ainsi, aucune des attributions confiées à la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat n'emporte intervention sur un marché ; que par suite, les dispositions de l'article 2 du décret attaqué n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence ; qu'elles ne sont pas davantage contraires au principe d'égal accès à la commande publique ; qu'enfin, dès lors qu'elles ne portent pas sur des prestations de services au sens du droit communautaire, elles n'ont pu ni introduire de restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne prohibées par les stipulations de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, ni méconnaître

l'égalité de traitement entre les candidats à la commande publique issue du droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

## **Document n° 3 : CE. Sect., 20 novembre 1964, *Ville de Nanterre***

(…) Considérant que, pour déclarer illégale la création par la ville de Nanterre d'un cabinet dentaire municipal ouvert sans réserve à la généralité de la clientèle locale, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'insuffisance de l'initiative privée n'était établie qu'à l'égard de la partie économiquement la plus défavorisée de la population et que l'intervention de la collectivité publique devait donc trouver sa limite dans celle de l'étendue du besoin particulier qui l'avait provoquée;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en créant en 1949 au dispensaire municipal un cabinet dentaire ouvert à l'ensemble de la population locale la ville de Nanterre a eu pour but, non pas tant de contribuer par ce moyen à l'exécution des obligations d'assistance qui lui incombent en vertu de la loi du 15 Juillet 1893, alors surtout qu'à l'époque le règlement départemental d'aide médicale réservait à certains hôpitaux publics l'administration des soins dentaires aux bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite, mais essentiellement de permettre à la population locale, composée en grande majorité de salariés modestes, de ne pas renoncer aux soins dentaires malgré la carence de l'équipement hospitalier et le nombre insuffisant de praticiens privés, alors surtout que ceux-ci pratiquaient en fait, pour la plupart du moins, des tarifs supérieurs aux tarifs de responsabilité de la sécurité sociale; que cette initiative répondait, dans cette ville et à l'époque envisagée, à un besoin de la population et, par suite, à un intérêt public local;

Considérant, d'autre part, qu'en ne limitant pas l'accès dudit cabinet municipal aux seuls assurés sociaux la ville de Nanterre s'est bornée à appliquer le principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics à l'égard des usagers ; qu'en effet, si ledit principe ne s'oppose pas à ce que les usagers d'un service public de la nature de celui dont s'agit comportent des tarifs différents ou même bénéficient éventuellement de la gratuité complète selon qu'ils sont ou non assurés sociaux, ou bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite, il implique, en revanche, nécessairement que l'accès au service public communal ne soit pas interdit à un habitant de la commune pour le seul motif que ses revenus lui permettent de recourir aux soins de praticiens privés;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de fonctionnement du cabinet municipal et notamment le fait qu'il effectuait toutes les opérations et tous les travaux de prothèse relevant

de la profession dentaire, y compris ceux qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale aient été de nature à détourner l'activité dudit cabinet de son objet d'intérêt public ni, par la suite, à porter une concurrence illégale aux chirurgiens-dentistes de la ville;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Nanterre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que la création du cabinet dentaire municipal était illégale, en tant que ledit cabinet était ouvert sans réserve à la généralité de la clientèle locale…

## **Document n° 4 : CE Ass. 9 novembre 2016, *Fédération de la libre pensée de Vendée***

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 3 septembre 2012, le président de la Fédération de la libre pensée de Vendée a demandé au président du conseil général de la Vendée de s'abstenir de procéder à l'installation de tout élément de culte, notamment d'une crèche de Noël, dans les locaux du conseil général, durant la période des fêtes de la fin de l'année 2012. Une crèche ayant néanmoins été installée dans le hall de l'hôtel du département durant le mois de décembre 2012, la Fédération de la libre pensée de Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président du conseil général de procéder à cette installation. Par un jugement du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Par un arrêt du 13 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel formé par le département de la Vendée, a annulé ce jugement. La Fédération de la libre pensée de Vendée se pourvoit en cassation contre cet arrêt (…)

Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : « *La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.* ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d'une part, d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d'autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, en particulier en n'en reconnaissant ni n'en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi : « *La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public* » et, aux termes de son article 2 : « *La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.* ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l'article 28 de cette même loi précise que : « *Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions* ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d'apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public

à titre d'exposition. En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l'entrée en vigueur de la loi.

Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s'agit en effet d'une scène qui fait partie de l'iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s'agit aussi d'un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année. Eu égard à cette pluralité de significations, l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, dans un emplacement public, n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public.

Dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. A l'inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion d'une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse.

Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que la crèche installée dans le hall du conseil général de la Vendée s'inscrivait dans le cadre de la préparation de la fête familiale de Noël pour estimer qu'elle ne constituait pas, en l'absence de tout élément de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse, un signe ou emblème religieux contraire à l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et au principe de neutralité des personnes publiques. En statuant de la sorte sans rechercher si cette installation résultait d'un usage local ou s'il existait des circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la Fédération de la libre pensée de Vendée est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque (…)

## **Document n° 5 : CE, 29 juin 2023, *Association Alliance Citoyenne et autres, Ligue des droits de l'homme***

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 458088, par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021, 9 février, 3 avril, 15 juillet et 29 décembre 2022 et le 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Alliance citoyenne et Contre Attaque, Mmes A... B..., Iman Bohari, Bouchra Chaïb, Khartoum Dembele, Founé Diawara, Mama Diakité, Hawa Doukoure, Imen Houalef, Zamya Khan et Inçaf Mahassine demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2021 par laquelle le président de la Fédération française de football a rejeté leur demande tendant à l'abrogation ou la modification de l'article 1er des statuts de la Fédération en tant qu'il interdit le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l'occasion de compétitions ou de manifestations organisées par la Fédération française de football ;
2°) d'enjoindre à la Fédération française de football de modifier l'article 1er de ses statuts conformément à la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. (…)
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du sport ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez avocat de la Ligue du droit international des femmes ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2023, sous le n°s 458 088 et le n°463 408, présentée par la Fédération française de football ;

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération française de football a modifié, par délibération de son assemblée fédérale du 28 mai 2006, l'article 1er de ses statuts, pour prévoir que : " La Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu'organes chargés d'une mission de service public déléguée par l'Etat, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d'empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d'une personne, en raison notamment de son sexe, de son orientation sexuelle, de son origine ethnique, de sa condition sociale, de son apparence physique, de ses convictions ou opinions. / Par ailleurs, le respect de la tenue règlementaire et la règle 50 de la Charte olympique assurent la neutralité du

sport sur les lieux de pratique. / A ce double titre, sont interdits, à l'occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci : / - tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical, /- tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale, / - tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande, / (...) ".

2. Par une décision du 31 août 2021, le président de cette fédération a rejeté la demande présentée par l'Alliance citoyenne et les autres requérantes tendant à l'abrogation, dans cet article, de la deuxième interdiction, énoncée à l'article 1er des statuts de la Fédération française de football, de " tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale " en tant qu'elle concerne les signes religieux. L'Alliance citoyenne et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

3. Par une décision implicite, le président de la Fédération a rejeté la demande du 15 décembre 2021 de la Ligue des droits de l'homme tendant à l'abrogation des trois interdictions reproduites au point 1. La Ligue des droits de l'homme demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions et du refus de les abroger en tant qu'elles interdisent toute manifestation et expression politique, religieuse et syndicale.

4. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les interventions :

5. Eu égard à l'objet et à la nature du litige, l'association Les dégommeuses, d'un côté, et la Ligue du droit international des femmes, de l'autre, justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien, respectivement, des conclusions de l'association Alliance citoyenne et autres, et de leur rejet. Leurs interventions sont, par suite, recevables.

Sur la compétence du juge administratif :

6. Aux termes des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code du sport, les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines et sont constituées sous forme d'associations. L'article L. 131-8 du même code dispose que : " I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-14 du même code: " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ". Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2°

Procèdent aux sélections correspondantes ; / 3° Proposent l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau sur la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires ". Aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; / 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; / (...) ". Enfin, il résulte de l'article L. 331-5 du même code que : " Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. / Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret ".

7. Les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. Toutefois, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code du sport, en particulier l'organisation de compétitions, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission présentent le caractère d'actes administratifs. Il en va ainsi alors même que ces décisions seraient édictées par leurs statuts.

8. La Fédération française de football ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, la juridiction administrative est compétente pour connaître des règles édictées par ses statuts si elles manifestent l'usage de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public.

9. Par les dispositions litigieuses, la Fédération française de football doit être regardée comme ayant entendu fixer des règles applicables aux matchs des compétitions qu'elle organise ou des manifestations qu'elle autorise. Ces dispositions interdisent, pendant les matchs, outre les actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Alors même qu'elles ont été insérées dans ses statuts, ces dispositions sont prises par la Fédération en application des prérogatives de puissance publique qui lui sont conférées pour l'accomplissement de sa mission d'organisation des compétitions, et présentent dès lors un caractère administratif. Il s'ensuit que la Fédération n'est pas fondée à soutenir que le juge administratif ne serait pas compétent pour en connaître.

Sur le fond :

10. Aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ". Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure

l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ". Aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 10 de la même convention : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. (...) / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées [ci-après] dans l'intérêt de l'ordre public ". Et aux termes du I de l'article 1er de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. / Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations. / (...) ".

En ce qui concerne les agents de la Fédération française de football ou les personnes sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction :

11. Il résulte du principe de neutralité du service public rappelé par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 24 août 2021 qu'une fédération sportive délégataire de service public est tenue de prendre toutes dispositions pour que ses agents ainsi que les personnes qui participent à l'exécution du service public qui lui est confié, sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, s'abstiennent, pour garantir la neutralité du service public dont elle est chargée, de toute manifestation de leurs convictions et opinions. Il en va ainsi notamment des personnes que la Fédération sélectionne dans les équipes de France, mises à sa disposition et soumises à son pouvoir de direction pour le temps des manifestations et compétitions auxquelles elles participent à ce titre et qui sont, dès lors, soumises au principe de neutralité du service public.

En ce qui concerne les autres licenciés de la Fédération française de football :

12. Une fédération sportive délégataire dispose du pouvoir réglementaire dans les domaines définis par les dispositions législatives citées au point 6, pour l'organisation et le fonctionnement du service public qui lui a été confié. À ce titre, il lui revient de déterminer les règles de participation aux compétitions et manifestations qu'elle organise ou autorise, parmi lesquelles celles qui permettent, pendant les matchs, d'assurer la sécurité des joueurs et le respect des règles du jeu, comme ce peut être le cas de la réglementation des équipements et tenues. Ces règles peuvent légalement avoir pour objet et pour effet de limiter la liberté de ceux des licenciés qui ne sont pas légalement tenus au respect du principe de neutralité du service public, d'exprimer leurs opinions et convictions si cela est nécessaire au bon fonctionnement du service public ou à la protection des droits et libertés d'autrui, et adapté et proportionné à ces objectifs.

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la Fédération a pu légalement interdire " tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical " et " tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande ", qui sont de nature à faire obstacle au bon déroulement des matchs.

14. Par ailleurs, l'interdiction du " port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ", limitée aux temps et lieux des matchs de football, apparaît nécessaire pour assurer leur bon déroulement en prévenant notamment tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport. Dès lors, la Fédération française de football pouvait légalement, au titre du pouvoir réglementaire qui lui est délégué pour le bon déroulement des compétitions dont elle a la charge, édicter une telle interdiction, qui est adaptée et proportionnée.

15. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'incompétence de la Fédération pour édicter une telle interdiction qui, contrairement à ce qui est soutenu, a été adoptée par son assemblée générale, et du caractère injustifié de cette interdiction doivent être écartés. Il en est de même, en tout état de cause, des moyens tirés de la méconnaissance des articles 10 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de ce que les dispositions litigieuses introduiraient une discrimination indirecte fondée sur la religion, les opinions politiques et les activités syndicales et méconnaîtraient dès lors l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Fédération française de football et la Ligue du droit international des femmes, que les requêtes de l'Alliance citoyenne et autres et de la Ligue des droits de l'homme doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Fédération française de football les sommes que réclament à ce titre les requérantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes que présente au même titre la

Fédération française de football.

D E C I D E :
Article 1er : Les interventions des associations Les dégommeuses et La ligue du droit international des femmes sont admises.
Article 2 : Les requêtes n° 458088, 459547 et 463408 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Alliance citoyenne, première dénommée, à l'association Les dégommeuses, à la Ligue des droits de l'homme, à la Ligue du droit international des femmes et à la Fédération française de football.

## **Document n° 6 : CE, ass., 5 mai 2026, Fédération des acteurs de la solidarité et autres, n° 502860 (extraits)**

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 27 mars 2025 et 14 janvier et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Fédération des Acteurs de la Solidarité, JRS France - Service Jésuite des Réfugiés, Comité inter-mouvement auprès des évacués (Cimade), Groupe SOS Solidarités, Secours Catholique, Forum Réfugiés, Emmaüs Solidarité, Aurore, France Terre d'Asile (FTDA) et Coallia demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 28 janvier 2025 par lequel le ministre de l'intérieur a transmis leur demande à ses services et la décision implicite de rejet née le 21 février 2025 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la même demande, tendant à ce qu'il soit mis un terme aux carences affectant le système " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) en prenant toutes mesures utiles permettant d'assurer l'accès normal des usagers au service public, de respecter les lois et règlements applicables aux étrangers et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre toutes mesures utiles permettant d'assurer l'accès normal des usagers au service public et à l'ANEF et la garantie effective de leurs droits, et notamment :
- de modifier le téléservice pour que les usagers puissent réaliser simultanément plusieurs démarches, y compris déposer plusieurs demandes de titres de séjour sur différents fondements, en les hiérarchisant, rectifier une demande ou la compléter, y compris avec des pièces volumineuses ou non sollicitées, ou l'annuler, notamment lorsque les critères ont évolué, modifier l'adresse mail de connexion après vérification de l'identité et obtenir une information précise sur l'avancement de l'instruction ;
- de modifier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour rendre automatique le renouvellement des attestations de prolongation de l'instruction et, subsidiairement, augmenter leur durée de validité ;
- de modifier le même code et le téléservice pour aligner les droits attachés à ces attestations sur ceux attachés aux récépissés et pour que les attestations de décision favorable emportent les mêmes droits que le titre de

séjour et en portent mention ;
- de mettre à jour les différents textes fixant la liste des pièces à fournir pour l'obtention d'un droit auquel peuvent prétendre les étrangers en situation régulière afin d'y faire figurer les documents provisoires de séjour ;
- de diffuser une information lisible sur la valeur juridique des mêmes documents ;
- d'enserrer l'intervention du centre de contact citoyens (CCC) et des points d'accueil numérique (PAN) dans un délai au-delà duquel la solution de substitution devra être mise en place et d'imposer, en cas de dysfonctionnement, la délivrance d'un récépissé l'indiquant et prorogeant les droits au séjour ;
- d'accroître les prérogatives informatiques du CCC pour lui permettre de surmonter certains blocages mineurs ;
- de préciser les modalités de recours à la solution de substitution après l'échec de l'intervention du PAN, d'interdire le recours exclusif à des personnes en service civique dans des PAN et de diffuser une meilleure information sur l'existence des PAN dans les différentes préfectures ;

Sur le cadre juridique et l'office du juge :

4. Il appartient au gestionnaire d'un service public, afin de satisfaire l'intérêt général en vue duquel le service a été institué, de veiller à garantir le droit d'accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d'égalité, d'assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'exigence de mutabilité. Il doit notamment corriger les dysfonctionnements qui affectent le service et qui sont de nature à limiter de façon anormale le droit d'accès des usagers ou à compromettre l'exercice par ces derniers des droits qui leur sont reconnus par la loi.

5. Lorsque le juge administratif est saisi d'une requête tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration à une demande tendant à ce qu'elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d'une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité et, si tel est le cas, d'enjoindre à l'administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Il en est ainsi, en particulier, lorsque est contesté devant lui le refus, par l'administration, de mettre fin à des dysfonctionnements affectant un service public dont il est soutenu qu'ils compromettent l'accès normal des usagers à ce service public ou font obstacle à l'exercice effectif de leurs droits. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.

6. Il incombe à l'administration d'accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l'ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d'ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu'elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d'une règle de droit dans l'accomplissement de ses missions par l'administration, et notamment de l'obligation de veiller à ce que des dysfonctionnements d'un service public ne fassent pas obstacle à l'exercice effectif de leurs droits par les

personnes concernées, et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point précédent, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s'il apparaît au juge qu'au regard de la portée de l'obligation qui pèse sur l'administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l'exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l'obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.

7. Lorsque l'illégalité du refus de l'administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d'y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d'assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l'instruction a révélé l'existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l'intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d'un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Enfin, dans l'hypothèse où l'édiction d'une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue ou au bon fonctionnement du service public et où l'abstention de l'autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu'elle puisse être respectée, il appartient au juge d'ordonner à l'administration de prendre la mesure considérée.

8. Le pouvoir réglementaire ne saurait rendre obligatoire le recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative, et notamment pour demander la délivrance d'une autorisation, qu'à la condition de permettre l'accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits. Il doit tenir compte de l'objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l'outil numérique mis en œuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l'accès aux services en ligne ou dans leur maniement.

9. Eu égard aux caractéristiques du public constitué par les personnes demandant un titre de séjour, à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande, il incombe au pouvoir règlementaire, lorsqu'il impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de prévoir les dispositions nécessaires pour que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l'accomplissement des démarches administratives. Il lui incombe, en outre, pour les mêmes motifs, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement.

10. A cet égard, l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "

(...) Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement (...) ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution (...) ". Un arrêté du 1er août 2023, pris pour l'application de ces dispositions, a fixé " les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice ANEF ".(…)

En ce qui concerne les dysfonctionnements liés à la conception ou au fonctionnement de l'ANEF :

S'agissant de l'impossibilité de présenter simultanément ou successivement plusieurs demandes :

12. En premier lieu, alors qu'aucune disposition textuelle ne fait obstacle à ce qu'un étranger demande simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, et qu'une telle possibilité demeure ouverte pour les titres de séjour qui n'entrent pas dans le champ de l'ANEF, il est constant que celle-ci, en raison de contraintes liées à la conception technique du système d'information, ne permet pas à l'étranger qui demande un titre de séjour de présenter simultanément ou successivement une autre demande, pour un titre relevant d'une autre catégorie, tant que l'administration n'a pas statué sur sa première demande. En outre, s'il est loisible à l'étranger qui s'est vu opposer une première décision de refus de présenter une nouvelle demande sur un autre fondement, il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour est l'un des cas justifiant que l'autorité administrative puisse obliger un étranger à quitter le territoire français et, aux termes de l'article L. 432-1-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative (...) ". Ainsi, l'impossibilité, pour des motifs techniques, de présenter de telles demandes, est de nature à compromettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur plusieurs fondements. A cet égard, le seul fait que le demandeur puisse signaler, dans le champ " observations ", à la fin de la téléprocédure, qu'il serait éligible à un titre de séjour sur un autre fondement ne saurait en l'espèce être regardé, en l'absence de toute possibilité de présenter à ce stade les documents de nature à justifier le bien-fondé d'une telle demande, comme susceptible d'y remédier. Dès lors, le refus de prendre toutes mesures utiles pour faire évoluer l'ANEF en tant qu'elle fait obstacle à ce que l'étranger qui estime disposer d'un droit au séjour sur plusieurs fondements distincts puisse faire valoir l'ensemble de ses droits entache d'illégalité la décision du ministre de l'intérieur.

(…)

**CAS PRATIQUE** (EXTRAIT DU PARTIEL 2025)

**1)** Tout.e. jeune avocat.e. installé.e. en région parisienne, vous êtes extrêmement sollicité.e. par de nouveaux clients qui vous interrogent sur les chances de succès de leurs dossiers. Ceux-ci, tout aussi divers que variés, soulèvent des questions de droit public pour lesquelles vous êtes spécialiste. Aussi, vous vous efforcerez de répondre à votre client du jour en étant le plus pédagogique possible et en construisant votre argumentation autour de syllogismes précis et rigoureux.

Aujourd'hui, c'est Benjamin qui vient vous solliciter à la suite de plusieurs mésaventures qui lui sont survenues ces derniers temps.

Tout d'abord, Benjamin est l'heureux propriétaire d'un studio qu'il a acquis en 2020 au rez-de-chaussée d'un immeuble situé sur le front de mer à Nice. En s'installant en 2021 avec son épouse, il a mis en location ce studio et son ancien locataire vient de dénoncer son bail à la suite de nombreuses fuites d'eau constatées dans la cuisine de l'appartement. En récupérant les clefs, Benjamin ne peut que constater l'étendue des dégâts. Les murs et le parquet de la cuisine de son studio sont effectivement gorgés d'eau et particulièrement abîmés ; aucun locataire n'acceptera plus de vivre ici tant que des travaux n'auront pas été effectués.

Après la visite d'experts, Benjamin comprend que les fuites d'eau à répétition proviennent non de la négligence de son ancien locataire mais du mauvais état de la conduite de distribution des eaux située sous la voie publique et du branchement particulier de cette conduite à son immeuble et à son appartement. Il entend donc réclamer la réparation de ses préjudices à la commune de Nice qui exploite en régie le service public de distribution et d'assainissement des eaux.

Inquiet du fait qu'il n'occupe pas l'immeuble, il vous demande quel juge sera compétent pour connaître de son litige avec l'exploitant du service des eaux

**2)** Enfin, Benjamin vient d'apprendre que le conseil municipal de Nice a, dans une délibération de la semaine dernière, décidé de ne pas renouveler le contrat le lie à l'exploitant de la piscine municipale où il nage chaque week-end. La ville souhaite en effet faire détruire l'infrastructure pour la remplacer par un terrain de pétanque moins coûteux à entretenir. Alors même que les bénéfices sanitaires d'une activité sportive régulière sont vantés par la ville sur tous ses panneaux municipaux, Benjamin ne comprend pas une telle décision. Il vous demande comment l'attaquer et quelles sont ses chances de succès

# SEANCE N° 4 :
# LA NOTION DE POLICE ADMINISTRATIVE

Liste des documents :

- Document n° 1 : Code général des collectivités territoriales (extraits)
- Document n° 2 : Code de procédure pénale (extraits)
- Document n° 3 : TC, 16 décembre 1977, *Dlle Motsch*
- Document n° 4 : CE, Ass., 27 oct. 1995, *Commune de Morsang-sur-Orge* (extrait)
- Document n° 5 : CE, 15 juillet 2026, *Préfet de police et Min. de l'Intérieur c/ Société Z Machine*, n° 513080.
- Document n° 6 : B. SEILLER, « La notion de police administrative », *RFDA* 2015, p. 876.
- Document n° 7 : O. RENAUDIE, « Police administrative et ordre public : les notions plastique, est-ce si fantastique ? », *AJDA* 2024, p. 774.

Exercice : Dissertation

*

## Document n °1 : Code général des collectivités territoriales (extraits)

**Art. L. 2212-1** : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs.

**Art. L. 2212-2 :** La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles, ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les

attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3º Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…)

5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…).

## Document nº 2 : Code de procédure pénale (extraits)

**Art. 13** : La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.

**Art. 14** : Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte (...).

## Document 3 : TC, 16 décembre 1977, *Delle Motsch*

VU LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ; LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;

CONSIDERANT QUE, LE 12 AOUT 1972, AU COURS D'UNE OPERATION DE CONTROLE EFFECTUEE PAR LA POLICE ET DESTINEE A PREVENIR LES ACTES DE BANDITISME, LE SIEUR GUERRERO, CONDUISANT UNE VOITURE AUTOMOBILE, DANS LAQUELLE AVAIT PRIS PLACE LA DEMOISELLE MOTSCH, A FORCE UN BARRAGE POUR ECHAPPER A TOUTE VERIFICATION, A POURSUIVI SA ROUTE AU MEPRIS DE LA SIGNALISATION, A REFUSE SCIEMMENT D'OBTEMPERER A LA SOMMATION DE S'ARRETER QUI LUI ETAIT FAITE A EMPRUNTE UNE VOIE EN SENS INTERDIT ET A DIRIGE SON VEHICULE SUR UN AGENT QUI TENTAIT DE LE CONTRAINDRE A S'ARRETER ; QUE L'OFFICIER DE PAIX PRINCIPAL MALITOURNE, QUI AVAIT QUALITE POUR CONSTATER LES INFRACTIONS ET EN RECHERCHER ET APPREHENDER LES AUTEURS, POURSUIVIT LE VEHICULE DU SIEUR GUERRERO, A L'AIDE D'UNE VOITURE DE SERVICE, ET FIT FEU DANS SA DIRECTION, BLESSANT LA DEMOISELLE MOTSCH ; QU'EN UTILISANT AINSI SON ARME DANS L'INTENTION D'APPREHENDER UN INDIVIDU QUI VENAIT DE COMMETTRE PLUSIEURS INFRACTIONS, CET OFFICIER DE POLICE A FAIT UN ACTE QUI RELEVE DE LA POLICE JUDICIAIRE ; QUE LES LITIGES RELATIFS AUX DOMMAGES QUE PEUVENT CAUSER LES AGENTS DU SERVICE PUBLIC DANS DE TELLES CIRCONSTANCES RESSORTISSENT AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A

TORT QUE LE PREFET DES ALPES MARITIMES A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE ; [ANNULATION DE L'ARRETE DE CONFLIT].

## **Document 4 :** CE, Ass., 27 oct. 1995, *Commune de Morsang-sur-Orge* (extrait)

(…) Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique" ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ;
Considérant que l'attraction de "lancer de nain" consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle ; que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l'interdire même en l'absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 25 octobre 1991 du maire de Morsang-sur-Orge interdisant le spectacle de "lancer de nains" prévu le même jour dans une discothèque de la ville, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait qu'à supposer même que le spectacle ait porté atteinte à la dignité de la personne humaine, son interdiction ne pouvait être légalement prononcée en l'absence de circonstances locales particulières ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un tel motif est erroné en droit ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Fun Production et M. X... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que le respect du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police municipale interdise une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l'ordre public ; que tel est le cas en l'espèce, eu égard à la nature de l'attraction en cause ;
Considérant que le maire de Morsang-sur-Orge ayant fondé sa décision sur les dispositions précitées de l'article L. 131-2 du code des communes qui justifiaient, à elles seules, une mesure d'interdiction du spectacle, le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait trouver sa base légale ni dans l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni dans une circulaire du ministre de l'intérieur, du 27 novembre 1991, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Morsang-sur-Orge en date du 25 octobre 1991 et a condamné la commune de Morsang-sur-Orge à verser aux demandeurs la somme de 10 000 F ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à l'augmentation du montant de cette indemnité ;

Sur les conclusions de la société Fun Production et de M. X... tendant à ce que la commune de Morsang-sur-Orge soit condamnée à une amende pour recours abusif :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables (…)

Décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 février 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes de la société Fun Production et de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées (…)

## **Document 5 : CE, 15 juillet 2026, *Préfet de police et Min. de l'Intérieur c/ Société Z Machine*, n° 513080.**

Vu la procédure suivante :
La société Z Machine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Z Machine " situé au 22/24 rue d'Alleray à Paris (15ème arrondissement). Par une ordonnance n° 2602318 du 9 février 2026, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de police, agissant en qualité d'autorité municipale de la ville de Paris, et le ministre de l'intérieur demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Z Machine ;
3°) de mettre à la charge de la société Z Machine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'ordonnance qu'ils attaquent est entachée :
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la situation financière alléguée par la société Z Machine était à elle seule de nature à caractériser une situation d'urgence, alors qu'il appartenait au juge des référés de procéder à une appréciation objective et globale de l'urgence et de rechercher à ce titre si les motifs d'intérêt général invoqués par le préfet de police n'exigeaient pas que l'exécution de la décision de fermeture de l'établissement soit maintenue ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la société Z Machine ne disposait pas d'autres établissements permanents permettant le maintien de son activité, sans procéder à une appréciation concrète de la situation d'urgence, alors que le préfet de police avait démontré que la société avait la possibilité de déplacer son activité dans d'autres lieux ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient la condition d'urgence en tenant pour établies les déclarations de la société Z Machine selon lesquelles la fermeture de son établissement la plaçait dans l'impossibilité d'assurer la pérennité de l'ensemble de ses activités et de couvrir ses frais fixes, alors que la société ne produisait pas les éléments comptables ou bancaires propres à établir le risque allégué d'atteinte à sa viabilité économique ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle prend en compte les dettes locatives et la fermeture de l'établissement durant l'année 2025 pour se mettre en conformité avec les normes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, alors que ces circonstances sont sans rapport avec l'arrêté attaqué ;
- d'erreur de droit, faute d'avoir pris en compte l'hostilité massive exprimée par les riverains pour apprécier si le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en se fondant sur l'atteinte à la tranquillité et à la moralité publiques était de nature à créer un doute sérieux, alors que cette circonstance suffisait à caractériser un trouble à l'ordre public ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle se fonde sur la seule absence de troubles à l'ordre public provoqués par les clients de l'établissement et la réprobation par les riverains des pratiques sexuelles qui s'y déroulent pour retenir l'existence d'un doute sérieux quant à l'atteinte à la tranquillité et à la moralité publiques, alors que d'autres éléments étaient de nature à corroborer les témoignages produits par le préfet pour caractériser des troubles à l'ordre public ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle retient l'existence d'un doute sérieux quant à l'atteinte à la dignité de la personne humaine au seul motif que l'organisation mise en place permettrait aux femmes de donner leur consentement et de le révoquer à tout moment, alors qu'une telle circonstance est inopérante lorsqu'est en cause un risque d'atteinte à la dignité de la personne humaine ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, faute d'avoir recherché si, telles qu'elles étaient concrètement promues et mises en œuvre, les pratiques de marchandisation du corps de la femme imputables à l'établissement ne caractérisaient pas une atteinte à la dignité des femmes participant à ces événements ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir l'existence d'un doute sérieux quant à la nécessité de prévenir la commission d'infractions pénales, elle se fonde sur le motif suivant lequel la société Z Machine n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire alors qu'elle mène ce type d'activités depuis quinze ans ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il ne résultait pas des éléments produits par le préfet de police que les événements de nature sexuelle organisés par la société étaient de nature à favoriser la commission d'infractions pénales, alors que les pièces versées au dossier établissaient la réalité des risques de commission d'agressions sexuelles, de viols, de violences volontaires et de traite des êtres humains ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle comporterait des énonciations susceptibles de provoquer une " victimisation secondaire " contraire aux obligations de protéger la dignité des victimes au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;
- de méconnaissance de l'office du juge des référés et d'erreur de droit en ce qu'elle apprécie isolément chacun des motifs d'ordre public justifiant la fermeture administrative de l'établissement Z Machine sans analyser si, globalement, ces motifs étaient de nature à justifier la fermeture de l'établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la société Z Machine conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'État et de la Ville de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police et le ministre requérants ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la Ville de Paris, représentée par son maire, demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi et, en cas de règlement de l'affaire au titre de la

procédure de référé engagée, rejette la demande de suspension de la société Z Machine. Elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- commis une erreur de droit, faute d'avoir procédé à une appréciation objective et globale de l'urgence ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour considérer que la condition d'urgence était remplie, que l'arrêté litigieux interdisait à la société Z Machine de poursuivre toutes ses activités et risquait de la mettre en péril ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur des éléments inopérants pour caractériser les troubles à la tranquillité publique et en considérant que les troubles de voisinage et à la tranquillité publique n'étaient pas établis par les éléments versés au dossier ;
- commis une erreur de droit en écartant toute atteinte à la dignité de la personne humaine, au seul motif que l'organisation mise en place par la société Z Machine permettrait aux femmes de donner leur consentement et de le révoquer à tout moment, sans rechercher si la nature des actes en cause, leur promotion et leur commercialisation n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à leur dignité, indépendamment de l'existence d'un consentement ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant que le consentement des participantes était suffisamment acquis, sans s'être interrogé sur les conditions concrètes de son effectivité ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur le fait qu'il n'était pas établi que des plaintes avaient effectivement été diligentées et avaient donné lieu à des poursuites à l'encontre de la société Z Machine pour écarter le motif tiré de la nécessité de prévenir des infractions pénales, alors qu'une telle circonstance est inopérante.

Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, les associations " Les Effronté-es ", " La Fondation des Femmes " et " Osez le Féminisme ! " demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi et, en cas de règlement de l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, rejette la demande de suspension de la société Z Machine. Elles se réfèrent aux moyens exposés dans le pourvoi du préfet de police et du ministre de l'intérieur.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du pourvoi en tant qu'elles émanent du ministre de l'intérieur, faute d'intérêt pour agir dans un litige concernant un arrêté pris par le préfet de police en tant qu'autorité de la Ville de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Préfecture de police et du ministre de l'intérieur, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la société Z Machine, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'association " Osez le Féminisme ", de l'association " Les Effronté-es " et de la Fondation des femmes, et à la Selas Froger et Zajdela, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de police a décidé la fermeture administrative de l'établissement exploité par la société " Z Machine ", situé au 22/24 rue d'Alleray à Paris (15ème arrondissement), en raison des troubles à l'ordre public résultant de l'organisation dans celui-ci d'activités sexuelles collectives désignées sous l'appellation de " gang bangs ". Le ministre de l'intérieur et le préfet de police se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 9 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les interventions :

2. Eu égard à la nature et à l'objet du litige, la Ville de Paris, représentée par son maire, d'une part, et les associations " Les Effronté-es ", " La Fondation des Femmes " et " Osez le Féminisme ! ", d'autre part, justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Ainsi, leurs interventions sont recevables.

Sur le pourvoi en cassation :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) "

4. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine constituant une des composantes de l'ordre public, cette autorité peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, prendre les mesures qu'appelle l'exercice d'une activité par un établissement lorsqu'elle porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Il appartient également à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises.

5. Aux termes de l'article 222-22 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 novembre 2025

modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles : " Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. / Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. / Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. (...) "

6. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, pour ordonner la fermeture de l'établissement Z Machine, le préfet de police s'est fondé sur le trouble à l'ordre public résultant de son activité eu égard, d'une part, à l'atteinte à la tranquillité et à la moralité publique, d'autre part, à l'atteinte à la dignité de la personne humaine et, enfin, au risque de commission d'infractions. Le juge des référés a estimé qu'étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté des moyens contestant l'appréciation portée par le préfet de police sur chacun de ces trois motifs.

7. En premier lieu, pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur l'existence d'une atteinte à la dignité de la personne humaine, le juge des référés s'est borné à relever, d'une part, que la société avait mis en place une organisation permettant aux femmes de déterminer la nature et les conditions de déroulement de l'événement, dont elles pourraient demander l'arrêt à tout moment, et, d'autre part, que le préfet se fondait essentiellement sur des mentions de nature promotionnelle tirées du site internet de la société. Toutefois, en se prononçant par ces motifs, sans rechercher si, compte tenu des caractéristiques propres des activités proposées par la société, consistant à offrir contre paiement à des groupes d'hommes des rencontres sexuelles simultanées avec une ou plusieurs femmes, les conditions concrètes d'organisation et de déroulement de ces activités, y compris le fait pour le gérant de l'établissement d'inviter les participants à certains événements à " utiliser le corps " d'une femme " de toutes les manières possibles ", au motif qu'elle consentirait " à ne pas consentir ", dans le cadre de scénarios pouvant inclure agressions sexuelles, violences, séquestrations et enlèvements, n'étaient pas, quand bien même de tels événements reposeraient sur une mise en scène agréée avec les participantes, qui ne seraient pas rémunérées, de nature à porter par lui-même atteinte, par le traitement qu'il est proposé de réserver aux femmes concernées, à la dignité de la personne humaine, le juge des référés a commis une erreur de droit.

8. En deuxième lieu, pour remettre en cause l'appréciation du préfet de police sur le risque que soient commises des infractions pénales dans le cadre de l'exploitation de l'établissement, le juge des référés s'est borné à relever qu'un tel risque n'était pas établi eu égard aux éléments produits par le préfet de police et en l'absence de poursuites judiciaires contre la société. Il résulte cependant des pièces du dossier qui lui était soumis, et en particulier des descriptions de certains événements sur le site internet de la société, que leur organisation, avec des groupes parfois importants d'hommes auxquels étaient susceptibles de s'associer personnellement les organisateurs et dans le cadre de scénarios mentionnés au point précédent, y compris en offrant aux femmes concernées " à boire plus que de raison ", n'était pas entourée des garanties propres à s'assurer du consentement libre, éclairé et révocable des participantes, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 222-22 du code pénal. C'est, par suite, au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que le juge des référés a retenu que le risque de commission d'infractions pénales dans le cadre de l'activité

de l'établissement en cause n'était pas établi.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes des dispositions de la première phrase de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ".

12. Si la société Z Machine soutient que l'arrêté du préfet de police du 21 janvier 2026 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, il résulte de l'instruction que le préfet de police a informé la société des faits constatés et de la mesure envisagée par un courrier en date du 16 janvier 2026, qui précisait qu'au regard de l'urgence de la situation, elle pouvait présenter des observations jusqu'au 19 janvier 2026. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.

13. En second lieu, d'une part, il ressort des éléments produits par le préfet de police que, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'établissement exploité par la société requérante organise, en contrepartie d'un paiement demandé aux participants, des rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un groupe parfois important d'hommes reposant sur des scénarios comprenant des situations d'agressions sexuelles, de violences, de séquestrations ou d'enlèvements des femmes participantes, les hommes étant explicitement invités à se montrer injurieux et virulents à l'encontre de ces dernières, ainsi réduites à un rôle exclusif d'objet sexuel. Le moyen tiré de ce que l'ensemble de ces éléments ne caractériseraient pas une atteinte à la dignité de la personne humaine justifiant la fermeture de l'établissement n'est, en l'état du dossier, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. D'autre part, comme indiqué au point 8, il ressort également des éléments versés au dossier que les événements organisés par la société, en ce qu'ils mettent en présence des groupes d'hommes auxquels sont susceptibles de s'adjoindre les organisateurs eux-mêmes, dans le cadre de scénarios invitant notamment les intéressés à exercer une contrainte physique et sexuelle sur les femmes participantes, le cas échéant en les incitant à consommer de l'alcool, exposent ces dernières à des risques graves d'atteintes à leur intégrité physique et morale et d'agression sexuelle, en l'absence notamment de garanties propres à s'assurer de leur consentement libre, éclairé et révocable, au sens des dispositions de l'article 222-22 du code pénal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une application erronée de ses pouvoirs en se fondant sur le motif tiré de la nécessité de prévenir la commission d'infractions pénales n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par conséquent, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que le

préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'un de ces deux motifs, et que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la mesure prise ne serait pas proportionné aux motifs qui la justifient n'est également pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence de rejeter la demande de suspension présentée par la société Z Machine. (…)

D E C I D E :

---

Article 1er : Les interventions de la Ville de Paris, d'une part, et des associations " Les Effronté-es ", " La Fondation des Femmes " et " Osez le Féminisme ! ", d'autre part, sont admises.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 9 février 2026 est annulée.
Article 3 : La demande de suspension présentée par la société Z Machine est rejetée.
Article 4 : La société Z Machine versera au préfet de police, agissant en tant qu'autorité de la ville de Paris, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

## **Document n° 6 : B. Seiller, « La notion de police administrative », *RFDA* 2015, p. 876.**

Pourquoi revenir sur la notion de police administrative ? Tout n'a-t-il pas déjà été dit, écrit, théorisé à propos de cette notion ? N'est-il pas révolu le temps où Hauriou constatait, en conclusion de sa note sous Conseil d'État du 3 décembre 1897, *Ville de Dax* (2), « les matières de police n'ont pas jusqu'ici chez nous été suffisamment étudiées au point de vue théorique ; elles sont manifestement incohérentes. On n'a pas encore cherché à établir la liste des droits que contient le pouvoir de police. On a beaucoup disserté sur la forme des règlements et sur la compétence réciproque des autorités qui font les règlements. Presque jamais on ne s'est préoccupé de la limite des pouvoirs réglementaires du côté de la liberté. C'est une étude à faire ; elle en vaut la peine ».

Cette étude a été faite depuis mais, il est vrai, plutôt à l'époque contemporaine que dans les années qui ont suivi la suggestion d'Hauriou.

L'ouvrage fondamental sur la question est évidemment la thèse d'E. Picard, parue en 1984(3), qui porte exactement sur le sujet qu'il nous incombe de traiter. Le même auteur a par la suite publié d'autres travaux relatifs à la police administrative. D'autres auteurs s'y intéressent particulièrement, à l'instar de J. Petit, qui a notamment rédigé le chapitre qui y est consacré dans le *Traité de droit administratif* publié par Dalloz(4) et conçu l'article pertinent de la « Constitution administrative de la France », fruit d'un colloque organisé en 2011 à l'Université Paris II(5). Plus récemment encore, fin 2013, un important colloque sur la police administrative s'est tenu à la Faculté de droit de Nancy(6).

Il semble dès lors tout aussi inutile que présomptueux de prétendre à nouveau s'interroger sur ce qu'est la police administrative, qui plus est à l'occasion d'un colloque consacré à la dignité de la personne humaine

vingt ans après l'arrêt *Commune de Morsang-sur-Orge*.

Autant le reconnaître d'emblée : effectivement, les lignes qui suivent ne s'écarteront guère de la présentation habituelle de la police administrative. Tout au plus souligneront-elles, sinon ses contradictions, du moins l'irréductibilité de chacun de ses aspects à des idées simples et homogènes.

Le constat est probablement inéluctable au sujet d'une notion qui est au croisement de deux exigences fondamentales de toute vie en société : la liberté d'une part, l'ordre d'autre part.

Joseph Fouché, qui fut ministre de la police sous le Directoire, le Consulat, l'Empire et encore pendant les Cent-Jours, rédigea en 1815 une circulaire souvent citée au XIX$^{e}$ siècle parce qu'elle exprime assez correctement ce qu'est la police. Selon ce texte, la police « est instituée, ainsi que la justice, pour assurer l'exécution des lois et non pour les enfreindre, pour garantir la liberté du citoyen et non pour y porter atteinte, pour assurer la sécurité des hommes honnêtes et non pour empoisonner la source des jouissances sociales. Elle ne doit ni s'étendre au-delà de ce qu'exige la sûreté publique ou particulière, ni gêner le libre exercice des facultés de l'homme et des droits civils, par un système violent de précautions ».

La postérité de ce bel exposé a cependant été compromise par la personnalité de son auteur. Ce grand défenseur des libertés commença sa remarquable carrière en réprimant avec une telle violence l'insurrection lyonnaise en 1793 qu'il fut rappelé à Paris, où il affirma, pour justifier son ardeur, « le sang du crime féconde le sol de la liberté et affermit sa puissance ». Le jeune Gerando faillit d'ailleurs être l'une des nombreuses victimes de cette répression et n'échappa qu'*in extremis* à l'exécution.

Dans ses *Institutes du droit administratif français*, parus en 1829, Gerando est lui-même fort peu disert quant à la police administrative. Mais l'auteur du *Traité de la bienfaisance publique*, qui occupa également de hautes fonctions administratives sous l'Empire, est infiniment plus crédible que Fouché lorsqu'il indique que l'ordre public, « qui sert d'objet » à la police administrative, tend à conserver la paix et la sécurité publique(7).

Bien que fort brève, sa présentation de la police fait apparaître une autre notion qui en est au coeur : l'ordre public. Leurs liens sont si intimes, en dépit de leur indispensable distinction, qu'il est impossible d'étudier la police administrative sans y associer l'étude de l'ordre public.

Ceci se constate dans les définitions de la police administrative actuellement données dans les manuels de droit administratif. Selon R. Chapus, « exercer la police administrative, c'est assurer un service public : celui du maintien de l'ordre public »(8). Pour P.-L. Frier et J. Petit, « la police administrative apparaît (...) comme la fonction de l'administration qui a pour but de faire régner l'ordre public, en imposant en amont aux membres de la société des restrictions à leurs libertés publiques, pour assurer la discipline qu'exige la vie sociale »(9). P. Chrétien, N. Chifflot, M. Tourbe, indiquent pour leur part que « les mesures de police administrative, qui ont pour effet d'imposer des limitations aux libertés des individus, ne sont régulières que si elles sont prises en vue du maintien de l'ordre public »(10). D. Truchet souligne que la police « a pour objet d'empêcher que l'ordre public soit troublé »(11). B. Stirn et Y. Aguila définissent la police administrative « par son objet, qui est de maintenir l'ordre public »(12). Y. Gaudemet, s'il n'utilise pas l'expression « ordre public » s'y réfère

cependant implicitement puisqu'il définit « le pouvoir de police (...) par son but qui est d'assurer la tranquillité (...), la sécurité (...) ou la salubrité publique »(13).

Il est en effet impossible de définir la fonction de police sans référence à l'ordre public. C'est pourquoi nous définirons la police comme la fonction qui tend à assurer l'ordre public, c'est-à-dire l'état dans lequel les libertés s'exercent au mieux. De cette façon, les liens qui unissent la police directement à l'ordre public et indirectement aux libertés apparaissent clairement.

Cette définition est par ailleurs pleinement conforme à ce que pose le texte qui constitue le socle sur lequel repose notre système d'organisation des libertés, la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Son article 2 affirme d'abord que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme ». L'article 4 précise que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits » et l'article 5 ajoute que « la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». L'article 12 tire en quelque sorte la conséquence de ces divers principes en constatant que « la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ».

Ces dispositions, qui organisent un régime répressif d'exercice des libertés, sont profondément libérales. Ainsi que l'affirme encore l'article 5 de la Déclaration, « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ». En d'autres termes, ceux du commissaire du gouvernement L. Corneille concluant en 1917 dans l'affaire *Baldy*, « la liberté est la règle et la restriction de police l'exception »(14). Comme ce dernier l'avait préalablement souligné, « pour déterminer l'étendue du pouvoir de police dans un cas particulier, il faut tout de suite se rappeler que les pouvoirs de police sont toujours des restrictions aux libertés des particuliers, que le point de départ de notre droit public est dans l'ensemble les libertés des citoyens, que la Déclaration des droits de l'homme est, implicitement ou explicitement, au frontispice des constitutions républicaines »(15).

Définir la police comme la fonction qui tend à assurer l'ordre public, c'est-à-dire l'état dans lequel les libertés s'exercent au mieux, appelle quelques précisions qui permettront de mettre en lumière les paradoxales unité et diversité de la police d'abord et de l'ordre public ensuite.

## LA POLICE

### Son unité

Dire que la police est une fonction, c'est d'abord rejeter les définitions reposant sur un critère formel, qui fut longtemps prédominant et auquel F.-P. Bénoit donnait la préférence. Selon lui « la police administrative, c'est l'usage de la prohibition par une autorité administrative (16). C'est également s'écarter quelque peu de la définition matérielle, très largement répandue depuis Hauriou, et qui définit la police exclusivement par son résultat - le maintien de l'ordre public - et même, plus précisément, par le contenu de ce résultat, qui est le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques.

La définition fonctionnelle ici retenue peut néanmoins sembler fort proche de ces définitions matérielles. Elle s'en distingue toutefois par le fait qu'elle assigne une finalité à la recherche de l'ordre public et ne laisse pas supposer qu'il constitue une fin par lui-même. En effet, si la police vise à assurer le maintien de l'ordre public, c'est exclusivement en tant que celui-ci est l'état dans lequel les libertés s'exercent au mieux. En bref, la police doit favoriser l'exercice le plus complet possible des libertés.

Or cet état d'ordre public n'est pas spontané. Libres de toute entrave, les libertés de chacun ne s'épanouissent pas mais suscitent rapidement la prédominance de celles de quelques-uns. Le constat est ancien. D. Serrigny avait ainsi choisi cette citation de Fénelon comme épigraphe à son *Traité de droit public des Français* : « la liberté sans ordre est un libertinage qui attire le despotisme »(17). Jean-Henri-Nicolas de Fooz, auteur au milieu du XIX$^{e}$ siècle d'un ouvrage sur le droit administratif belge remarquable par sa présentation de la police encore très pertinente, soulignait également que « lorsque chacun jouit d'une liberté sans bornes, la liberté n'existe pour personne »(18).

Cet auteur en déduisait que l'ordre social « règne au sein d'une société quelconque, lorsque l'autonomie et l'activité de chacun de ses membres sont disciplinées de telle sorte qu'elles puissent et doivent se coordonner avec l'autonomie et l'activité de tous les autres »(19). Il concluait que « c'est dans les limitations légales qui affectent les rapports d'homme à homme que la liberté trouve ses véritables garanties »(20).

La Déclaration de 1789 en tire les conséquences, qui, après avoir posé le primat des libertés, admet qu'elles ne sont pas absolues et doivent, pour s'exercer pleinement, connaître des limites à l'initiative du législateur. Voilà pourquoi E. Picard peut affirmer que « l'ordre public ne doit pas être conçu comme le tombeau des libertés et des droits, mais comme leur abri même »(21). Ce même auteur précise « plus qu'il ne lui est opposé, l'ordre public est nécessaire à la liberté, laquelle ne peut se concevoir ni s'exercer sans lui. Il lui est à la fois consubstantiel et coextensif, car il y a toujours de l'ordre public dans la liberté et de la liberté dans l'ordre public »(22). J.-H.-N. de Fooz avait déjà compris que, contrairement à ce qui est encore souvent prétendu, « il n'y a pas d'opposition entre ces deux biens qui sont si dignes des aspirations de l'homme et qu'il appelle l'ordre, la liberté »(23).

L'unité de la fonction de police apparaît ici : toutes les mesures de police sont également inspirées par la recherche d'un état de paix sociale, seul apte à permettre la meilleure jouissance possible des libertés. Mais si ses liens avec l'ordre public et les libertés font l'unité de la police, cela ne saurait cacher la diversité de celle-ci.

## La diversité

Cette diversité apparaît à deux égards.

En premier lieu, s'il est nécessaire de recourir à l'expression « police administrative », c'est en raison de la nécessité de la distinguer d'autres types de police. L'une d'entre elle est bien connue et classiquement distinguée de la police administrative par sa contribution différente à la réalisation de l'ordre public. Tandis que la police administrative s'efforce, pour l'essentiel, de prévenir les troubles à l'ordre public, la police

judiciaire vise à réprimer les atteintes qui peuvent lui être portées. Ce critère, lié à la finalité distincte de l'intervention de ces deux types de police, a été consacré par la jurisprudence au milieu du XX[e] siècle(24) mais fut énoncé bien plus tôt en doctrine. Pour le citer à nouveau, J.-H.-N. de Fooz exprimait parfaitement les choses dès 1859 : « La police judiciaire se dirige vers le passé. Elle s'attache à des individualités, soit de faits, soit de personnes. Elle n'atteint que des actions coupables et punissables. Elle est consécutive ; elle est répressive. La police administrative se préoccupe d'éventualités, soit qu'elle impose l'obligation de faire, soit qu'elle défende de faire ou bien qu'elle prescrive de souffrir ou de laisser faire. Elle dispose pour l'avenir et seulement pour l'avenir. Elle est essentiellement préventive, préservatrice »(25). Le critère finaliste est le meilleur moyen de distinguer les polices administrative et judiciaire même s'il n'est pas pleinement satisfaisant. En effet, la première est encore mise en oeuvre lorsque des mesures sont prises pour faire cesser un trouble à l'ordre public tandis que la seconde sert également parfois à prévenir la commission des atteintes à l'ordre public(26).

Mais, contrairement à ce qu'il est le plus souvent exposé, les polices administrative et judiciaire n'épuisent pas les différents types de police. On doit à Etienne Picard d'avoir justement souligné dans sa thèse qu'il s'y ajoute une police législative. Elle est même primordiale car c'est au législateur seul que les auteurs de la Déclaration de 1789 accordaient le droit de poser les limites nécessaires aux libertés. Ainsi le code pénal ou l'interdiction législative de fumer dans les lieux publics contribue à l'ordre public en assurant respectivement la sécurité et la salubrité publiques. Les polices législative, administrative et judiciaire sont mises en oeuvre par des actes de nature juridique différente et soumis en conséquence à des régimes différents. Ces régimes peuvent d'ailleurs ne pas présenter de spécificité par rapport aux actes de même nature non rattachables à la fonction de police : par exemple, le régime d'une loi ne varie guère selon qu'elle est inspirée ou non par des préoccupations de police.

La diversité de la police se manifeste, en second lieu, au sein même de la seule police administrative. Celle-ci est doublement plurielle parce qu'il faut non seulement y distinguer la police administrative générale des polices administratives spéciales mais aussi, au sein de ces dernières, un très grand nombre de polices. Elles sont apparues progressivement au fur et à mesure de la prise de conscience de l'incapacité de la police administrative générale à assurer au mieux l'exercice des libertés. Cette impuissance peut d'abord résulter de l'insuffisance des procédés susceptibles d'être mis en oeuvre dans le cadre de la police administrative générale. Celle-ci, en vertu de son inspiration libérale, peut seulement procéder à des interdictions et non soumettre des activités à une autorisation préalable. La création d'une police spéciale permet de surmonter cette incapacité. L'impuissance de la police administrative générale peut ensuite être structurelle, en ce sens qu'elle est liée à la limitation stricte des composantes de l'ordre public général. Celui-ci ne recouvre en principe que la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Or la recherche de l'état dans lequel les libertés s'exercent au mieux peut inciter à prendre en considération d'autres buts et donc à enrichir la composition de l'ordre public. Il est alors nécessaire de créer une police spéciale pour donner aux autorités publiques la compétence et les moyens de poursuivre ces buts nouveaux.

Ceci révèle alors la diversité de l'ordre public, par-delà son unité jusqu'ici affirmée.

## L'ORDRE PUBLIC

## L'unité

En définissant, comme nous le faisons ici, l'ordre public comme un état, celui dans lequel les libertés s'exercent au mieux, l'unité de la notion semble assurée. Une telle définition met en effet l'accent sur l'essence libérale de l'ordre public puisque celui-ci consiste, indépendamment des circonstances de temps et de lieux, à favoriser le meilleur exercice possible des libertés. Défini par sa finalité, l'ordre public présente ainsi une plasticité appréciable permettant de le faire évoluer au gré des circonstances. Il permet aussi bien d'organiser différemment des activités bruyantes selon qu'elles sont diurnes ou nocturnes, que d'accompagner des changements de régime politique ou les évolutions profondes qui affectent nécessairement une société sur une longue période.

Il faut cependant reconnaître que l'unité de l'ordre public repose largement sur la place centrale occupée par les composantes de l'ordre public général. Ce sont les trois composantes précédemment citées qui trouvent leur source dans le fameux article 97 de la loi municipale du 4 avril 1884. Aujourd'hui codifiée à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, cette disposition indique que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Il faut y lire qu'elle a pour objet d'assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Ces trois objectifs permettent aux autorités de police générale de soumettre un très grand nombre d'activités humaines à un encadrement, ce d'autant qu'ils donnent lieu chacun à une interprétation à la fois extensive et évolutive et que les moyens à mettre en oeuvre ne sont pas définis. Cette plasticité donne aux autorités de police générale et particulièrement aux maires la capacité de prévenir la plupart des menaces susceptibles de gêner la jouissance des libertés et ce, plus de 130 ans après le texte déterminant l'objet de leur pouvoir.

Pourtant, cela a été souligné, l'ordre public général peut parfois s'avérer impropre à justifier l'édiction d'une mesure de police administrative alors même qu'une considération d'intérêt général incite à encadrer une activité. La création d'une police administrative spéciale s'avère alors le moyen de fonder légalement l'intervention de la puissance publique pour retreindre les libertés.

J. Petit considère cependant que « le pullulement de polices spéciales [traduit], sur le plan juridique, le développement de l'interventionnisme public de direction des activités privées »(27), ce qui, selon lui, remet en cause l'inspiration initialement libérale de la police administrative. Il estime en conséquence impossible d'englober les polices administratives générale et spéciales au sein d'une définition unique fondée sur l'ordre public(28) dans la mesure où « nombre de polices spéciales visent des fins d'intérêt général très diverses, autres que celles de la police générale, et, partant, étrangères à l'ordre public »(29).

Il est indéniable que l'incidence des polices générale et spéciales sur l'exercice des libertés peut être sensiblement différente. La première se borne à restreindre les activités susceptibles d'empêcher la jouissance la plus large des libertés quand les secondes entendent souvent diriger les activités relevant de leur champ dans un sens supposé être le meilleur pour l'épanouissement des libertés. La mise en oeuvre d'un pouvoir de police spéciale peut donc effectivement relever d'une inspiration moins libérale.

Toutefois, diverses considérations incitent à persister à affirmer l'unité de l'ordre public. D'abord, ainsi que le reconnaît J. Petit, « les polices spéciales sont bien libérales en ce sens, très général, que l'État s'y borne à encadrer les activités sociales et non pas à les exercer lui-même »(30). Ensuite, bien des polices administratives spéciales visent des fins identiques à celles de l'ordre public général et n'ont été créées que pour permettre l'édiction de mesures échappant aux autorités de police générale. Tel est le cas, notamment des polices des cimetières, des édifices menaçant ruine, des débits de boisson etc. Enfin, s'il est exact que d'autres polices spéciales se singularisent par l'impossibilité de rattacher leur finalité soit à la sécurité, soit à la tranquillité, soit à la salubrité publiques, à l'instar des polices des étrangers, de la chasse ou de la publicité et de l'affichage, doit-on pour autant en conclure que ces finalités sont étrangères à l'ordre public ? Leur inclusion en son sein peut se prévaloir de la plasticité précédemment relevée de ce dernier. L'époque à laquelle s'est forgée la notion de police administrative générale était celle, d'inspiration nettement libérale, de l'État-gendarme. Mais l'apparition ultérieure et le développement de l'État-providence, qui se manifeste par un fort interventionnisme public, n'a pu que faire évoluer la conception initiale de l'ordre public. Celui-ci n'est peut-être plus tout à fait le même mais n'est-il pas toujours l'état dans lequel les libertés s'exercent au mieux ? Nous n'avons évidemment pas la même conception de cet état que les Français du milieu du XIX$^{e}$ siècle. Les modernes droits-créances ne sauraient être protégés par les mêmes procédés que les vieux droits-libertés. Mais, en tout état de cause, protéger les uns et les autres relève d'une même préoccupation.

De la même façon que le droit administratif est l'ombre de l'État éclairé par la lumière du siècle, selon le mot magnifique de J. Boulouis(31), la police est l'ombre des libertés, éclairées par la lumière du siècle.

C'est d'ailleurs la conjoncture actuelle qui a mis en lumière certains éléments de la diversité de l'ordre public.

## La diversité

Si l'unité de l'ordre public peut être contestée, c'est, semble-t-il, moins par le constat de l'infléchissement de son inspiration libérale que par celui d'une remise en cause exceptionnelle de ses liens avec les libertés. Cela se manifeste de deux façons, qui ne s'excluent d'ailleurs pas mutuellement.

Dans la présentation que nous en avons donnée précédemment, la police est la fonction qui tend à assurer l'ordre public, c'est-à-dire à assurer l'état dans lequel les libertés s'exercent au mieux. Cela signifie d'une part, que la police vise à prévenir les comportements de certains individus s'ils paraissent menacer la jouissance de leurs libertés par d'autres et d'autre part, que l'ordre public est extérieur aux droits et libertés dont il est l'instrument de garantie. À ces deux égards, l'époque contemporaine a marqué une rupture significative.

En premier lieu, le juge administratif a admis la légalité de mesures de police tendant soit à interdire des comportements non nuisibles aux tiers, soit à contraindre à des comportements bénéfiques à leur seul auteur. Ces deux hypothèses sont pourtant étrangères à notre régime d'exercice des libertés tel qu'exprimé par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme : le premier pose que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », le second que « la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». L'inspiration libérale de notre régime des libertés n'aurait pas dû conduire à tolérer des mesures de police tendant à encadrer des activités ne portant préjudice qu'à leurs auteurs et non aux tiers ou, plus

largement, à la société. Tel est bien pourtant ce qui ressort de l'obligation du port de la ceinture de sécurité pour les automobilistes(32) ou de prise en charge des sans-abris par temps de grand froid(33). Leur absence n'est en aucun cas susceptible de nuire à des tiers, du moins directement. Tout au plus est-il possible de faire valoir que la société peut en pâtir indirectement par le coût social des conséquences dommageables d'une abstention. Mais cette considération ne saurait justifier que des mesures de police soient prises pour protéger les individus contre eux-mêmes : beaucoup d'activités non nuisibles directement aux tiers ou à la société peuvent en effet l'être indirectement ; admettre que ces conséquences indirectes puissent être le fondement de mesures de police ayant avant tout pour objet immédiat de protéger les individus contre eux-mêmes infléchirait regrettablement la logique libérale de notre système de libertés. En réalité, ce n'est que lorsque la sécurité des personnes en cause était gravement mise en danger que de telles mesures ont été jusqu'alors tolérées.

L'affaire à l'origine de l'arrêt *Commune de Morsang-sur-Orge*, dans laquelle une mesure de police a privé une personne de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle compte-tenu de la nature attentatoire à la dignité humaine de celle-ci, a néanmoins constitué une exception. Cette affaire hors-normes n'a pas seulement marqué un élargissement des hypothèses dans lesquelles la fonction de police peut être mise en oeuvre pour encadrer des activités nuisant avant tout à leur auteur. Elle a également marqué une autre rupture dans les rapports entre ordre public et libertés.

Comme chacun le sait, l'arrêt *Commune de Morsang-sur-Orge*, dont ce colloque examine la portée vingt ans après qu'il a été rendu, a surtout retenu l'attention en ce qu'il a admis qu'une mesure de police soit fondée sur la protection de la dignité de la personne humaine.

Il convient de prendre conscience de l'incidence de cette solution sur les notions d'ordre public et de police. Pour le comprendre, il faut préalablement revenir sur la question de la moralité publique comme motif d'exercice du pouvoir de police, c'est-à-dire comme composante de l'ordre public.

Dans la conception classique, l'ordre public, que la police tend à maintenir pour que les libertés puissent s'exercer au mieux, est un ordre « matériel et extérieur ». Cette formule bien connue d'Hauriou(34) signifie que l'ordre public est un ordre « physique », « dans la rue » comme il l'exprimait également(35). En conséquence, la police « ne poursuit pas l'ordre moral dans les idées et dans les sentiments, elle ne pourchasse pas les désordres moraux, elle est pour cela radicalement incompétente »(36). Cette conception avait été auparavant exprimée par J.-H.-N. de Fooz, à une époque où pourtant la chose semblait politiquement moins assurée. Dans son ouvrage de droit administratif belge paru en 1859, il affirmait que les lois positives « sont sans action sur les consciences : *De internis non curat praetor* » et que « les actes internes ne sont pas du ressort de la justice humaine ; celle-ci n'a pas le droit de punir le mal purement moral, parce qu'il est sans influence directe sur le bien commun de la société : *Cogitationis poenam nemo patitur* ».

Sur deux siècles de jurisprudence, il est certes possible de citer quelques affaires dans lesquelles la moralité publique, voire la morale, ont servi de fondement légal à des mesures de police administrative(37). Cependant, outre que leur nombre est assez réduit, ils sont pour la plupart relativement anciens et surtout se rapportent le plus souvent à des hypothèses relevant de polices spéciales telles que celles du cinéma, des

débits de boissons, des jeux ou de la presse. Comme le relève J. Petit, « le juge administratif ne [fait] qu'un usage très parcimonieux des solutions considérées, dont la portée pratique demeure, ainsi, limitée »(38). Il est alors possible de considérer que la moralité publique n'est admise comme composante complémentaire de l'ordre public que lorsqu'est en cause, selon les mots toujours cités de P.-H. Teitgen, ce « minimum d'idées morales naturellement admises à une époque donnée, par la moyenne des individus »(39). En bref, elle ne reposerait pas sur une intrusion dans les consciences individuelles mais constituerait une donnée quasi-objective, sinon matérielle du moins extérieure dans le vocabulaire d'Hauriou.

En tout état de cause, la moralité publique n'est pas un droit ou une liberté. L'admettre au nombre des composantes de l'ordre public peut sans doute être considéré comme une atteinte à l'inspiration libérale de notre système d'exercice des libertés mais ne remet pas en cause l'organisation des rapports entre l'ordre public et les libertés.

Il en va autrement avec la dignité humaine que l'arrêt *Commune de Morsang-sur-Orge* a également ajoutée à la liste des composantes de l'ordre public, en la distinguant de la moralité publique. Sans qu'il soit ici question ni de l'opportunité de cette solution ni de la maîtrise de sa portée sur laquelle des affaires ultérieures ont conduit à d'intenses débats, il importe de souligner la rupture avec la logique classique de l'ordre public qu'elle a impliquée.

Comme l'a montré J. Petit(40), la dignité de la personne humaine ne saurait être analysée de la même manière que les autres composantes de l'ordre public, qu'il s'agisse de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité voire de la moralité publiques. Ces dernières se présentent en effet comme des limites aux droits et libertés, à l'égard desquels elles sont extérieures. Les droits et libertés, pour s'exercer pleinement, ne doivent pas heurter l'une ou l'autre de ces composantes de l'ordre public. Celles-ci sont donc tout autant des limites que des moyens de garantie des droits et libertés.

Avec la dignité humaine, cette logique n'a plus cours puisqu'« un droit fondamental dont le respect peut être considéré comme une fin en soi est désormais compris dans l'ordre public »(41). La dignité humaine, droit fondamental, est en effet un motif autorisant les autorités de police à apporter des restrictions aux droits et libertés.

Il est vrai que la sécurité a été érigée, elle aussi, en droit fondamental par le législateur(42) et qu'une remarque similaire devrait dès lors prévaloir à son égard.

Or l'une et l'autre présentent une spécificité commune déjà relevée parmi les droits et libertés : le juge administratif considère que, dans certaines circonstances extrêmes, les individus ne sont plus libres de renoncer à leur bénéfice, comme il en va en principe de tout droit ou liberté, et peuvent au contraire s'en voir imposer le respect au nom de l'ordre public.

Cela laisse entrevoir une distinction au sein de l'ordre public. Certaines de ses composantes - la tranquillité et la salubrité publiques - ne justifieraient que des mesures de protection contre des atteintes émanant de tiers. Les autres - la sécurité et la dignité - seraient à ce point fondamentales qu'elles justifieraient jusqu'à

l'interdiction faite à leurs titulaires d'y renoncer.

Les autorités de police contemporaines sont ainsi désormais parfois amenées à lutter contre des abus des droits et libertés compromettant les droits et libertés de leurs auteurs eux-mêmes.

Décidément, la police est bien l'ombre des libertés éclairées par la lumière du siècle.

(1) Dans son numéro 5/2015, la RFDA a publié la première partie d'un colloque intitulé « Les vingt ans de l'arrêt *Commune de Morsang-sur-Orge* - À propos de la dignité de la personne humaine » qui comporte, outre cet article, les contributions suivantes :
- l'article de Guillaume Glénard, La dignité de la personne humaine : un ordre de valeurs ?, p. 869 ;
- l'article de Thibaut Leleu, La dignité de la personne humaine comme fondement des mesures de police administrative, p. 883 ;
- l'article de Pierre Delvolvé, L'ordre public immatériel, p. 890.

(2) S.1898.III.145.

(3) E. Picard, *La notion de police administrative*, BDP T. 146, (2 vol.), LGDJ 1984.

(4) J. Petit, *La police administrative, in Traité de droit administratif*, P. Gonod, F. Melleray, Ph. Yolka (sous dir.), Dalloz 2011, T. II, p. 6.

(5) J. Petit, « Art. 15 - La police », *in La Constitution administrative de la France*, J.-J. Bienvenu, J. Petit, B. Plessix, B. Seiller (sous dir.), Coll. Thèmes et commentaires, Dalloz 2012, p. 227.

(6) *La police administrative*, Ch. Vautrot-Schwarz (sous dir.), coll. Thémis - Essais, PUF, 2014.

(7) J.-M. de Gerando, *Institutes du droit administratif français, ou Élémens du code administratif*, T. 3, Nève, 1830, p. 328.

(8) R. Chapus, *Droit administratif général*, T. 1, 15e éd., Précis Domat, Montchrestien, 2001, n° 901.

(9) P.-L. Frier et J. Petit, *Précis de droit administratif*, 9e éd., Précis Domat, Montchrestien, 2014, n° 464.

(10) P. Chrétien, N. Chifflot, M. Tourbe, *Droit administratif*, coll. Sirey université, 14e éd., Sirey 2014, n° 669.

(11) D. Truchet, *Droit administratif*, coll. Thémis droit, PUF, 5e éd. 2013, p. 306.

(12) B. Stirn, Y. Aguila, *Droit public français et européen*, coll. Amphi, Presses de Sciences Po et D. 2014. 364.

(13) Y. Gaudemet, *Droit administratif*, coll. Manuel, 20e éd., LGDJ 2012, n° 737.

(14) L. Corneille, concl. sur CE, 10 août 1917, n° 59855, *Baldy*, Lebon p. 637.

(15) *Ibid.*

(16) F.-P. Bénoit, *Le droit administratif français*, Dalloz 1968, n° 1371.

(17) Fénelon, *Examen de conscience sur les devoirs de la royauté*, Didot, 1838, p. 351. Charles Péguy affirmait quant à lui : « L'ordre, et l'ordre seul, fait la liberté. Le désordre fait la servitude. Seul est légitime l'ordre de la liberté ».

(18) J.-H.-N. de Fooz, *Le droit administratif belge*, Casterman, 1859-1866, t. 3, p. 7, note 6. V. en annexes, outre une notice biographique de l'auteur, quelques extraits de cet ouvrage consacrés à la police administrative.

(19) *Ibid.*, p. 8.

(20) *Ibid.*, p. 9.

(21) E. Picard, *V°* Police, *in Dictionnaire de culture juridique*, D. Alland, S. Rials (sous dir.), Lamy-PUF, coll. Quadrige-dicos poche, 2003.

(22) E. Picard, « L'influence du droit communautaire sur la notion d'ordre public », AJDA 1996. 55.

(23) J.-H.-N. de Fooz, préc., p. 6.

(24) CE, sect., 11 mai 1951, *Consorts Baud,* Lebon p. 265 ; S. 1952.III.13, concl. Delvolvé ; T. confl., 7 juin 1951, *Dame Noualek,* Lebon p. 636 ; S. 1952.III.13, concl. Delvolvé.

(25) J.-H.-N. de Fooz, préc., p. 16.

(26) T. confl., 15 janv. 1968, n° 1909, *Consorts Tayeb*, Lebon p. 791.

(27) J. Petit, « La police administrative », *in Traité de droit administratif*, préc., p. 8.

(28) V. sa rédaction des deux premiers alinéas de l'article 15 de la Constitution administrative de la France, qui distingue les deux polices administratives : « La police administrative générale contribue à la protection de l'ordre public nécessaire à la garantie des libertés et de la propriété. Le législateur peut instituer des polices administratives

spéciales qui visent soit à concourir à la sauvegarde de l'ordre public, soit à satisfaire d'autres fins d'intérêt général » (J. Petit, « Art. 15 - La police », *in La Constitution administrative de la France*, préc., p. 227).
(29) *Ibid.*, p. 228.
(30) J. Petit, « La police administrative », *in Traité de droit administratif*, préc., p. 15.
(31) J. Boulouis, « Supprimer le droit administratif ? », *Pouvoirs* 1988, n° 46, p. 12.
(32) CE, 4 juin 1975, n° 92161, *Bouvet de la Maisonneuve et Millet*, Lebon p. 330.
(33) CAA Paris, 6 déc. 2004, *Association Droit au logement Paris et environs*, AJDA 2005. 341.
(34) M. Hauriou, *Précis de droit administratif*, 10e éd., 1921, p. 471.
(35) *Ibid.*
(36) *Ibid.*
(37) V. par ex., E. Picard, *La notion de police administrative*, préc., p. 216 s.
(38) J. Petit, « La police administrative », *in Traité de droit administratif*, préc., p. 13.
(39) P.-H. Teitgen, *La police municipale*, Sirey, 1934, p. 34.
(40) J. Petit, « La police administrative », *in Traité de droit administratif*, préc., p. 13.
(41) *Ibid.*
(42) Loi du 21 janv. 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

## **Document n° 7 : O. RENAUDIE, « Police administrative et ordre public : les notions plastiques, est-ce si fantastique ? », *AJDA* 2024, p. 774**

Récemment, le Premier ministre, Gabriel Attal, a pu déclarer que « vivre paisiblement est un droit, peut-être le plus important de tous » (Le Parisien, 11 févr. 2024). Si une telle affirmation peut laisser perplexe le juriste, elle lui fait spontanément penser à la police administrative, susceptible d'être considérée comme le principal instrument permettant d'assurer cette vie paisible à laquelle aspire la population. Généralement définie comme l'activité ayant pour objet le maintien de l'ordre public, la police administrative possède deux caractéristiques principales. .

La première caractéristique est son libéralisme, à la fois matériel et territorial. Sur le plan matériel, ce libéralisme se traduit de deux manières. D'un côté, le maintien de l'ordre public est considéré comme consubstantiel à la liberté (sur la dimension libérale de la police administrative, J. Petit, La police administrative, *in* P. Gonod, F. Melleray et P. Yolka [dir.], *Traité de droit administratif*, Dalloz, t 1, 2011, p. 7-9 ; E. Picard, *La notion de police administrative*, LGDJ, Bibl. Dr. publ., t 2, 1984, p. 534 et s.). C'est ce qu'exprime l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux termes duquel « la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique [...] » (S. Slama et L. Vanier, Le réveil de la force publique. A propos de l'article 12 de la Déclaration de 1789, AJDA 2022. 1138). De l'autre, les restrictions aux libertés apportées par les mesures de police administrative doivent être tout à la fois exceptionnelles et limitées. On connaît la formule classique, selon laquelle « la liberté est la règle et la restriction de police, l'exception » (concl. Corneille sur CE 10 août 1917, n° 59855, *Baldy*, Lebon 638). C'est un fait qu'il résulte d'une jurisprudence constante que les pouvoirs de police administrative varient avec la nécessité, plus ou moins grande selon les circonstances de temps et de lieu, d'assurer le maintien de l'ordre public. Au-delà de cette dimension matérielle, les restrictions aux libertés apportées par les mesures de police administrative doivent être limitées dans l'espace. En ce sens, les arrêtés municipaux de police, applicables sur un territoire aussi restreint que celui d'une commune, apportent aux libertés des restrictions

par essence mesurées .

La seconde caractéristique est son différencialisme (sur les distinctions relatives à la police administrative, not., X. Prétot et C. Zacharie, *La police administrative*, LGDJ, 2018, P. 21 et s.). En raison de sa finalité, le maintien de l'ordre public, la police administrative se différencie de deux autres fonctions. D'une part, elle doit être distinguée du service public (F. Rolin, Service public et police administrative, *in* AFDA, *Le service public*, Dalloz, 2014, p. 211-223). La distinction entre la police administrative et le service public renvoie à la *summa divisio* de l'action administrative. La grande majorité des auteurs s'accordent en effet pour affirmer que cette dernière se divise en deux grandes branches : d'un côté, la police administrative, par le biais de laquelle est réglementée l'activité des particuliers dans le but de prévenir ou de faire cesser d'éventuels troubles à l'ordre public ; de l'autre, le service public, par le biais duquel sont accordées aux particuliers des prestations correspondant à la satisfaction des besoins d'intérêt général. D'autre part, elle doit être distinguée de la police judiciaire (J. Moreau, Police et séparation des autorités administrative et judiciaire, *in* C. Vautrot-Schwarz [dir.], *La police administrative*, PUF, 2014, p. 24-37 ; R. Parizot, La distinction entre police administrative et police judiciaire est-elle dépassée ?, *in* M. Touillier [dir.], *Le code de la sécurité intérieure, artisan d'un nouvel ordre ou semeur de désordre ?*, Dalloz, 2017, p. 133-142). Cette distinction est issue de la Révolution française, en particulier de la loi des 16-24 août 1790. Plus précisément, c'est le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (24 oct. 1795) qui a formalisé cette distinction classique : « la police administrative a pour objet le maintien habituel de l'ordre public en chaque lieu. Elle tend principalement à prévenir les délits » (Art. 19) ; « la police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir » (Art. 20) .

L'évocation de ces caractéristiques traditionnelles pourrait laisser penser que le régime de la police administrative est marqué par la simplicité et la stabilité. Ce n'est pas le cas ; celle-ci connaît aujourd'hui une certaine effervescence. D'abord, la police administrative a été placée au coeur de la gestion par les pouvoirs publics de la crise de la covid-19. Dans un premier temps, elle a pu être utilisée par l'Etat pour réagir en urgence à une situation exceptionnelle. Les premières mesures ont été édictées par le ministre de la santé, sur le fondement de la police spéciale de l'urgence sanitaire (CSP, art. L. 3131-1), puis par le Premier ministre, sur celui de son pouvoir de police générale (CE 8 août 1919, n° 56377, *Labonne*, Lebon 737 ;CE, ass., 13 mai 1960, *SARL Restaurant Nicolas*, Lebon 324). Dans un second temps, les pouvoirs publics ont pu estimer que le droit commun de la police administrative n'était pas suffisant pour endiguer la crise du coronavirus. C'est la raison pour laquelle la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a créé un régime dérogatoire, celui de l'état d'urgence sanitaire (J. Petit, L'état d'urgence sanitaire, AJDA 2020. 833) .

Ensuite, la police administrative a connu une frénésie législative. Quel est le point commun entre les lois du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, du 26 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation du droit de l'Union européenne, du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale en France, du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, du 24 janvier 2022 sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure et du 19 mai

2023 relative aux Jeux olympiques de 2024 (sur ce dernier texte, M.-A. Granger, Surveiller et contrôler. Les pouvoirs de police administrative de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques, AJDA 2023. 2222) ? Non seulement toutes contiennent des dispositions relatives à la police administrative, mais celles-ci la renforcent de manière substantielle en augmentant les prérogatives des autorités compétentes en la matière .

Enfin, la police administrative a fait l'objet d'un renouveau constitutionnel. D'un côté, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel portant sur des dispositions législatives relatives à cette police, par exemple celles sur les états d'urgence, terroriste ou sanitaire (not., Cons. const. 22 déc. 2015, nº 2015-527 QPC, AJDA 2015. 2463 ; D. 2016. 79, et les obs. ; *ibid*. 1461, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; RFDA 2016. 123, note A. Roblot-Troizier ; Constitutions 2015. 654, Décision ; *ibid*. 2016. 100, chron. L. Domingo ;Cons. const. 26 mars 2020, nº 2020-799 DC, *Loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19*, AJDA 2020. 839, note M. Verpeaux ; 839,note J. Jeanneney ; et 1257, tribune X. Magnon), ont permis d'édifier un régime constitutionnel de la police administrative. De l'autre, dans une décision du 15 octobre 2021, *Société Air France*, le Conseil constitutionnel a affirmé que « l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative [...] constitue un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France » (nº 2021-940 QPC, AJDA 2022. 172, note J. Petit ; D. 2022. 50, et les obs., note J. Roux). Sur le fond, cela a contribué à renforcer l'assise constitutionnelle de la police administrative. Sur la forme, cela a décuplé son importance. Il est remarquable que le premier principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ait été consacré dans le champ de la police administrative .

C'est dans ce contexte agité que s'inscrivent aujourd'hui les liens entre la police administrative et l'ordre public. Dès lors, il est permis de se demander si l'ordre public demeure la notion sans laquelle la police administrative ne peut être définie. Il y a certainement de multiples manières de répondre à cette interrogation, en particulier selon les sources, textuelles ou jurisprudentielles, que l'on mobilise. De notre point de vue, le caractère apodictique de l'union de ces deux notions mérite d'être (ré)interrogé ; si la relation entre police administrative et ordre public demeure exclusive, elle n'en est pas moins dépassée.

## I - Une relation exclusive

En principe, police administrative et ordre public entretiennent une relation exclusive : il est impossible de définir l'une sans recourir à l'autre(1). Pour autant, le contenu et la fonction de l'ordre public varient selon qu'il s'agit de la police administrative générale ou des polices administratives spéciales. Dans le premier cas, l'ordre public est une norme implicite d'habilitation ; dans le second cas, une norme formelle d'habilitation .

### A. L'ordre public, norme implicite d'habilitation de la police administrative générale

L'ordre public constitue le fondement sur lequel les autorités compétentes peuvent édicter des mesures de police administrative générale. On peut s'en convaincre en soulignant l'essence, puis les sens de cette affirmation .

L'essence de l'ordre public comme norme implicite d'habilitation (G. Tusseau, *Les normes d'habilitation*, Dalloz, 2006) de la police administrative générale revêt deux dimensions : d'une part, l'ordre public constitue une habilitation normative ; d'autre part, cette habilitation est implicite. Affirmer que l'ordre public constitue une norme d'habilitation de la police administrative générale signifie que celui-ci conditionne la nécessité des actes édictés (sur l'ordre public comme « norme de nécessité », E. Picard, *La notion de police administrative*, préc., p. 559). Les autorités titulaires de pouvoirs en la matière peuvent en faire usage et restreindre l'exercice des libertés à la seule condition de se fonder sur l'existence d'un trouble à l'ordre public, qu'elles entendent prévenir ou faire cesser. En conséquence, tout acte de police administrative générale fondé sur des considérations étrangères à l'ordre public est illégal (CE 19 févr. 1909, n° 27355, *Abbé Olivier*, Lebon 181 ; *GAJA*, n° 18). Tel est le cas par exemple d'un arrêté du préfet de police interdisant un concert alors qu'« il ne résulte pas des pièces du dossier [...] que [ledit concert] était de nature à menacer l'ordre public » (CE 7 juin 1939, *Association Travail et loisirs*, Lebon 376) .

Souligner le caractère implicite de cette habilitation normative renvoie à l'idée selon laquelle celle-ci n'est pas fondée sur un texte mais sur un « pouvoir propre ». Si un texte existe, comme c'est le cas pour le maire, ce dernier n'est pas pour autant limité dans son action et peut édicter toute mesure justifiée par les nécessités de l'ordre public, y compris celles qui n'étaient pas envisagées par le texte. Ainsi peut-il « prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients qu'un mode d'exercice de la profession de photographe peut présenter pour la circulation et l'ordre public » (CE, ass., 22 juin 1951, n° 00590, *Daudignac*, Lebon 362 ; *GAJA*, n° 58). La question s'est posée de savoir si, malgré le silence du texte constitutionnel, le Premier ministre disposait d'un pouvoir de police administrative générale justifié par les nécessités de l'ordre public national. Dans le droit fil des décisions du Conseil d'Etat (CE 8 août 1919, *Labonne*, préc. ; CE, ass., 13 mai 1960, *SARL Restaurant Nicolas*, préc.), le Conseil constitutionnel a pu estimer que « l'article 34 de la Constitution n' pas retiré au chef du gouvernement les attributions de police générale qu'il exerçait en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative » (Cons. const. 20 févr. 1987, n° 87-149 L, RD publ. 1987. 399, note L. Favoreu).

Les sens de l'ordre public comme norme implicite d'habilitation de la police administrative générale ne sont pas faciles à identifier tant il s'agit du « type même de standard, de notion à texture ouverte, variable et contingente » (B. Plessix, *Droit administratif général*, LexisNexis, 4e éd., 2022, P. 893 ; égal., P. Bernard, *La notion d'ordre public en droit administratif français*, LGDJ, Bibl. Dr. publ., 1962 ; C.-A. Dubreuil [dir.], *L'ordre public*, Cujas, 2013). Pour autant, l'usage, doctrinal et juridictionnel, veut que l'on s'appuie sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour en identifier le contenu. Selon celui-ci, l'ordre public général renvoie à une trilogie composée de quatre éléments. Comme l'écrit Benoit Plessix, « de tous les mythes perpétrés par la *doxa* du droit administratif, celui de la trilogie de l'ordre public général est probablement l'un des mieux ancrés et des plus significatifs » (préc., p. 895). Le premier élément est la sécurité publique, qui est relative à la prévention des risques d'accidents et de dommages aux personnes et aux biens. Le deuxième élément est la tranquillité publique (N. Wolff, *La tranquillité publique et les polices administratives*, thèse, Université Paris-I, 2008), qui concerne les troubles et nuisances affectant la qualité de vie, par exemple le bruit(2). Le troisième élément est la salubrité publique, qui renvoie à

l'hygiène et à la prévention des maladies et risques sanitaires. Au-delà de ces trois éléments, un quatrième, le bon ordre, apparaît plus indéterminé (sur le sujet, P. Delvolvé, L'ordre public immatériel, RFDA 2015. 890 ; B. Delaunay, Faut-il revoir la trilogie des buts de la police générale ?, JCP Adm. 2012, n° 2112). Tel qu'il a été interprété par le juge administratif, celui-ci possède une double dimension immatérielle. D'une part, il renvoie à la moralité publique (J.-M. Pontier, La moralité publique, AJDA 2022. 384). Il est possible, par exemple, pour un maire d'interdire la projection d'un film sur le territoire de sa commune « à raison du caractère immoral du film et de circonstances locales » (CE, sect., 18 déc. 1959, n° 36385, *Société « Les films Lutetia » et syndicat français des producteurs et Exportateurs de films*, Lebon 693 ; *GAJA*, n° 69). D'autre part, on peut y rattacher le respect de la dignité de la personne humaine (T. Leleu, La dignité humaine comme fondement des mesures de police administrative, RFDA 2015. 883 ; R. Schwartz, La dignité humaine, *in La scène juridique. Mélanges en l'honneur de Bernard Stirn*, Dalloz, 2019, p. 525-536). La police générale peut ainsi être mise en oeuvre pour prévenir ou faire cesser toute atteinte à la dignité de la personne humaine et ce, même en l'absence de circonstances locales particulières (CE, ass., 27 oct. 1995, n° 136727, *Commune de Morsang-sur-Orge*, Lebon 372 avec les concl. ; AJDA 1995. 942 ; 878, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux ; et 2014. 106, chron. M. Franc ; RFDA 1995. 1204, concl. P. Frydman ; *GAJA*, n° 85) .

### B. L'ordre public, norme formelle d'habilitation des polices administratives spéciales

Envisagé comme fondement des polices administratives spéciales (J. Petit, La police administrative, préc., P. 14-16 ; B. Plessix, *Droit administratif général*, préc., p. 899-900), l'ordre public apparaît différemment. S'il constitue toujours une norme d'habilitation, celle-ci doit être formalisée dans un texte spécifique. On peut s'en convaincre par quelques rappels d'ordre général et une illustration.

Les polices spéciales (M.-F. Delhoste, *Les polices spéciales et le principe d'indépendance des législations*, LGDJ, Bibl. Dr. publ., 2001 ; E. Picard, *La notion de police administrative*, préc., p. 310 et s.) peuvent être considérées comme telles à deux titres. D'un côté, elles sont instituées par un texte législatif spécifique, lequel détermine le titulaire de la compétence et l'étendue de ses pouvoirs selon les circonstances envisagées. Ainsi, la police spéciale de l'urgence sanitaire a été instituée par les lois du 9 août 2004 (L. n° 2004-806 relative à la politique de santé publique) et du 5 mars 2007 (L. n° 2007-294 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur) et figure aujourd'hui à l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. De l'autre, elles poursuivent un but particulier, qui prend la forme d'un élément - ou d'une combinaison d'éléments - de l'ordre public, que le législateur entend protéger spécifiquement en raison de son importance. Par exemple, la police spéciale des jeux d'argent et de hasard a pour objet la prévention du jeu excessif ou pathologique, la protection des mineurs et la prévention des activités frauduleuses ou criminelles (CSI, art. L. 320-3).

Depuis quelques années, ces polices spéciales se multiplient (J.-M. Pontier, La multiplication des polices administratives spéciales : pourquoi ?, JCP Adm. 2012, n° 2113), ce qui pose plusieurs questions. La première porte sur les motifs de ce développement. Deux raisons sont généralement avancées. D'une part, certains domaines de l'action publique sont marqués par un haut degré de technicité et, en ces matières, il semble difficile de laisser l'édiction de mesures restrictives de l'exercice des libertés à la seule appréciation

des préfets et des maires. D'autre part, des risques nouveaux apparaissent et les pouvoirs publics cherchent à mieux protéger ceux qui pourraient y être confrontés ; « cela conduit nécessairement à l'édiction de nouvelles normes mais aussi, de ce fait, à prévoir des sanctions administratives, des mécanismes d'autorisation, qui relèvent de la police et, presque obligatoirement, de la police spéciale » (J.-M. Pontier, préc.) .

La seconde question concerne les relations entre police générale et police spéciale (J.-B. Guyonnet, Police générale - police spéciale : une crise sans fin ?, *in* X. Dupré de Boulois [dir.], *Les classifications en droit administratif*, Mare et Martin, 2021, p. 131-150). Sur le sujet, il convient de rappeler que la police administrative générale est par essence subsidiaire (E. Picard, *La notion de police administrative*, préc., p. 645 et s.). Elle l'est vis-à-vis de l'exercice des libertés. Elle l'est également vis-à-vis du législateur. Ce dernier est en effet l'autorité par principe compétente pour restreindre l'exercice des libertés publiques (sur le fondement de l'article 34 de la Constitution), principalement en créant des polices spéciales. Dès lors, il reste à la police générale le soin de pourvoir aux situations n'ayant pas été envisagées par le législateur. On peut donc affirmer que la police législative formalisant un ordre public spécial est le principe, et la police fondée sur la norme implicite d'habilitation que constitue l'ordre public, l'exception. D'une certaine manière, c'est ce que traduit le principe d'exclusivité de la police spéciale applicable, sauf rares exceptions, aux hypothèses de concours de police (H. Hoepffner et L. Janicot, Police locale *versus* police spéciale : l'exclusivité de la police administrative spéciale des communications électroniques, RD publ. 2012. 1245) .

Pour illustrer la manière dont le législateur fait usage de la notion d'ordre public par le biais des polices administratives spéciales, on peut prendre l'exemple de la police des armes et des munitions (M. Burg, *Droit des armes*, LegiTech éd., 2020 ; M.-A. Granger, Classicisme et renouveau de la police administrative des armes, *in* P. Mbongo et X. Latour [dir.], *Sécurité, libertés et légistiques. Autour du Code de la sécurité intérieure*, L'Harmattan, 2012, p. 167-189). Sous l'impulsion de l'Union européenne(3), cette police a fait l'objet d'un renouveau par les lois n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, qui ont établi un nouveau classement des armes. Ce classement comprend quatre catégories (CSI, art. L. 311-2) : les armes de catégorie A, qui ne peuvent être acquises ou détenues ; celles de catégorie B, dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation ; celles de catégorie C, dont l'acquisition et la détention sont soumises à une simple déclaration ; celles de catégorie D, dispensées de formalité quelconque. Comme le précise l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), « en vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu [...] est fondé sur la dangerosité des matériels de guerre et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme ». C'est donc bien l'ordre public qui est le but de cette police spéciale, plus précisément la protection des personnes face aux dangers de l'usage des armes à feu (en ce sens, CE 12 févr. 2020, n° 434356, *Société Redcore*, AJDA 2020. 1863, note M. Burg).

## II - Une relation dépassée

En dépit de son caractère principiel, la relation entre police administrative et ordre public apparaît aujourd'hui dépassée. D'une part, l'ordre public peut être contesté comme fondement unitaire de la police administrative. D'autre part, il est souhaitable de refonder la police administrative sur une autre notion, la sécurité .

### A. La contestation de l'ordre public comme fondement unitaire de la police administrative

Aussi plastique soit-il, l'ordre public apparaît aujourd'hui comme l'un de ces « grands référentiels doctrinaux en cours d'épuisement » (J. Caillosse, A propos de doctrine en droit administratif, AJDA 2012. 1618). En effet, il semble de plus en plus difficile de le considérer comme la notion sans laquelle la police administrative ne saurait être définie. Cela vaut aussi bien pour la police générale que pour les polices spéciales .

S'agissant de la police administrative générale, le problème tient à ce que l'ordre public ne permet pas de distinguer clairement celle-ci du service public. D'un côté, affirmer que la police aurait pour objet le maintien de l'ordre public alors que le service public viserait l'intérêt général apparaît relativement tautologique. Par ailleurs, si cette proposition sous-entend que la police ne vise pas une dimension de l'intérêt général, l'on passe de la tautologie à l'inexactitude. De l'autre, considérer que le critère de distinction entre ces deux branches de l'action administrative est celui des procédés utilisés pose question. On connaît la formule du doyen Vedel, selon laquelle « la réglementation de police opère par voie de prescriptions ; le service public opère par voie de prestations » (Les bases constitutionnelles du droit administratif, EDCE 1954. 24). Ce critère a fait l'objet de nombreuses critiques dans la mesure où, d'une part, la police peut fournir des prestations et, d'autre part, le service public « ne peut fonctionner sans un minimum de prescriptions » (J. Petit, La police administrative, préc., p. 22). Face aux critiques, ce critère a pu être affiné. L'on a pu ainsi montrer que lorsque la police offre une prestation, elle ne le fait pas pour servir les intérêts d'un droit subjectif mais cherche à protéger l'ordre public, c'est-à-dire, au fond, l'ensemble de la collectivité. Comme le souligne Etienne Picard, « lorsque la police offre une prestation, elle ne le fait pas pour servir les intérêts d'un droit subjectif. Elle cherche seulement à protéger un ordre statutaire dont l'un des éléments [...] est menacé ; elle se préoccupe d'une situation objective d'atteinte à l'ordre institutionnel dans laquelle un droit subjectif est suffisamment compromis pour que cette situation l'incite à intervenir » (*La notion de police administrative*, préc., p. 787). Même affiné de la sorte, ce critère apparaît parfois délicat à mettre en oeuvre. Tel est le cas par exemple en matière de santé : les soins sans consentement sont-ils une mesure sanitaire ou policière ? Les vaccinations sont-elles des prestations offertes à des patients ou des mesures de protection contre les épidémies ?

S'agissant des polices administratives spéciales, deux éléments peuvent être relevés. Le premier élément est classique et renvoie à l'idée selon laquelle il n'existe pas à proprement parler d'ordres publics spéciaux (C. Fardet, Existe-t-il des ordres publics spéciaux ?, *in* C. Vautrot-Schwarz [dir.], *La police administrative*, préc., p. 121-137). Comme a pu le souligner Jacques Petit, « nombre de polices visent des fins d'intérêt général très diverses, autres que celles de la police générale et, partant, étrangères à l'ordre public » (Article 15, *in*

J.-J. Bienvenu, J. Petit, B. Plessix et B. Seiller [dir.], *La Constitution administrative de la France*, Dalloz, 2012, p. 228). Ainsi, la police spéciale de la chasse tend à la « gestion durable du patrimoine faunique » (C. envir., art. L. 420-1) .

Le second élément est plus contemporain ; il tient au « verdissement » d'un certain nombre de polices administratives spéciales. Il ne s'agit pas ici de relever le nombre important de polices spéciales dans le domaine environnemental (O. Renaudie, Polices et environnement, *in* L. Janicot [dir.], *Les collectivités territoriales et la protection de l'environnement*, Berger-Levrault, 2021), mais de souligner l'évolution de certaines polices spéciales classiques très marquées par le maintien de l'ordre public vers la protection de l'environnement. En ce sens, on peut prendre l'exemple de la police de la circulation, qui figure parmi les polices administratives spéciales les plus anciennes, dont le but originel est la sécurité des voies publiques (P. Bon, *La police de la circulation et du stationnement*, Sirey, 1981 ; du même auteur, Police de la circulation et du stationnement, Encycl. Coll. loc., n° 2255). Comme a pu le relever le Conseil d'Etat dans une décision célèbre, « le décret du 10 mars 1899, à raison des dangers que présente la locomotion automobile, a pu valablement exiger que tout conducteur d'automobile fût porteur d'une autorisation de conduite, délivrée sous la forme d'un certificat de capacité » (CE 8 août 1919, *Labonne*, préc.). Aujourd'hui, il est possible d'affirmer que celle-ci est « au service de l'environnement » (M. Moliner-Dubost, La police de la circulation au service de l'environnement, AJCT 2019. 382) .

Cette évolution s'est faite en deux temps. Dans un premier temps, on a inséré dans le code de l'environnement des dispositions visant à protéger certains espaces naturels. Dans un second temps, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM, art. 35) a modifié la rédaction de l'article L. 2213-2 du CGCT. Elle a ajouté qu'au-delà des nécessités de la circulation, le maire pouvait faire usage de la police de la circulation « eu égard à la protection de l'environnement ». Cette modification est loin d'être anodine. D'abord, elle traduit une hybridation de la police de la circulation ; tournée à l'origine vers la seule sécurité des voies publiques, celle-ci est aujourd'hui imprégnée par des considérations environnementales. Ensuite, celle-ci donne un fondement clair aux décisions des maires ayant pour objet d'interdire la circulation sur certaines voies, afin de les rendre piétonnes, non pour des raisons liées à la sécurité de la circulation mais pour des motifs liés à la lutte contre la pollution atmosphérique et à la santé environnementale (S. Brimo, *La santé environnementale. Une approche juridique*, Dalloz, 2023). Enfin, elle témoigne d'un phénomène remarquable : alors que certaines polices spéciales avaient pour finalité exclusive le maintien de l'ordre public, elles sortent aujourd'hui du giron de celui-ci. Ici, on touche du doigt les limites de la plasticité de l'ordre public .

### B. La refondation de la police administrative sur la sécurité

Si la notion d'ordre public n'apparaît plus en mesure de fonder la police administrative, il convient de lui trouver un substitut dynamique. Ce dernier n'est pas à chercher bien loin : la sécurité peut être celui-ci (sur les rapports complexes entre ordre public et sécurité, J. Moreau, La notion de sécurité en droit français, Rev. pol. nat. 1977, p. 5-12). On peut s'en convaincre en voyant dans quelle mesure cette notion s'est récemment imposée, puis en comparant ses mérites avec les défauts de la notion d'ordre public.

Depuis quelques années, la sécurité a connu une montée en puissance remarquable. Sur le plan sociologique, une rupture a eu lieu vers la fin des années 1970 avec l'apparition de ce que l'on a appelé le sentiment d'insécurité (H. Lagrange, Perceptions de la violence et sentiment d'insécurité, Déviance et Société 1984, n° 4, p. 321-344 ; S. Roché, *Le sentiment d'insécurité*, PUF, 1993). Désormais, il ne s'agit plus de répondre à une délinquance objective, mais également à une insécurité ressentie. La prise en compte de cette insécurité ressentie a obligé les pouvoirs publics à se situer par rapport à une demande sociale et à répondre aux attentes des citoyens. Il en a découlé une remise en cause du modèle policier traditionnel fondé sur le maintien de l'ordre public pour le faire évoluer vers une meilleure protection des personnes et des biens. On est ainsi passé d'une logique d'ordre à une logique de sécurité. Sur le plan juridique, cela s'est traduit par la création de nouvelles incriminations pénales (par ex., J. Alix, *Terrorisme et droit pénal. Etude critique des incriminations terroristes*, Dalloz, 2010) et la multiplication des polices administratives spéciales (en ce sens, J.-M. Pontier, La multiplication des polices spéciales : pourquoi ?, art. préc.), mais également par la reconnaissance d'un droit à la sécurité (X. Dupré de Boulois, Existe-t-il un droit fondamental à la sécurité ?, RDLF 2018, chron. n° 13 ; M.-A. Granger, Existe-t-il un « droit fondamental à la sécurité » ?, RSC 2009. 273) .

Comme le précise le premier article du code de la sécurité intérieure, « la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions d'exercice des libertés individuelles et collectives ». C'est la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui l'a consacré en ces termes. La manière dont ce droit a été formalisé appelle deux brèves observations. La première observation concerne la place de l'Etat dans la mise en oeuvre de ce droit. Si la sécurité est consacrée comme un droit, le même article législatif (CSI, art. L. 111-1) affirme, en miroir, que « l'Etat a le devoir d'assurer la sécurité [...] sur l'ensemble du territoire de la République ». Autrement dit, il y aurait, d'un côté, un droit-créance et, de l'autre, un débiteur de cette créance. La seconde observation est relative au caractère fondamental de ce droit. On le sait, l'expression « droit fondamental » renvoie aux droits dont la valeur est supra-législative, c'est-à-dire susceptibles de s'imposer au législateur (en ce sens, X. Dupré de Boulois, *Droit des libertés fondamentales*, PUF, 4e éd., 2024, p. 38-40 ; M. Levinet, *Théorie générale des droits et libertés*, Bruylant, 2006, p. 62-64). Tel est le cas des droits consacrés par une norme constitutionnelle ou un traité international. Pour dire les choses simplement, ce n'est pas le cas du droit à la sécurité, consacré par une simple loi. Ainsi, sa valeur étant simplement législative, il ne peut être considéré comme fondamental au sens strict du terme (Cons. const. 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, *Loi sur la sécurité intérieure*, D. 2004. 1273, obs. S. Nicot ; RSC 2003. 614, obs. V. Bück ; et 616, obs. V. Bück) .

Sur le plan légistique, cette montée en puissance a pris la forme de l'élaboration d'un code de la sécurité intérieure (M. Bart et R. Decout-Paolini, Le code de la sécurité intérieure : genèse d'un outil, contours et traductions d'une notion, AJDA 2015. 84) par l'ordonnance(4) du12 mars 2012, dont l'objectif était de « rassembler les nombreuses normes législatives et réglementaires se rapportant à la sécurité intérieure dans un ouvrage unique » (rapport relatif à l'ordonnance n° 2012-531). Dans la manière dont celui-ci a été conçu, il est intéressant de constater que ce code contient un livre entier sur « Ordre et sécurité publics » et un autre relatif aux « Polices administratives spéciales », consacrant l'idée selon laquelle c'est désormais la sécurité

qui englobe l'ordre public, et non l'inverse .

Il faut tirer les conséquences de cette montée en puissance de la sécurité et remplacer l'ordre public par celle-ci pour appréhender la police administrative. Pourquoi passer d'un standard à l'autre ? Pour au moins trois raisons. La première raison tient à ce que la sécurité serait mieux à même de représenter toutes les dimensions de la police administrative, y compris celles qui sont les plus éloignées du maintien de l'ordre public. En effet, quelle que soit la police concernée, générale ou spéciale, il s'agit aujourd'hui d'assurer une fonction de protection contre des risques de toute nature et de mise à l'abri du danger (sur cette dimension protectrice, U. Beck, *La société du risque*, Flammarion, 2008 ; R. Sève, Avant-propos : la mesure de l'ordre public, Arch. Phil. dr., 2015, n° 58, p. 9-10). D'un côté, la sécurité peut concerner les personnes, les biens, l'environnement ou bien encore les pouvoirs publics. De l'autre, elle se décline facilement sous la forme d'un adjectif susceptible de lui être accolé : la sécurité peut être publique, sanitaire, civile, alimentaire, environnementale, énergétique, routière, etc.

La deuxième raison est que cela permettrait de lever l'ambigüité relative à la nature de la police administrative. D'une part, son objet, la sécurité, lui conférerait un but d'intérêt général. D'autre part, tournée vers la protection des personnes et des biens, elle serait considérée comme une activité de service public(5). Cela aurait pour vertu d'affirmer le caractère unitaire de l'action administrative, tout entière tournée vers la satisfaction de l'intérêt général. Cela conduirait, par ailleurs, à aborder autrement la délicate question de l'indélégabilité de la police administrative, dont le régime juridique apparaît aujourd'hui relativement illisible (O. Renaudie, Recherche sur l'indélégabilité de la police administrative : quand le Conseil constitutionnel s'écarte du Conseil d'Etat, *in* J. Bonnet *et al.* [dir.], *Droit constitutionnel et droit administratif. Entre unité et spécificités*, Mare et Martin, 2023, p. 51-61).

La troisième raison est d'ordre institutionnel. En l'état du droit, il y a une dissonance cognitive entre les dimensions fonctionnelle et organique de la police administrative. Dans ce domaine, force est de constater que le ministre de l'intérieur est un géant politique et un nain juridique. Alors qu'il est au coeur du dispositif institutionnel relatif à l'exercice de la police, il ne compte pas parmi les autorités de police administrative générale (X. Prétot et C. Zacharie, *La police administrative*, préc., p. 79-82). Cela s'explique en grande partie par les règles relatives à la distribution du pouvoir réglementaire sous la V$^{e}$ République (CE, sect., 23 mai 1969, n° 71782, *Société Distillerie Brabant et C$^{ie}$* , Lebon 264, concl. N. Questiaux ; à propos du ministre de l'intérieur, CE 10 juin 2021, n° 444849, *Syndicat national des journalistes*, Lebon 171 ; AJDA 2021. 1791, chron. C. Malverti et C. Beaufils ; et 1803, note X. Bioy). En substituant la sécurité à l'ordre public, cela permettrait de gagner en cohérence, le ministre de l'intérieur étant considéré comme celui qui « prépare et met en oeuvre la politique du gouvernement en matière de sécurité intérieure » (Décr. n° 2024-29 du 24 janv. 2024 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur et des outre-mer) .

En apparence, l'ordre public demeure la pierre angulaire de la police administrative. En réalité, la plasticité de cette notion dissimule mal un grand malaise : cette relation n'a plus de sens et est inadaptée aux évolutions législatives contemporaines sur le sujet. C'est pourquoi nous proposons de fonder la police administrative sur la notion de sécurité. Plus précisément, celle-ci pourrait être définie comme l'activité

d'intérêt général ayant pour objet la sécurité intérieure et visant en particulier la protection des personnes, des biens, de l'environnement, des institutions de la République et des intérêts fondamentaux de la Nation. Il nous semble que cette définition donne à voir ce qu'est vraiment la police administrative aujourd'hui. Reste que cette proposition n'est pas sans risque. Sur la forme, elle constitue une rupture avec l'un des récits classiques sur lesquels le droit administratif s'est construit. Sur le fond, cela pourrait laisser penser que la police administrative s'éloigne de son libéralisme fondateur. En la matière, on objectera qu'il en est ainsi depuis un certain temps et que la substitution suggérée est la conséquence et non la cause de cette évolution .

(1) « Il est en effet impossible de définir la fonction de police sans référence à l'ordre public. C'est pourquoi nous définirons la police comme la fonction qui tend à assurer l'ordre public, c'est-à-dire l'état dans lequel les libertés s'exercent au mieux. De cette façon, les liens qui unissent la police directement à l'ordre public et indirectement aux libertés apparaissent clairement » (B. Seiller, La notion de police administrative, RFDA 2015. 876) .

(2) Le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police générale, par exemple, pour prescrire la fermeture à 23h le samedi et à 22h les autres jours des bals publics en raison de l'atteinte portée à la tranquillité du voisinage (CE 17 juin 1970, n° 70079, *Combault*, Lebon 408) .

(3) Dir. 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes et Dir. (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes .

(4) Ord. n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure. Egal., décret n° 2013-1113 du 4 déc. 2013 relatif aux dispositions des livres I$^{er}$, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, ainsi que les décrets n° 2014-1252 et n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, relatifs aux dispositions des livres III, VI et VII et achevant la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure .

(5) Cela permettrait également de faire le lien avec la défense nationale, l'article L. 1111-1 du code de la défense précisant ainsi que « la politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale » .

# SEANCE N° 5 :
# LE REGIME DE LA POLICE ADMINISTRATIVE

Liste des documents :

- Document n° 1 : CC, 15 octobre 2021, *Société Air France*, Décision n° 2021-940 QPC.
- Document n° 2 : CE, 23 octobre 1959, *Sieur Doublet*, req. n° 40922.
- Document n° 3 : CE, 29 novembre 2022, n° 449749, *min. Intérieur c/ Sté Périgord Shooting club.*
- Document n° 4 : CE, 17 avril 2020, *Commune de Sceaux*, n° 440057.
- Document n° 5 : CE, 31 décembre 2020, *Commune d'Arcueil,* n° 439253.

Exercice : Cas pratique

*

## DOCUMENT N° 1 : CC, 15 octobre 2021, Société Air France, Décision n° 2021-940 QPC

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

**1.** La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 24 novembre 2004 mentionnée ci-dessus et du 1 ° de l'article L. 625-7 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 7 mars 2016 mentionnée ci-dessus.

**2.** L'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans cette rédaction, prévoit : « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ».

**3.** Le 1 ° de l'article L. 625-7 du même code, dans cette rédaction, prévoit qu'est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros : « L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ».

**4.** La société requérante reproche à ces dispositions d'obliger les entreprises de transport aérien à réacheminer les personnes étrangères auxquelles l'accès au territoire national a été refusé, le cas échéant en exerçant des contraintes sur celles dont le comportement présente un risque pour la sécurité à bord de l'aéronef. Ces dispositions auraient ainsi pour effet de déléguer à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique, en violation de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La société requérante reproche également à ces dispositions d'obliger ces entreprises à détenir contre leur gré, au cours de ce réacheminement, les personnes qui refuseraient de se soumettre à cette mesure, en méconnaissance de l'article 66 de la Constitution. En outre, ces dispositions permettraient d'engager la responsabilité des entreprises de transport quand bien même l'inexécution de cette obligation ne serait imputable qu'au comportement du passager. Elles méconnaîtraient ainsi l'article 9 de la Déclaration de 1789.

**5.** La société requérante soutient, par ailleurs, que ces dispositions, en imposant aux entreprises de transport de prendre en charge l'ensemble des coûts liés à l'obligation de réacheminement, les soumettraient à des sujétions excessives. Ce faisant, elles méconnaitraient l'article 13 de la Déclaration de 1789.

**6.** Enfin, ces dispositions, en ne prévoyant aucune exception à cette obligation de réacheminement, seraient entachées d'incompétence négative.

**7.** Ces griefs sont ainsi dirigés contre l'obligation de réacheminement mise à la charge des transporteurs aériens. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « est tenue de ramener » figurant à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

**8.** L'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers est fondée à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité dans la seule mesure où son intervention porte sur ces mêmes mots. Elle soutient, pour les mêmes raisons que la société requérante, que ces dispositions méconnaîtraient l'article 12 de la Déclaration de 1789.

**- Sur le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel :**

**9.** Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». La transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne. Dans cette hypothèse, il n'appartient qu'au juge de

l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive ou ce règlement des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

**10.** En application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les États signataires se sont engagés à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de « reprendre en charge sans délai » les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers. Cette obligation a été reprise et précisée par la directive du 28 juin 2001.

**11.** Les dispositions contestées de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent à assurer la transposition de cette directive en prévoyant que l'entreprise de transport aérien ou maritime est tenue de ramener une personne étrangère non ressortissante d'un État membre de l'Union européenne en cas de refus d'entrée sur le territoire national.

**12.** Ces dispositions se bornent ainsi à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 28 juin 2001.

**13.** Par conséquent, le Conseil constitutionnel n'est compétent pour contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit que dans la mesure où elles mettent en cause une règle ou un principe qui, ne trouvant pas de protection équivalente dans le droit de l'Union européenne, est inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

**- Sur le fond :**

**14.** En premier lieu, le droit à la sûreté, le principe de responsabilité personnelle et l'égalité devant les charges publiques, qui sont protégés par le droit de l'Union européenne, ne constituent pas des règles ou principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France. Il n'appartient donc pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur ces griefs.

**15.** En second lieu, selon l'article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits. Cette exigence constitue un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

**16.** La décision de mettre en œuvre le réacheminement d'une personne non admise sur le territoire français relève de la compétence exclusive des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière. En application des dispositions contestées, les entreprises de transport aérien ne sont tenues, à la requête de ces autorités, que de prendre en charge ces personnes et d'assurer leur transport.

**17.** Ainsi, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant des seules compétences des autorités de police. Elles ne privent pas non plus le commandant de bord de sa faculté de débarquer une personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre de l'aéronef, en application de l'article L. 6522-3 du code des transports.

**18.** Le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 12 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté. Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces mêmes exigences.

**19.** Par conséquent, les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution.

## DOCUMENT n° 2 : CE, 23 octobre 1959, *Sieur Doublet*, req. n° 40922

Requête du sieur Doublet Jacques, tendant à l'annulation du jugement en date du 1er février 1957, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le refus du maire de Saint-Jean-de-Monts Vendée , de prendre un arrêté règlementant l'usage d'un terrain de camping ; ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision du maire de Saint-Jean-de-Monts ; Vu les lois du 5 avril 1884 et du 21 juin 1898 ; les arrêtés préfectoraux des 6 mars 1951 et 1er juillet 1955 ; l'ordonnance du 31 juillet 1915 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la recevabilité des conclusions du sieur Doublet : Considérant que si, dans sa lettre du 14 juin 1955, le sieur Doublet avait demandé au maire de Saint-Jean-de-Monts d'user de ses pouvoirs de police pour interdire l'usage du terrain de camping de la rue des sports, en raison des très graves inconvénients que le rassemblement de campeurs au voisinage immédiat d'une partie de l'agglomération lui paraissait présenter pour l'hygiène et la sécurité des habitants, il ressort des pièces de la procédure de première instance que le maire a présenté au tribunal administratif des observations tendant au rejet au fond de la réclamation introduite par le requérant devant cette juridiction ; qu'ainsi le contentieux s'est trouvé lié sur les conclusions sus analysées de la demande du sieur Doublet, lesquelles sont, par suite, recevables ;

Sur le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Jean-de-Monts aurait eu l'obligation légale de réglementer par arrêté l'utilisation du terrain de camping de la rue des sports : Considérant que l'existence d'un arrêté du préfet de la Vendée du 6 mars 1951, modifie le 1er juillet 1955 et imposant certaines conditions à l'ouverture et à l'installation des terrains de camping, ne faisait pas obstacle à ce qu'un maire du département, usant des pouvoirs qu'il tient de l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884, édictât toutes les prescriptions supplémentaires que l'intérêt public pouvait commander x... sa localité ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que le maire de Saint-Jean-de-Monts n'était pas compétent pour prendre des dispositions complétant la règlementation générale instituée par le préfet ;

Mais considérant que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police a lui conférés par l'article 97 précité de la loi du 5 avril 1884 n'est entaché d'illégalité que dans le cas où à raison de la gravite du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnait ses obligations légales ;

Considérant que les prescriptions de l'arrêté préfectoral des 6 mars 1951, 1er juillet 1955 étaient, si l'exploitant du terrain de camping de la rue des sports s'y était conformé, suffisantes pour pallier les réels dangers que faisaient courir à l'hygiène et à la sécurité publiques les conditions dans lesquelles le camp dont s'agit fonctionnait ; que dès lors, s'il appartenait au sieur Doublet d'obtenir par toutes voies de droit que les prescriptions de cet arrêté préfectoral fussent respectées, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de prescrire par arrêté des mesures supplémentaires, qui n'étaient pas indispensables pour faire disparaitre un danger grave, le maire de Saint-Jean-de-Monts a excédé ses pouvoirs (…).

## **Document n° 3 : CE, 29 novembre 2022, n° 449749, *min. Intérieur c/ Sté Périgord Shooting club***

Vu la procédure suivante :

La société Périgord Shooting club, la société civile agricole et forestière du 87 et l'association Périgord Shooting club ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a suspendu à titre conservatoire l'activité de l'établissement de ball-trap " Périgord Shooting club " situé dans la commune de Servanches, et la décision du 8 septembre 2018 par laquelle le préfet a refusé de lever cette suspension, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de la réalisation d'une expertise acoustique. Par un jugement n° 17902983, 1703751 et 1704192 du 10 octobre 2018, le tribunal administratif a annulé cet arrêté du 29 juin 2017 du préfet de la Dordogne ainsi que sa décision de rejet du recours gracieux.

Par un arrêt n° 18BX04459 du 31 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 16 février 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités locales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Périgord Shooting club, de la société civile agricole et foncière du 87 et de l'association Périgord Shooting club.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 juin 2017 pris sur le

fondement du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet a suspendu à titre conservatoire l'activité de l'établissement de ball-trap permanent " Périgord Shooting Club " implanté sur le territoire de la commune de Servanches (Dordogne), aux motifs que l'activité de cet établissement générait des nuisances sonores, elles-mêmes à l'origine de troubles à l'ordre public, et que cette activité ne respectait pas certaines règles de sécurité prévues par le code du sport. Par un jugement du 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux, faisant droit à la demande présentée par la société Périgord Shooting Club, la société civile agricole et forestière du 87 et l'association Périgord Shooting Club, a annulé l'arrêté du 29 juin 2017 ainsi que de la décision du préfet du 8 septembre 2017 refusant de lever la mesure de suspension. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : /1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; / 2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ; / 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que les dispositions citées ci-dessus du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne confèrent aucune compétence au préfet de département pour prendre un arrêté de suspension des activités de l'établissement à l'origine de troubles à l'ordre public, en l'espèce des nuisances sonores et des manifestations de protestation en réaction à celles-ci, la cour s'est fondée sur ce que, dès lors que l'établissement ne disposait que d'installations situées dans la commune de Servanches, le champ d'application de la mesure n'excédait pas le territoire de cette commune. En jugeant ainsi que le champ d'application d'une mesure prise sur le fondement du 3° de l'article pour réglementer l'activité d'un établissement qui cause des troubles à l'ordre public s'apprécie au regard de l'objet de la mesure, en fonction de la localisation de l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, et non au regard des effets de la mesure, en fonction de la portée des troubles à l'ordre public auquel elle entend remédier, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, pour rejeter la demande de substitution de base légale présentée par le ministre, la cour administrative d'appel a jugé que les dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne sauraient davantage fonder la compétence du préfet pour prendre l'arrêté litigieux. Dès lors que ces dispositions ne confèrent de compétence au préfet que pour se substituer, dans l'exercice de certains pouvoirs de police, si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, aux maires de ces communes, et qu'il résultait de ses propres constatations que la mesure en cause, consistant en la suspension des activités de l'établissement à l'origine des troubles à l'ordre public situé sur le territoire d'une seule commune, ne relevait pas de la compétence des maires de deux ou plusieurs communes, la cour n'a commis aucune erreur de droit en se prononçant par ces motifs.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser tant à la société Périgord Shooting club qu'à l'association Périgord Shooting club et à la société civile agricole et forestière du 87, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Périgord Shooting Club, l'association Périgord Shooting club et à la société civile agricole et forestière du 87 une somme de 1 000 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Société Périgord Shooting club, première défenderesse dénommée.

## **Document n° 4 : CE, ordonnance n° 440057, 17 avril 2020, *Commune de Sceaux* (extraits)**

(…) Sur le cadre juridique :
3. D'une part, la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a introduit dans le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique un chapitre Ier bis relatif à l'état d'urgence sanitaire, comprenant les articles L. 3131-12 à L. 3131-20. Aux termes de l'article L. 3131-12 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire (...) en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. " Aux termes de l'article L. 3131-15, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut notamment, aux seules fins de garantir la santé publique : " 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ; 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout

autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ; 5° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ; 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature (...) ". L'article L. 3131-16 donne compétence au ministre chargé de la santé pour " prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 ", ainsi que pour " prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l'article L. 3131-15. " Enfin, aux termes de l'article L. 3131-17 : " Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions./ Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3131-15 et à l'article L. 3131-16 doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " La loi du 23 mars 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur. Par un décret du 23 mars 2020, le Premier ministre a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...).

5. Par les dispositions citées au point 3, le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l'Etat mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 la compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l'ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l'évolution de la situation.

6. Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, cités au point 4, autorisent le maire, y compris en période d'état d'urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l'Etat, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l'accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements. En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l'édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'Etat.

Sur la demande en référé :

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

7. Par un arrêté en date du 6 avril 2020, le maire de Sceaux, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, a subordonné les déplacements dans l'espace public de la commune des personnes âgées de plus de dix ans au port d'un dispositif de protection buccal et nasal. Cet arrêté prévoit qu'à défaut d'un masque chirurgical ou FFP2, " les usagers de l'espace public (...) peuvent porter une protection réalisée par d'autres procédés à la condition que ceux-ci couvrent totalement le nez et la bouche. " Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la Ligue des droits de l'homme sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté par une ordonnance en date du 9 avril 2020 dont la commune de Sceaux relève appel.

8. Par le décret du 23 mars 2013 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié et complété à plusieurs reprises, le Premier ministre a interdit, en dernier lieu jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile à l'exception de certains déplacements pour les motifs qu'il énumère et en évitant tout regroupement, et a habilité le représentant de l'Etat dans le département à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. En revanche, le décret n'impose pas, à ce jour, le port de masques de protection, dans tout ou partie de l'espace public, aux personnes autorisées à se déplacer, une stratégie de gestion et d'utilisation maîtrisée des masques ayant été mise en place à l'échelle nationale afin d'assurer en priorité leur fourniture aux professions les plus exposées.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, l'état d'urgence sanitaire ayant été déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'usage par le maire de son pouvoir de police générale pour édicter des mesures de lutte contre cette épidémie est subordonné à la double condition qu'elles soient exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et qu'elles ne soient pas susceptibles de compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures prises par l'Etat dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale.

10. Il résulte de l'instruction que, pour justifier l'obligation faite aux personnes âgées de plus de dix ans de porter lors de leurs déplacements dans l'espace public un dispositif de protection buccal et nasal, la commune de Sceaux fait valoir que sa population est plus âgée que la moyenne, avec 25 % de personnes de plus de 60 ans contre 19 % dans le reste de l'Ile-de-France selon ses dernières écritures, que les espaces verts, qui représentent le tiers de la superficie communale, ont été fermés et que les commerces alimentaires qui demeurent ouverts sont concentrés dans une rue piétonne du centre-ville dont la largeur n'excède pas quatre mètres en certains endroits, entraînant une forte affluence à certaines heures de la journée et rendant ainsi difficile le strict respect des gestes de distanciation sociale. La commune, ainsi que l'association Coronavictimes, soutiennent que le port obligatoire d'un dispositif de protection buccal et nasal limite le risque que des personnes contaminées, et en particulier des personnes asymptomatiques, propagent le virus et contaminent à leur tour des personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées, particulièrement nombreuses à Sceaux, et que, dès lors, la mesure contestée contribue à garantir la libre circulation de ces dernières.

11. Toutefois, d'une part, ni la démographie de la commune de Sceaux ni la concentration de ses commerces de première nécessité dans un espace réduit, ne sauraient être regardées comme caractérisant des raisons impérieuses liées à des circonstances locales propres à celle-ci et qui exigeraient que soit prononcée sur son territoire, en vue de lutter contre l'épidémie de covid-19, une interdiction de se déplacer sans port d'un masque de protection. D'autre part, l'édiction, par un maire, d'une telle interdiction, à une date où l'Etat est, en raison d'un contexte qui demeure très contraint, amené à fixer des règles nationales précises sur les conditions d'utilisation des masques chirurgicaux et FFP2 et à ne pas imposer, de manière générale, le port d'autres types de masques de protection, est susceptible de nuire à la cohérence des mesures prises, dans l'intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes. De plus, en laissant entendre qu'une protection couvrant la bouche et le nez peut constituer une protection efficace, quel que soit le procédé utilisé, l'arrêté est de nature à induire en erreur les personnes concernées et à introduire de la confusion dans les messages délivrés à la population par ces autorités. Les conditions n'étaient donc manifestement pas réunies en l'espèce pour que le maire de Sceaux puisse légalement édicter une telle interdiction sur le fondement de son pouvoir de police générale.

12. Alors même que la commune de Sceaux indique avoir mis en œuvre diverses mesures pour que tous ses habitants puissent, à terme rapproché, disposer d'un masque de protection, l'arrêté contesté, qui est d'ailleurs susceptible de concerner des personnes ne résidant pas dans la commune mais devant s'y déplacer, porte ainsi à la liberté d'aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale.

(…) 14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sceaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2020 (…).

## **Document n° 5** : CE, 31 décembre 2020, *Commune d'Arcueil*, n° 439253

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Val-de-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire d'Arcueil a interdit l'utilisation à certaines fins de l'herbicide glyphosate et des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sur l'ensemble du territoire de la commune, dans l'attente des mesures réglementaires devant être prises par l'Etat pour garantir la protection des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. Par une ordonnance n° 1908137 du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par un arrêt n° 19PA03833 du 14 février 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune d'Arcueil contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars, 18 mars et 11 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Arcueil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre2009 ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune d'Arcueil ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, le représentant de l'Etat peut assortir son déféré d'une demande de suspension, à laquelle il est fait droit si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 septembre 2019, le maire d'Arcueil a interdit l'utilisation de l'herbicide glyphosate et des produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sur l'ensemble du territoire de la commune pour l'entretien des jardins et espaces verts des entreprises, des propriétés et copropriétés, des bailleurs privés, des bailleurs sociaux publics, des voies ferrées et de leurs abords, des abords des autoroutes A6a et A6b, et de l'ensemble des routes départementales traversant la commune. Par une ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté. La commune d'Arcueil se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 février 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance.

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 253-7 du code du même code : " I.- Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. / L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : / 1° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 (...) ". L'article L. 253-7-1 du même code prévoit que : " A l'exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l'autorité administrative : / 1° L'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins

et espaces verts ouverts au public ; / 2° L'utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu'à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates et horaires de traitement permettant d'éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l'autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d'utiliser ces produits à proximité de ces lieux. (...) Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ". Par ailleurs, le III de l'article L. 253-8 du même code, entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose : " (...) l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique. / Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III. / Un décret précise les conditions d'application du présent III ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le ministre chargé de l'agriculture est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ainsi que l'autorité administrative mentionnée au chapitre III du titre V du livre II du présent code (partie législative) ". L'article R. 253-45 du même code dispose que : " L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture. / Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. " L'article D. 253-45-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l'agriculture. / L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l'utilisation des produits définis à l'article L. 253-1 ". En vertu de l'article D. 253-46-1-5 du même code, entré en vigueur le 1er janvier 2020, lorsque les mesures prévues dans la charte d'engagements des utilisateurs élaborée en application de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime sont adaptées et conformes aux exigences fixées par la réglementation, la charte est approuvée par le préfet de département concerné. Enfin, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, "

en cas de risque exceptionnel et justifié, l'utilisation des produits peut être restreinte ou interdite par arrêté préfectoral ", ce dernier devant " être soumis dans les plus brefs délais à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ".

5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, confiée à l'Etat et dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, alors que les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l'état des connaissances scientifiques, incertains. Les produits phytopharmaceutiques font l'objet d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché, délivrée par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail s'il est démontré, à l'issue d'une évaluation indépendante, que ces produits n'ont pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine. Il appartient ensuite au ministre chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la consommation, éclairés par l'avis scientifique de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de prendre les mesures d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de ces produits qui s'avèrent nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement, en particulier dans les zones où sont présentes des personnes vulnérables. L'autorité préfectorale est également chargée, au niveau local et dans le cadre fixé au niveau national, d'une part, de fixer les distances minimales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de certains lieux accueillant des personnes vulnérables, d'autre part, d'approuver les chartes d'engagements d'utilisateurs formalisant des mesures de protection des riverains de zones d'utilisation des produits et, enfin, en cas de risque exceptionnel et justifié, de prendre toute mesure d'interdiction ou de restriction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques nécessaire à la préservation de la santé publique et de l'environnement, avec une approbation dans les plus brefs délais du ministre chargé de l'agriculture. Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 22122 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qu'il appartient aux seules autorités de l'Etat de prendre.

6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune d'Arcueil, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, malgré l'absence de mesure de protection des riverains des zones traitées dans l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, que le pouvoir de police spéciale des produits phytopharmaceutiques confié aux autorités de l'Etat faisait obstacle à l'édiction, par le maire de la commune, de mesures réglementaires d'interdiction de portée générale de l'utilisation de ces produits. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les faits ou les a dénaturés en écartant la compétence du maire malgré l'existence de circonstances locales exceptionnelles justifiant son intervention au titre de son pouvoir de police générale ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arcueil est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arcueil, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

*

**CAS PRATIQUE** : (EXTRAIT DU GALOP 2025)

Mme Dévot est (…) désemparée (car) sa propriété a été ravagée il y a près de 10 ans à la suite de la crue de la rivière locale. Une bande de 5 mètres de large, au fond de son jardin riverain du cours d'eau, a ainsi été emportée par les eaux, tandis que sa maison a présenté ensuite d'importantes fissures nécessitant des travaux d'urgence. L'état de catastrophe naturelle a été constatée par arrêté du ministre de l'intérieur et le maire de la commune a déclaré cette habitation inhabitable.

Souhaitant pouvoir réintégrer sa maison, Mme Dévot a demandé, le 4 août dernier, au maire de la commune de réaliser de nouveaux travaux de confortement de la berge au droit de sa propriété afin de restaurer à la maison sa fonction d'habitation. Le maire n'a pas répondu explicitement et une décision implicite de rejet est née le 4 octobre. Il leur a simplement fait savoir, au cours d'une discussion informelle un jour de marché, qu'il n'y avait pas de raison d'en faire plus que ce qu'il avait déjà réalisé puisque, depuis 10 ans, la situation de la maison ne s'était pas dégradée et qu'elle était toujours debout…

> QUESTION : Mme Dévot voudrait demander l'annulation de cette décision de refus. Qu'en pensez-vous ?
> .

# SEANCE N° 6 :
# LES SOURCES CONSTITUTIONNELLES

Liste des documents :

- Document n° 1 : CE Ass., 3 octobre 2008, *Commune d'Annecy*, n° 297931
- Document n° 2 : CE, 9 juillet 2010, *Fédération nationale de la libre pensée et autres*, n° 327663
- Document n° 3 : Article 61-1 de la Constitution
- Document n° 4 : Conseil Constitutionnel, décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, *Assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence*.
- Document n° 5 : P. DELVOLVE, « L'actualité de la théorie des bases constitutionnelles du droit administratif », *RFDA* 2014, P.1211.

Exercice : Dissertation

*

## Document n° 1 : CE Ass., 3 octobre 2008, *Commune d'Annecy*

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ANNECY, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ANNECY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2006-993 du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne pris pour l'application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 34 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 1er août 2006, pris pour l'application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 187 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, introduit de nouvelles dispositions dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme, relatives à la " délimitation, autour des lacs de montagne, des champs d'application respectifs des dispositions particulières à la montagne et des dispositions particulières au littoral ", aux termes desquelles : " (...) Article R. 145-11. - La délimitation du champ d'application, autour des lacs de montagne de plus de mille hectares, des dispositions du présent chapitre et des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre est effectuée soit à l'initiative de l'Etat, soit à l'initiative concordante des communes riveraines du lac. / Article R. 145-12. - I. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative de l'Etat, le préfet adresse aux communes riveraines du lac un dossier comprenant : / a) Un plan de délimitation portant sur l'ensemble du lac ; / b) Une notice exposant les raisons, tenant au relief, à la configuration des lieux, bâtis et non bâtis, à la visibilité depuis le lac, à la préservation sur ses rives des équilibres économiques et écologiques ainsi qu'à la qualité des sites et des paysages, pour lesquelles la délimitation proposée a été retenue. / L'avis des communes est réputé émis si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de l'envoi du projet au maire. / II. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative des communes, celles-ci adressent au préfet le dossier prévu au I du présent article, accompagné de la délibération de chaque conseil municipal. / Article R. 145-13. - Le dossier, accompagné des avis ou propositions des conseils municipaux, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. / A l'issue de l'enquête publique, le préfet adresse au ministre chargé de l'urbanisme le dossier de délimitation ainsi que le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et une copie des registres de l'enquête. / Article R. 145-14. - Le décret en Conseil d'Etat approuvant la délimitation est publié au Journal officiel de la République française. Il est tenu à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de chacune des communes riveraines du lac. Il est affiché pendant un mois à la mairie de chacune de ces communes. " ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, que " la loi détermine les principes fondamentaux (...) de la préservation de l'environnement " ; qu'il est spécifié à l'article 7 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle que " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. " ; que ces dernières dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ;

Considérant que les dispositions précitées, issues de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont réservé au législateur le soin de préciser " les conditions et les limites " dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; qu'en

conséquence, ne relèvent du pouvoir réglementaire, depuis leur entrée en vigueur, que les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur ; que, toutefois, les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu'il était déterminé antérieurement, demeurent applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes, alors même qu'elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement que pour l'application de dispositions législatives, notamment parmi celles qui figurent dans le code de l'environnement et le code de l'urbanisme, que celles-ci soient postérieures à cette date ou antérieures, sous réserve, alors, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences de la Charte ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui se borne à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois, ne saurait être regardé comme déterminant les conditions et limites requises par l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme : " (...) Autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'Etat délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules. " ; que ces dispositions n'avaient pas pour objet de déterminer les conditions et limites d'application des principes d'accès aux informations et de participation du public s'imposant au pouvoir réglementaire pour la délimitation des zones concernées ; qu'en l'absence de la fixation par le législateur de ces conditions et limites, le décret attaqué du 1er août 2006, dont les dispositions, qui prévoient, outre la mise en oeuvre d'une enquête publique, des modalités d'information et de publicité, concourent de manière indivisible à l'établissement d'une procédure de consultation et de participation qui entre dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, a été pris par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANNECY est fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE D'ANNECY d'une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le décret du 1er août 2006 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE D'ANNECY une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

## **Document n° 2 : CE, 9 juillet 2010, *Fédération nationale de la libre pensée***

Vu, 1°, sous le n° 327663, la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE ; la FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d'application), signé à Paris le 18 décembre 2008 ; (…)
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997, publiée par le décret n° 2000-941 du 18 septembre 2000 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes sont dirigées contre le même décret du 16 avril 2009 portant publication de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur, signé à Paris le 18 décembre 2008, et de son protocole additionnel ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;
En ce qui concerne le contrôle du Conseil d'Etat, statuant au contentieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la Constitution : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi./ Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. (…) » ; que l'article 55 de la Constitution dispose : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les traités ou accords relevant de l'article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l'approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l'article 55 précité ; qu'il

appartient au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en cas de recours pour excès de pouvoir contre un décret publiant un traité ou un accord, de connaître de moyens tirés, d'une part, de vices propres à ce décret, d'autre part, de ce qu'en vertu de l'article 53 de la Constitution, la ratification ou l'approbation de l'engagement international en cause aurait dû être autorisée par la loi ; que constitue, au sens de cet article, un traité ou un accord « modifiant des dispositions de nature législative » un engagement international dont les stipulations touchent à des matières réservées à la loi par la Constitution ou énoncent des règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative ; qu'en revanche, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité du traité ou de l'accord à la Constitution ; qu'il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur la conformité d'un traité ou d'un accord à d'autres engagements internationaux ; (…)

Quant aux moyens tirés de ce que l'accord et le protocole additionnel publiés méconnaîtraient la Constitution et la convention de Lisbonne :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l'accord et du protocole publiés par le décret attaqué ; qu'il ne lui appartient pas non plus de se prononcer sur la conformité de ceux-ci à d'autres engagements internationaux ; que, par suite, les moyens formulés à ce titre ne peuvent qu'être écartés ;

## Document n° 3 : Article 61-1 de la Constitution

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

## Document n° 4 : Conseil Constitutionnel, décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, *Assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence*.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 décembre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 395009 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Cédric D. par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 », enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-527 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, enregistrées le 15 décembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 décembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour M. Pierre B., Mme Soizic C., M. Luc G., Mme Marion S., MM. Corentin V., Sid Ahmed G. et Fabien K. par Me Marie Dosé, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 15 et 16 décembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour M. Joël D. par Me Muriel Ruef, avocat au barreau de Lille, enregistrées le 15 décembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association Ligue des Droits de l'Homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 15 et 16 décembre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Denis Garreau et Me Alexandre Faro, avocat au barreau de Paris, pour le requérant, Me Dosé et Me Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris pour M. Pierre B., Mme Soizic C., M. Luc G., Mme Marion S., MM. Corentin V., Sid Ahmed G. et Fabien K., Me Ruef pour M. Joël D., Me Patrice Spinosi pour l'association Ligue des Droits de l'Homme et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 susvisée : « Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre de l'intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l'assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.
« L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.
« En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.

« L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.
« Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :
« 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;
« 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
« La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l'intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu'elle n'est plus nécessaire.
« Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d'emprisonnement et a fini l'exécution de sa peine depuis moins de huit ans, le ministre de l'intérieur peut également ordonner qu'elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé après accord de la personne concernée, recueilli par écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d'un dispositif technique permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Elle ne peut être astreinte ni à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie, ni à l'obligation de demeurer dans le lieu d'habitation mentionné au deuxième alinéa. Le ministre de l'intérieur peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de la personne placée aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement ou en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance » ;

2. Considérant que, selon le requérant, l'association Ligue des Droits de l'Homme et M. Joël D., en posant une obligation de ne pas quitter un lieu déterminé et en imposant, le cas échéant, à la personne ainsi assignée à résidence de demeurer dans un lieu d'habitation et de se présenter plusieurs fois par jour aux services de police ou de gendarmerie, les dispositions contestées portent une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'aller et de venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'aux libertés de réunion et de manifestation ; qu'en ne définissant pas avec suffisamment de précision le régime de l'assignation à résidence, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces droits et libertés constitutionnellement garantis ; que, dès lors que l'assignation à résidence n'est pas placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 66 de la Constitution ; que selon M. Pierre B., Mme Soizic C., M. Luc G., Mme Marion S., MM. Corentin V., Sid Ahmed G. et Fabien K., les dispositions contestées méconnaissent le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les neuf premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES DROITS GARANTIS PAR L'ARTICLE 66 DE LA CONSTITUTION :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; que la liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées permettent au ministre de l'intérieur, lorsque l'état d'urgence a été déclaré, de « prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée » par le décret déclarant l'état d'urgence ; que cette assignation à résidence, qui ne peut être prononcée qu'à l'égard d'une personne pour laquelle « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics », est une mesure qui relève de la seule police administrative et qui ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; que cette assignation à résidence « doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération » ; qu'elle ne peut en aucun cas « avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes » assignées à résidence ; que, tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution ;

6. Considérant, en second lieu, que, dans le cadre d'une assignation à résidence prononcée par le ministre de l'intérieur, la personne « peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures » ; que la plage horaire maximale de l'astreinte à domicile dans le cadre de l'assignation à résidence, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l'article 66 de la Constitution ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES DROITS ET LIBERTÉS GARANTIS PAR LES ARTICLES 2 ET 4 DE LA DÉCLARATION DE 1789 ET DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION :
8. Considérant que la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence ; qu'il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; que parmi ces droits et libertés figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

9. Considérant que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ;

10. Considérant que les dispositions contestées permettent à l'autorité administrative prononçant une assignation à résidence d'accompagner cette mesure d'une astreinte à demeurer dans un lieu d'habitation déterminé pendant une plage horaire ne pouvant excéder douze heures par vingt-quatre heures, de prescrire à la personne assignée à résidence de se présenter aux services de police ou aux unités de gendarmerie jusqu'à trois fois par jour, de lui imposer de remettre à ces services son passeport ou tout document justificatif de son identité, de lui interdire de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public ; que ces dispositions portent donc atteinte à la liberté d'aller et de venir ;

11. Considérant, en premier lieu, que l'assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l'état d'urgence a été déclaré ; que celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, qu'« en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou « en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » ; que ne peut être soumise à une telle assignation que la personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence et à l'égard de laquelle « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics » ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que tant la mesure d'assignation à résidence que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; que le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, la mesure d'assignation à résidence prise en application de cette loi cesse au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence ; que l'état d'urgence, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai de douze jours, être prorogé par une loi qui en fixe la durée ; que cette durée ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; que, si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures d'assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir ;

D É C I D E :
Article 1er.- Les neuf premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 décembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

## **Document n° 5 : P. DELVOLVE, « L'actualité de la théorie des bases constitutionnelles du droit administratif », *RFDA* 2014, p. 1211.**

Les organisateurs du colloque sur la constitutionnalisation du droit administratif ont voulu que, dès le début des travaux, soit exposée l'actualité de la théorie des bases constitutionnelles du < droit > < administratif >. C'est un honneur à un double titre : d'une part, pour un participant français, il manifeste une attention particulière pour la doctrine française qui est à l'origine de la théorie ; d'autre part, pour le rapporteur auquel est demandée la présentation du sujet, il souligne le lien qu'il a eu avec l'auteur de la théorie, le doyen Vedel, qui l'a associé à son ouvrage de < droit > < administratif > à partir de la 7e édition ; c'est dans cette même édition que le doyen a déjà actualisé cette théorie.

Il en est l'auteur exclusif : puisqu'il se trouve désormais dans un autre monde, on ne peut ici que rappeler sa thèse et essayer de déterminer en quoi elle survit aujourd'hui.

Il faut revenir au célèbre article publié en 1954 dans Études et documents du Conseil d'État (2). L'auteur constate l'affirmation faisant l'objet d'un accord général, selon laquelle « la < Constitution > est la base nécessaire des règles dont l'ensemble compose le < droit > < administratif > », dont la démonstration est inutile : « elle découle de la nature même de la < Constitution >, fondement de l'ordre juridique français et charte de l'organisation étatique ». Il veut aller plus loin en cherchant « sur quelles bases constitutionnelles peut se construire le < droit > < administratif > ». Contestant la notion de service public qui a pu paraître un temps la pierre angulaire du < droit > < administratif >, non seulement parce qu'elle est en crise mais parce qu'elle introduit une solution de continuité entre les principes constitutionnels et le < droit > < administratif >, il établit que « notre < droit > < administratif > doit se construire sur les notions de pouvoir exécutif et de puissance publique ». Ses propositions sont ainsi résumées : « l'administration stricto sensu n'est autre chose que l'exercice de la puissance publique par le pouvoir exécutif. Le < droit > < administratif > est le corps de règles spéciales applicables à l'activité du pouvoir exécutif en tant qu'il use de la puissance publique ».

La thèse, fondée sur les textes constitutionnels de 1875 et 1946 et la jurisprudence auxquels ils ont donné lieu(3), a dû être une première fois actualisée avec la < Constitution > de 1958, et notamment son article 3 donnant à l'exécutif un pouvoir réglementaire « autonome » : l'ouvrage < Droit > < administratif >, publié pour la première fois la même année, a cru pouvoir en déduire que l'activité administrative était l'activité de < droit > commun de la puissance publique et le < droit > < administratif >, « le < droit > commun de la puissance publique ». Ainsi, plutôt que des bases constitutionnelles du < droit > < administratif >, est établie la base constitutionnelle.

Cette thèse fut ébranlée par plusieurs démonstrations : d'abord, René Chapus(4) a identifié le < droit > < administratif > comme le < droit > du service public et le contentieux < administratif > comme le contentieux de la puissance publique - distinction contestée par Paul Amselek(5), et s'éloignant de la question des bases constitutionnelles ; puis Charles Eisenmann y est revenu de manière centrale en démontant de manière systématique la théorie des bases constitutionnelles du < droit > < administratif >(6).

Le doyen Vedel en a tenu compte dans la préface à la 7e édition de son < Droit > < administratif > (1980). Admettant l'erreur commise quant à la première interprétation de la < Constitution > de 1958, il rappelle la nécessité logique d'un lien entre < droit > < administratif > et < droit > constitutionnel et l'importance de la notion de pouvoir exécutif doté de prérogatives de puissance publique au coeur de l'histoire du critère de compétence et de celle du régime < administratif >. Il maintient l'idée que le < droit > < administratif > repose nécessairement sur « des bases constitutionnelles...». Il l'affine et le précise. Il arrive « ainsi à définir l'administration comme l'ensemble des activités du gouvernement et des autorités décentralisées étrangères à la conduite des relations internationales et aux rapports entre les pouvoirs publics et s'exerçant sous un régime de puissance publique » - et le < droit > < administratif > comme le < droit > de ces activités.

Revenant plus tard sur cette controverse(7), le doyen Vedel observe, d'une part, qu'elle est dépassée, d'autre part, que les « bases constitutionnelles émergeront de plus en plus de notre < droit > positif ». Il a plus tard encore pris une certaine distance par rapport à sa position initiale(8). Cela encourage à actualiser la théorie des bases constitutionnelles du < droit > < administratif > et à la relativiser.

Le doyen Vedel l'avait établie dans un cadre exclusivement français : il ne se fondait que sur les textes constitutionnels de la France, ceux de 1875 et 1946 d'abord, celui de 1958 ensuite, et sur la jurisprudence du Conseil d'État. On ne peut plus le faire. Le développement du < droit > < administratif > dans de nombreux systèmes juridiques, y compris anglo-saxons, les interactions entre eux, non par voie hiérarchique évidemment, mais par observation, comparaison, échanges (comme celui de ce colloque), ont conduit, non à une unification, mais à une convergence faisant apparaître des notions et des solutions communes. La réflexion sur l'identité du < droit > < administratif > ne peut être limitée à un cadre exclusivement national.

Pourtant, chaque < droit > < administratif > national a sa spécificité : le contenu peut varier d'un État à l'autre. Le professeur Cassese écrit à ce sujet(9) : « La notion et les règles du < droit > < administratif > n'ont pas de valeur générale et universelle, comme celles du < droit > privé ; elles diffèrent d'un pays à l'autre, selon que le < droit > < administratif > est plus ou moins développé ; de même les principes ordonnateurs sont de types différents selon les pays, les réflexions juridiques sont très vastes ou très circonscrites. En somme, il n'y a pas d'unités profondes, mais des entités disparates, sans cohérence ». À cela s'ajoute la création d'un véritable < droit > < administratif > européen, fondé sur des traités qui ont successivement fondé la Communauté européenne puis l'Union européenne(10).

Faut-il alors renoncer à essayer de trouver une théorie unique des bases constitutionnelles puisque le < droit > < administratif > lui-même n'est pas unique ? On peut au moins chercher si, au-delà de la diversité du < droit > < administratif > et à travers celle de ses bases constitutionnelles, il n'existe pas partout un socle

constitutionnel du < droit > < administratif >. Les < droits > < administratifs > peuvent être variés, leurs bases constitutionnelles aussi, mais le système des bases constitutionnelles devrait permettre de dégager une théorie qui les englobe toutes.

Encore faut-il s'entendre sur ce que sont des bases, car il est souvent parlé autant de sources constitutionnelles(11) que de bases constitutionnelles.

Selon le Grand dictionnaire Robert, la base est d'abord la partie inférieure d'un corps, sur laquelle il porte ou repose ; au figuré, elle est le principe fondamental sur lequel repose un raisonnement, une proposition, un système, une institution. Le mot renvoie à fondement, qui est, en logique, ce sur quoi repose un certain ordre ou un certain ensemble de connaissances. Base et fondement sont ainsi des concepts semblables.

La source est d'abord le point d'où sort l'eau ou l'eau qui sort elle-même. Au sens figuré, elle est le point d'origine de quelque chose (par exemple d'une information, de la chaleur, de la lumière, de l'énergie), duquel celle-ci découle.

Si l'on applique ces définitions dans l'espace, la base (ou le fondement) permet d'élever un édifice verticalement, la source se répand horizontalement. La base soutient, la source produit. La base sert à construire, la source permet plusieurs usages.

Si l'on applique ces définitions aux rapports entre < droit > constitutionnel et < droit > < administratif >, les sources constitutionnelles contribuent à déterminer le contenu du < droit > < administratif >, les bases constitutionnelles sont le socle sur lequel se construit le < droit > < administratif >.

Il n'est pas toujours facile de différencier sources constitutionnelles et bases constitutionnelles, car les sources peuvent servir à établir les bases du < droit > < administratif > autant qu'elles peuvent servir à en déterminer le contenu.

Mais pour être fidèle au sujet proposé, il faut chercher en quoi le < droit > constitutionnel permet la construction du < droit > < administratif > en un édifice juridique spécifique.

L'actualité fait apparaître à ce sujet deux tendances :

- le développement des normes constitutionnelles en < droit > < administratif > ;

- le dépassement de la théorie des bases constitutionnelles du < droit > < administratif >.

Le développement des normes constitutionnelles en < droit > < administratif >
Le développement des normes constitutionnelles en < droit > < administratif > est un aspect du développement de la constitutionnalisation du < droit > dans son ensemble, sous l'effet du constitutionnalisme, marqué à la fois par l'augmentation du nombre et du champ des normes constitutionnelles et par le renforcement de la justice constitutionnelle. Le doyen Vedel a élaboré « sa » théorie

à partir des arrêts du Conseil d'État (v. note 2) interprétant des dispositions constitutionnelles. Comme l'observe Olivier Jouanjan(12), le Conseil d'État a fait parler les textes constitutionnels pour leur donner un sens et une portée. Depuis lors, s'il n'a pas perdu son rôle créateur, il a été relayé par le Conseil constitutionnel au fur et à mesure de l'accroissement de ses interventions et de l'affermissement de son autorité. Le phénomène n'est pas propre à la France. Toutes les juridictions constitutionnelles, selon des procédés divers, ont pu et ont dû, à partir des textes constitutionnels, préciser les normes constitutionnelles s'imposant à toutes les branches du < droit >.

On en trouve des illustrations même dans celles, tel le < droit > civil, qui paraissaient a priori les plus réticentes au phénomène(13). « La constitutionnalisation du < droit > < administratif > »(14) apparaît ainsi comme un phénomène parmi d'autres. Cela peut contribuer à relativiser la théorie des bases constitutionnelles du < droit > < administratif > alors même que ces normes se développent elles-mêmes de deux manières : formellement, par le développement de dispositions constitutionnelles en matière administrative ; matériellement, par le développement constitutionnel de notions de < droit > < administratif >.

Le développement des dispositions constitutionnelles en matière administrative

Le doyen Vedel s'était fondé exclusivement sur l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 et l'article 47 de la < Constitution > du 27 octobre 1946, puis sur l'article 21 de celle du 4 octobre 1958, chargeant successivement le Président de la République, le Président du Conseil et le Premier ministre de l'exécution des lois. Il ne s'était pas servi des dispositions des < Constitutions > de 1946 et 1958 relatives aux collectivités locales. Actuellement, les révisions dont la < Constitution > de 1958 a fait l'objet depuis son adoption, si elles n'ont pas touché à l'article 21, ont renforcé certains aspects de l'administration, particulièrement la révision du 28 mars 2003. Il est désormais de principe, selon l'article 1er, que l'organisation de la République est décentralisée ; il en résulte plusieurs aménagements des dispositions relatives aux collectivités territoriales. C'est peu par rapport à ce que l'on trouve dans des < constitutions > d'autres États.

Une recherche menée à l'occasion de l'étude de la < Constitution > administrative de la France(15) a révélé que les < constitutions > sont inégalement précises.

Certaines le sont surtout pour les collectivités locales auxquelles elles consacrent des dispositions spéciales. C'est le cas par exemple de celles de la République tchèque (1992, art. 99 s.), de la Lituanie (1991, art. 119 s.), de la Bulgarie (1991, art. 135 s.).

D'autres sont plus générales, dans leur formulation ou dans leur objet. La < Constitution > italienne (1947) renvoie pour l'essentiel (art. 97) à la loi d'organisation et de fonctionnement des services publics. La < Constitution > grecque (1975) consacre à l'administration une section F qui porte sur l'organisation générale de celle-ci et sur le statut de ses agents.

Les formulations s'élargissent avec l'article 103 de la < Constitution > espagnole (1978), qui établit des principes généraux sur la manière dont l'administration doit servir (« avec objectivité ») et agir (efficacité, hiérarchie, décentralisation, déconcentration et coordination, soumission à la loi et au < droit >), celle de la Roumanie (1991), qui consacre un chapitre V (art. 165 s.) à « l'administration publique » en distinguant l'administration centrale et l'administration locale.

La < Constitution > portugaise (1976) est beaucoup plus riche avec tout un titre IX (art. 266 à 272) consacré à l'« administration publique », précisant, après des « principes fondamentaux », la « structure de l'administration », les « < droits > et garanties des administrés », le « régime de la fonction publique », les « restrictions à l'exercice de < droits > » de certains agents, la « responsabilité des fonctionnaires et des agents », la « police ». C'est sans doute celle qui, en matière administrative, d'une part, est la plus précise, d'autre part, établit le dispositif, sinon le plus complet, du moins le plus essentiel, et établit ainsi la trame d'une < constitution > administrative.

Deux < constitutions > méritent d'être particulièrement citées car elles comportent une systématisation propre à notre sujet.

Les formules de la < Constitution > hongroise de 2011 auraient particulièrement étayé la théorie des bases constitutionnelles du doyen Vedel. En effet, selon l'article 15, 1. Le gouvernement est l'organe général du pouvoir exécutif, ses prérogatives englobent tout ce qui ne relève pas expressément de la compétence d'un autre organe en vertu de la Loi fondamentale ou de toute autre norme juridique. ... 2. Le gouvernement est l'organe suprême de l'administration de l'État, habilité, dans les cas et les conditions prévus par la loi, à créer des organes d'administration d'État. 3. Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le gouvernement prend, sur la base d'une autorisation accordée par une loi, des décrets relatifs à des sujets ne relevant pas du domaine de la loi. S'y ajoutent les dispositions propres aux collectivités locales (art. 31 s.).

La plus ambitieuse est sans doute la < Constitution > de la Colombie de 1991, qui ne se contente pas d'établir l'organisation de l'État, mais, au sein de la branche de l'exécutif, définit la fonction administrative (art. 209 s.).

Il ne s'agit là que d'un inventaire incomplet. Il est insuffisant pour établir partout et toujours les bases constitutionnelles du < droit > < administratif >. Du moins les articles cités sont-ils une illustration de la part que certaines < constitutions > donnent à des questions d'ordre < administratif >. Ils peuvent contribuer plus profondément au développement constitutionnel des notions du < droit > < administratif >.

Le développement constitutionnel des notions de < droit > < administratif >

C'est essentiellement la jurisprudence qui, à partir des dispositions constitutionnelles, par une interprétation créative a érigé au niveau constitutionnel des éléments essentiels du < droit > < administratif >. Elle l'a fait pour les notions centrales du < droit > < administratif > et du régime < administratif >.

S'agissant des notions centrales du < droit > < administratif >, on retrouve celles qui, en tout cas en France, ont servi à la construction et à la systématisation du < droit > < administratif >.

On sait l'importance de la notion de service public, celle-là même que le doyen Vedel trouvait insuffisante pour servir de base constitutionnelle au < droit > < administratif > - et qui d'ailleurs n'est pas reprise dans tous les systèmes étrangers, voire peut paraître rejetée par le < droit > de l'Union européenne. Du moins le Conseil constitutionnel a-t-il contribué en France à reconnaître les exigences constitutionnelles relatives à l'existence de services publics et au régime du service public. Dans le premier cas, il affirme que « la nécessité de certains services publics nationaux découle de principes ou de règles à valeur constitutionnelle »(16), sans pour autant ni les identifier ni les définir : on sait seulement par là que la notion de service public s'élève au niveau constitutionnel. Cela se confirme dans le second cas puisque le Conseil constitutionnel appelle au « respect des exigences du service public »(17) ou encore des « exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la continuité des services publics »(18) : en particulier, « la continuité du service public [...] a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle »(19).

La notion de puissance publique est tout autant sollicitée. Elle est au coeur de la fameuse décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 identifiant le principe constitutionnel selon lequel « relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ». La référence à la fois au pouvoir exécutif et à la puissance publique est un écho direct de la position du doyen Vedel sur les bases constitutionnelles du < droit > < administratif >, qu'il a pu faire entériner par le Conseil constitutionnel auquel il appartenait lorsque celui-ci a rendu la décision du 23 janvier 1987, dont le doyen a été le rapporteur. C'est une confirmation éclatante de la théorie des bases constitutionnelles du < droit > < administratif >.

Elle se prolonge au sujet du régime < administratif >, caractérisé par deux éléments indissociablement liés à l'État de < droit > que la < Constitution > établit.

Le premier est le principe de la soumission de l'administration au < droit >. On a parlé longtemps du principe de légalité ; la formule vaut toujours, sauf à souligner que l'administration n'est pas seulement soumise à la loi. À ce sujet encore, les développements du < droit > constitutionnel ont souligné comme faisant partie du corps constitutionnel l'exigence du respect du < droit > par l'administration. Certes, ils n'ont pas été attendus pour que le principe de légalité soit considéré comme « le plus important de notre < droit > public », dont le respect s'impose « à toutes les autorités administratives si haut qu'elles fussent placées et quel que fût leur caractère »(20). Mais certaines dispositions constitutionnelles ont conduit à en rehausser le niveau et en renforcer la portée.

On peut citer certaines < constitutions > en ce sens. De l'article 1er de la < Constitution > espagnole de 1978, aux termes duquel « l'Espagne se constitue en un État de < droit > social et démocratique qui proclame comme valeurs suprêmes de son ordre juridique la liberté, la justice, l'égalité et le pluralisme politique », les tribunaux ont déduit les principes de légalité et de sécurité juridique(21). En Allemagne, « le juge

constitutionnel et le juge < administratif > ont tiré du principe de l'État de < droit > (Rechtsstaat), qui est posé par les articles 20 et 28 de la Loi fondamentale, non seulement le principe de légalité sous toutes ses variantes, mais encore un certain nombre de principes du < droit > < administratif > tels que l'impartialité, l'obligation de motiver les décisions, la sécurité juridique et spécialement la protection de la confiance légitime »(22). Plus directement, l'article 266-2 de la < Constitution > portugaise de 1976 dispose : « les organes et les agents < administratifs > observent la < Constitution > et la loi et doivent exercer leurs fonctions dans le respect des principes d'égalité, de proportionnalité, de justice et d'impartialité ». En France, si le principe de la soumission de l'administration au < droit > n'a pas été exprimé par une disposition de la < Constitution >, le Conseil constitutionnel considère que lorsque des pouvoirs sont attribués à des autorités administratives ou publiques, notamment celles qui sont qualifiées d'« indépendantes », elles sont toujours tenues de respecter les éléments de la légalité(23).

Le second principe constitutionnel du régime < administratif > est celui de la soumission de l'administration à contrôle. Il s'exprime en France à travers l'article 16 de la Déclaration des < droits > de l'homme et du citoyen de 1789 relatif à « la garantie des < droits > », de laquelle découle le < droit > à un recours effectif(24), précisé comme devant être « juridictionnel »(25). Plus explicitement et plus anciennement, l'article 131 de la < Constitution > fédérale d'Autriche permet à toute personne qui prétend être lésée de former un recours en violation du < droit > contre la décision d'une autorité administrative ; l'article 132 envisage un recours contre la violation du devoir de décider. Plus récemment, avec la Loi fondamentale de l'Allemagne fédérale (art.19, al. 4), « quiconque est lésé dans ses < droits > par la puissance publique dispose d'un recours juridictionnel ». L'article 106-1 de la < Constitution > espagnole charge les tribunaux de contrôler « le pouvoir de réglementation et la légalité de l'action administrative, ainsi que la soumission de celle-ci aux lois qui la justifient ». Pour la < Constitution > polonaise de 1997 (art. 184), « la Haute cour administrative et les autres tribunaux < administratifs > exercent, dans les limites de la loi, le contrôle de l'activité de l'administration ». La < Constitution > portugaise est encore plus prolixe : par son article 268, alinéa 4, « il est garanti aux administrés une protection juridictionnelle effective de leurs < droits > ou intérêts juridiquement protégés, comprenant notamment la reconnaissance de ces < droits > ou intérêts, la condamnation de tout agissement < administratif > qui lèse ceux-ci, indépendamment de la forme, la détermination des cas où l'administration est tenue par la loi d'agir et l'adoption de mesures provisoires appropriées ». Il ne s'agit là que de quelques exemples. Ils pourraient être multipliés(26).

Ainsi se sont développées les normes constitutionnelles propres au < droit > < administratif >. Cela confirme-t-il la théorie des bases constitutionnelles du < droit > < administratif > ? On peut avoir un doute.

Le dépassement de la théorie des bases constitutionnelles du < droit > < administratif >

L'importance du développement des normes constitutionnelles dans le < droit > < administratif > qu'on vient de constater conduit paradoxalement au dépassement de la théorie des bases constitutionnelles du < droit > < administratif >, à un double titre : d'une part, celle du doyen Vedel ne paraît plus tenir ; d'autre part, au-delà, il ne paraît plus possible de fonder le < droit > < administratif > sur des bases constitutionnelles.

Le dépassement de la théorie du doyen Vedel

Le doyen Vedel avait déjà réajusté lui-même sa théorie dans sa préface à la 7e édition de son < Droit > < administratif > pour tenir compte des critiques de Charles Eisenmann et, accessoirement, de René Chapus et Paul Amselek. Dans son article dans l'ouvrage consacré à La Pensée de Charles Eisenmann, il paraissait même douter que sa théorie puisse encore subsister.

Les développements du < droit > < administratif >, particulièrement de la jurisprudence administrative, en tout cas en France, confirment cette perspective. Si l'on reprend la définition de l'administration et, corrélativement, du < droit > < administratif > qui lui est spécifique, à laquelle le doyen était parvenu en 1980, on peut en observer les limites dans ses différents éléments.

Tout d'abord l'administration était définie comme constituée par les activités du gouvernement et des autorités décentralisées. Il reste évidemment exact que le gouvernement et les autorités décentralisées sont des organes < administratifs >. On peut déjà observer qu'entre 1954 et 1980, la thèse initiale, centrée sur le pouvoir exécutif et sa mission d'exécuter des lois, avait été élargie : on ne peut pas considérer que les autorités décentralisées font partie exactement du pouvoir exécutif. Certes elles assurent l'exécution des lois dans le domaine qui leur est propre, mais elles ne sont pas le prolongement du pouvoir exécutif gouvernemental, même si celui-ci les contrôle. La décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 distingue d'ailleurs clairement « les autorités exerçant le pouvoir exécutif » et « les collectivités territoriales » - lesquelles font, dans la < Constitution >, l'objet de dispositions propres.

Il faut ajouter d'autres autorités distinctes de l'exécutif proprement dit, qui se sont développées à partir des années quatre-vingts, comme autorités administratives ou autorités publiques indépendantes : on pourrait les ranger dans les autorités « décentralisées » en raison de leur indépendance même ; on pourrait aussi dire qu'elles reçoivent des attributions qui auraient pu ou dû relever de l'exécutif au sens strict et qu'elles font partie de celui-ci au sens large. Mais, de toute façon, elles constituent un élargissement du champ de l'administration au-delà des dispositions constitutionnelles.

La même observation peut être faite au sujet des organismes privés chargés d'une mission de service public et dotés de prérogatives de puissance publique : leur reconnaissance comme entrant dans le champ du < droit > < administratif >(27) et de la compétence de la juridiction administrative(28) est ancienne ; elle s'est prolongée(29). On peut encore les considérer comme des institutions décentralisées mais elles s'éloignent du pouvoir exécutif et des dispositions constitutionnelles relatives au pouvoir exécutif et aux collectivités territoriales : ces dispositions n'ont jamais été ni citées ni utilisées pour fonder leur soumission au < droit > < administratif > et à la compétence administrative.

De manière plus caractéristique, l'élargissement du champ du < droit > < administratif > et de la compétence administrative a atteint les autorités parlementaires, non dans leurs fonctions législatives, mais dans leurs fonctions administratives. Cela résulte, non pas seulement de dispositions ayant attribué certains contentieux des activités parlementaires à la juridiction administrative, mais de la reconnaissance par celle-ci de sa propre compétence sans l'intermédiaire d'un texte, à propos de marchés conclus par les assemblées parlementaires(30) : « il appartient à la juridiction administrative de connaître des contestations relatives aux

décisions par lesquelles les services de ces assemblées procèdent au nom de l'État à leur passation ». C'est reconnaître que la fonction administrative dépasse celle de l'exécutif et peut s'exercer dans le cadre d'organes parlementaires comme, précédemment, dans celui d'organes privés.

On ne peut plus définir l'administration comme portant seulement sur les activités du gouvernement et des autorités décentralisées.

On ne peut non plus préciser que ce sont seulement les activités étrangères à la conduite des relations internationales et aux rapports entre pouvoirs publics. Certes, dans les deux cas, il existe encore des aspects échappant au < droit > < administratif > et à la compétence administrative : mais l'un et l'autre y empiètent plus que naguère.

Désormais le juge < administratif > contrôle le respect par l'exécutif des conditions de ratification des traités, en vérifiant si elle a été précédée de l'autorisation législative nécessaire(31) ; il vérifie les conditions de notification à la Commission européenne des mesures législatives pouvant constituer des aides d'État(32) ; il a même annulé le refus du gouvernement de procéder à une extradition demandée par un gouvernement étranger(33).

Dans les relations entre pouvoirs publics, l'avancée du contrôle < administratif > s'est manifestée avec celui qu'exerce le Conseil d'État sur le refus du gouvernement de saisir le Conseil constitutionnel pour que celui-ci reconnaisse que la loi a empiété sur le domaine du règlement(34).

Il existe certes encore des cas où le juge < administratif > se récuse au sujet de mesures touchant aux relations internationales(35) ou aux rapports entre pouvoirs publics(36). Mais cela ne concerne que des cas extrêmes.

Il est donc difficile de définir l'administration et le < droit > < administratif > comme exclusifs des activités externes et des rapports entre pouvoirs publics.

De même, le régime de puissance publique, si important qu'il soit pour caractériser le < droit > < administratif > et la compétence administrative (comme la décision du 23 janvier 1987 le montre expressément), n'est pas exclusif : le service public peut servir à lui seul. On en a la preuve avec l'un des cas cités dans l'arrêt APREI du 22 février 2007 : pour identifier l'attribution d'un service public à un organisme privé, si la présence de prérogatives de puissance publique sert dans un premier cas, dans le second, « même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ». D'autres arrêts confirment cette solution(37).

Dès lors, au regard du seul < droit > français, la théorie du doyen Vedel fondant le < droit > < administratif >, non pas sur des bases constitutionnelles, mais sur une base constitutionnelle, ne peut plus être retenue.

Si l'on élargit l'analyse aux < droits > < administratifs > étrangers, la même observation peut être reprise. On peut relever avec Michel Fromont(38) la diversité des règles de compétence de la juridiction administrative et, corrélativement, du champ d'application du < droit > < administratif >. Dans les systèmes où cette compétence est la plus étendue, elle n'est pas déterminée au regard des critères qui auraient établi les bases constitutionnelles du < droit > < administratif >. Par exemple, en Espagne, ce n'est pas la < Constitution > mais la loi sur la justice administrative du 7 juillet 1998 attribue (art. 1er) aux tribunaux et cours de justice administrative le contentieux « des prétentions qui sont relatives à l'action des administrations publiques soumises au < droit > < administratif > », celles-ci étant « les entités de < droit > public qui dépendent ou sont liées à l'État, aux Communautés autonomes ou aux entités locales ». La < Constitution > ne définit pas ce qu'est le < droit > < administratif > auquel ces autorités sont soumises.

Dès lors il est difficile de considérer aujourd'hui que le < droit > < administratif > a en tant que tel une base constitutionnelle, entendue comme l'assise sur laquelle il est établi.

On peut néanmoins essayer de préciser théoriquement les liens entre < droit > constitutionnel et < droit > < administratif >.

Des bases constitutionnelles au cadre constitutionnel du < droit > < administratif >

L'importance des dispositions constitutionnelles portant sur le < droit > < administratif > et de la reconnaissance constitutionnelle de notions et de solutions de < droit > < administratif > ne permet évidemment pas de nier les liens entre < droit > constitutionnel et < droit > < administratif >.

Ceux-ci sont mis en valeur lorsqu'on parle de sources constitutionnelles du < droit > < administratif > (v. note 8). La formule souligne seulement l'origine de solutions de < droit > < administratif >. Mais cela ne fait pas du < droit > constitutionnel le fondement du < droit > < administratif >, le < droit > < administratif > ayant sa source aussi dans d'autres branches, tel le < droit > de la Convention européenne de sauvegarde des < droits > de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'interprétation et l'application qu'en a faites la Cour européenne des < droits > de l'homme, et le < droit > de l'Union européenne, avec l'ensemble de ses actes (traités, règlements, directives) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Le < droit > constitutionnel apparaît ainsi, sans doute plus fortement que d'autres branches du < droit >, mais au même titre qu'elles, comme déterminant un certain contenu dans différentes matières du < droit > < administratif > (identification des autorités administratives, de leur compétence et de leurs pouvoirs ; rôle des administrations publiques ; statut de la justice administrative principalement) ; comme les autres branches du < droit >, il nourrit le < droit > < administratif >.

Mais les autres branches du < droit > sont également nourries par lui. À cet égard, il n'y a pas de différences par rapport au < droit > constitutionnel entre, d'une part, le < droit > < administratif > et, d'autre part, le < droit > pénal, le < droit > du travail, le < droit > financier etc. (v. note 11).

Dans leur contenu, les sources constitutionnelles du < droit > < administratif > sont sans doute plus nombreuses que pour ces autres branches. Mais en soi elles ne constituent pas le < droit > < administratif >.

Or nous avons tous le sentiment, dans le prolongement du doyen Vedel, que le < droit > < administratif > trouve dans le < droit > constitutionnel un support. Comment le qualifier ?

Pour y arriver, il faut revenir à ce qui constitue l'essentiel du < droit > < administratif > et, d'abord, de l'administration. On peut retenir la définition que Michel Fromont(39) propose comme étant celle qui est retenue « dans toute l'Europe », mais qui, à vrai dire, peut l'être universellement : « l'administration publique peut être définie, dans son sens fonctionnel, comme une activité d'intérêt général exercée par des autorités publiques ou des personnes privées étroitement liées à celles-là hors des fonctions législatives et juridictionnelles. Entendue dans son sens organique, l'administration publique peut être définie comme l'ensemble des organes publics qui exercent une telle activité [...] ».

À partir de cette constatation, apparaissent les liens entre administration et < Constitution >, et corrélativement entre < droit > < administratif > et < Constitution > puisque aujourd'hui les autorités publiques (et leurs prolongements) ne se trouvent instituées qu'au sein de l'État et que celui-ci l'est lui-même par la loi fondamentale qu'est la < Constitution >.

Celle-ci ne se borne plus à établir des organes et à régir leurs rapports (comme ce fut le cas des lois constitutionnelles de 1875 en France) : elle détermine leur rôle et la manière de l'exercer, avec, plus fortement aujourd'hui qu'autrefois, les limites et les obligations découlant de la reconnaissance des < droits > et libertés des citoyens. À cet égard, la < Constitution > détermine au moins en partie, mais souvent largement, l'organisation et l'action administrative, donc le < droit > spécifique de cette organisation et de cette action.

On pourrait dire au sens large qu'ainsi le < droit > constitutionnel est bien la base du < droit > < administratif >, l'assise à partir duquel il se construit.

C'est ce qu'observe le professeur Cassese(40) tout en soulignant le « rapport ambigu » du < droit > constitutionnel et du < droit > < administratif > car « le < droit > < administratif > dépend du < droit > constitutionnel, mais en même temps il le conditionne ». « Les organes et les procédures < administratifs > ont pour assise le < droit > constitutionnel. Les < Constitutions > consacrent un nombre croissant de normes à l'administration [...]. Dans un certain sens, le < droit > constitutionnel contient les grandes options politiques, tandis que le < droit > < administratif > porte, apparemment, sur des problèmes techniques [...], comme le monisme ou le dualisme juridictionnel, la centralisation ou la décentralisation. Dans la vie concrète des institutions, le rapport devient plus complexe. Le < droit > < administratif > apparaît comme [...] < droit > constitutionnel concrétisé...». Ces formules rejoignent celles qui voient dans le < droit > constitutionnel les titres de chapitre du < droit > < administratif >(41).

Elles soulignent bien la relation étroite qui unit les deux < droits >. Mais aussi elles impliquent que le < droit > < administratif > va au-delà du < droit > constitutionnel : en effet bien des thèmes de < droit > < administratif > (par exemple acte < administratif >, contrat < administratif >, domaine public, fonction publique, responsabilité administrative, contentieux < administratif >) sont autonomes par rapport au < droit > constitutionnel ; leur notion et leur régime sont apparus indépendamment de lui et continuent à se développer en large partie sans lui. Ils n'y trouvent pas leur fondement.

C'est pourquoi, après avoir remarqué que, s'il existe « un statut constitutionnel de l'administration »(42) et des solutions de < droit > < administratif > qui sont déterminées par le < droit > constitutionnel, on ne peut pas dire que systématiquement, dans son ensemble, le < droit > < administratif > a pour base le < droit > constitutionnel.

Mais on peut dire avec Olivier Jouanjan(43) qu'il existe « un cadre constitutionnel du < droit > < administratif > ».

L'expression mérite d'être retenue même si elle nécessite d'être précisée. Un cadre est d'abord une bordure entourant une glace, un tableau, et plus généralement un objet ; par extension, c'est ce qui entoure un espace ou une action ; plus largement, c'est ce qui à la fois structure et limite quelque chose.

Un cadre peut être de grande ou de petite dimension. À l'intérieur d'un cadre, au sens propre comme au sens figuré, peuvent se trouver des éléments très variés (un tableau peut être figuratif ou non ; ses couleurs, ses formes, sa composition changent d'un peintre à l'autre ; son contenu et son inspiration peuvent provenir de différentes sources). Dans tous les cas, ils sont contraints par les limites du cadre.

C'est bien en ce sens que le < droit > constitutionnel est le cadre du < droit > < administratif >. Il en délimite les contours (qui sont ceux de l'organisation et de l'action administrative). Mais il laisse une variété de solutions possibles quant au contenu ; celui-ci peut être nourri par des sources diversifiées, beaucoup constitutionnelles mais pour partie seulement.

Ainsi le < droit > < administratif > de chaque État peut s'insérer dans le < droit > constitutionnel qui lui est propre. Comme l'a encore relevé le professeur Cassese (supra), le < droit > < administratif > varie d'un pays à l'autre. Cette variation résulte de traditions nationales. Celles-ci se retrouvent dans le système constitutionnel, qui lui-même se prolonge dans le système < administratif >. Chaque système constitutionnel constitue (c'est le cas de le dire) le cadre dans lequel s'insère le < droit > < administratif > : il le structure et le délimite, tout en lui laissant la possibilité de se développer avec des solutions qui lui sont propres.

En conséquence, s'il n'y a pas vraiment de base constitutionnelle servant d'assise à la < constitution > du < droit > < administratif >, il y a partout un cadre constitutionnel du < droit > < administratif >.

C'est en ce sens que peut être actualisée la théorie des bases constitutionnelles du < droit > < administratif >.

**

(1) Version française, légèrement remaniée, d'un rapport présenté le 3 sept. 2014 à l'Université Externado de Colombie (Bogota) lors des XVe journées internationales de < droit > < administratif >, et publié en langue espagnole dans La constitucionalizacion del Derecho administrativo (Alberto Montana Plata et Andrès Ospina Garzon, editores), Universidad Externado de Colombia, 2014, pp. 41-59

(2) N° 8, p. 21.

(3) CE, 28 juin 1918, n° 63412, Heyriès, Lebon ; CE, 8 août 1919, n° 56377, Labonne, Lebon.

(4) R. Chapus, « Le service public et la puissance publique », RD publ. 1968. 235-282.

(5) P. Amselek, « Le service public et la puissance publique - Réflexions autour d'une étude récente », AJDA 1968. 492-507.

(6) C. Eisenmann, « La théorie des bases constitutionnelles du < droit > < administratif > », RD publ. 1972. 1345-1441.

(7) G. Vedel, « Les bases constitutionnelles du < droit > < administratif > », in La pensée de Charles Eisenmann, Economica - Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1986, pp. 133-145.

(8) « Propos d'ouverture », in La constitutionnalisation des branches du < droit >, sous la direction de B. Mathieu et M. Verpeaux, Economica, 1998, p. 13 s.

(9) S. Cassese, La construction du < droit > < administratif >. France et Royaume-Uni (trad. de l'italien par J. Morvillez-Maigret), Montchrestien, 2000, p. 14.

(10) V. notamment, J. Scharze, < Droit > < administratif > européen, Bruylant, 2e éd., 2009.

(11) Par ex., B. Stirn, Les sources constitutionnelles du < droit > < administratif > - Introduction au < droit > public, préface G. Vedel, LGDJ, 8e éd., 2014.

(12) « La < Constitution > », in Traité de < droit > < administratif >, Dalloz, 2011, t. 1, p. 383 s., spéc. p. 394.

(13) V. par ex., F. Luchaire, « Les fondements constitutionnels du < droit > civil », RTD civ. 1982. V., in Cinquantième anniversaire de la < Constitution > française, Dalloz, 2008 ; les articles sur la constitutionnalisation du < droit > civil, du < droit > économique, du < droit > du travail, du < droit > pénal, du < droit > processionnel, du < droit > public financier, du < droit > de l'environnement, respectivement par N. Molfesis, Ph. Terneyre, O. Dutheillet de Lamothe, B. Bouloc, S. Guinchard, M. Bouvier et M. Prieur, p. 419 s.

(14) V. dans le même ouvrage, pp. 397-418 l'étude de P. Delvolvé.

(15) La < Constitution > administrative de la France (sous la Direction de J.J. Bienvenu, J. Petit, B. Plessix et B. Seiller), Dalloz, Thèmes et Commentaires, 2012. Rapport introductif par P. Delvolvé, pp. 3-12, spéc. p. 9.

(16) Cons. const., 25-26 juin 1986, n° 86-207 DC.

(17) Cons. const., 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, AJDA 2003. 1404, note E. Fatôme ; ibid. 1391, note J.-E. Schoettl ; ibid. 2348, étude E. Fatôme et L. Richer.

(18) Cons. const., 14 avr. 2005, n° 2005-513 DC, AJDA 2006. 178, étude E. Fatôme.

(19) Cons. const., 25 juill. 1979, n° 79-105 DC.

(20) Conclusions J. Delvolvé sur CE, 17 févr. 1950, n° 86949, Ministre de l'agriculture c/ Dame Lamotte, Lebon ; RD publ. 1951. 478

(21) M. Fromont, < Droit > < administratif > des États européens, PUF, Thèmis, 2006, p. 103.

(22) Idem, ibidem.
(23) Par ex., Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC.
(24) Cons. const., 9 avr. 1996, n° 96-373 DC, AJDA 1996. 371, note O. Schrameck ; D. 1998. 156, obs. J. Trémeau ; ibid. 145, obs. J.-C. Car ; ibid. 147, obs. A. Roux ; ibid. 153, obs. T. S. Renoux ; RFDA 1997. 1, étude F. Moderne ; Cons. const., 13 mai 2011, n° 2011-129 QPC, AJDA 2011. 988 ; RFDA 2011. 995, étude S. Jeannard ; < Constitutions > 2011. 305, obs. A. Baudu.
(25) Cons. const., 17 juin 2011, n° 2011-138 QPC, AJDA 2011. 1228 ; D. 2011. 1942, note O. Le Bot ; ibid. 2694, obs. F. G. Trébulle ; RDI 2011. 465, obs. P. Soler-Couteaux ; < Constitutions > 2011. 577, chron. A. Faro.
(26) V., M. Fromont, op. cit., p. 106.
(27) CE, 13 mai 1938, n° 57302, Caisse primaire « Aide et protection », Lebon.
(28) CE, 31 juill. 1942, n° 71398, Monpeurt Verreries et Cristalleries d'Alfortville, Lebon.
(29) CE, 22 févr. 2007, n° 264541, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI), Lebon avec les conclusions ; AJDA 2007. 793, chron. F. Lenica et J. Boucher ; RFDA 2007. 803, note C. Boiteau ; RDSS 2007. 499, concl. C. Verot ; ibid. 517, note G. Koubi et G. J. Guglielmi ; CE, 6 avr. 2007, n° 284736, Commune d'Aix-en-Provence, Lebon ; AJDA 2007. 1020, chron. F. Lenica et J. Boucher ; D. 2007. 1273, et les obs. ; ibid. 2617, chron. G. Clamour ; RDI 2007. 424, obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA 2007. 812, concl. F. Séners ; ibid. 821, note J.-C. Douence ; RTD com. 2007. 694, obs. G. Orsoni ; RTD eur. 2008. 835, chron. D. Ritleng, A. Bouveresse et J.-P. Kovar.
(30) CE, 5 mars 1999, n° 163328, Président de l'Assemblée nationale, Lebon avec les conclusions ; AJDA 1999. 460 ; ibid. 409, chron. F. Raynaud et P. Fombeur ; D. 1999. 627, note P. Brunet ; RDI 1999. 230, obs. F. Llorens ; ibid. 231, obs. F. Llorens ; ibid. 235, obs. F. Llorens ; ibid. 236, obs. F. Llorens ; ibid. 248, obs. F. Llorens ; RFDA 1999. 333, concl. C. Bergeal.
(31) CE, 18 déc. 1998, n° 181249, SARL du parc d'activités de Blotzheim et SCI « Haselaecker », Lebon avec les conclusions ; AJDA 1999. 180 ; ibid. 127, chron. F. Raynaud et P. Fombeur ; D. 1999. 56 ; RFDA 1999. 315, concl. G. Bachelier.
(32) CE, 7 nov. 2008, n° 282920, Comité national des interprofessions des vins à appellations d'origine, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2008. 2143 ; ibid. 2384 ; Just. & cass. 2009. 328, concl. E. Glase ; RFDA 2009. 111, concl. E. Glaser ; ibid. 123, étude C. Mondou et A. Potteau ; RTD com. 2009. 294, obs. G. Orsoni.
(33) CE, 15 oct. 1993, n° 142578, Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Gouverneur de la colonie royale de Hong-Kong, Lebon avec les conclusions ; AJDA 1993. 886 ; ibid. 848, chron. C. Maugüé et L. Touvet ; D. 1994. 108, note F. Julien-Laferrière ; RFDA 1993. 1179, concl. C. Vigouroux ; ibid. 1994. 21, étude H. Labayle ; ibid. 349, chron. D. Ruzié ; RSC 1994. 491, obs. E. Rolin.
(34) CE, 3 déc. 1999, n° 199622, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, Association France nature environnement, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2000. 171 ; ibid. 120, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2000. 17 ; RFDA 2000. 59, concl. F. Lamy ; ibid. 409, note L. Dubouis.
(35) Pour un exemple récent CE, réf., 23 mai 2014, n° 380560, Lebon : la décision par laquelle le gouvernement français s'est opposé à la tenue sur le territoire français d'opérations permettant aux ressortissants syriens de participer à l'élection présidentielle de Syrie, « n'est pas détachable des relations internationales » ; « elle échappe, dès lors, de manière manifeste à la compétence de la juridiction administrative ».

(36) CE, 26 nov. 2012, Krikorian : le refus du Premier ministre de soumettre au Parlement un projet de loi, y compris pour la transposition d'un acte de < droit > dérivé de l'Union européenne, échappe à la compétence de la juridiction administrative.
(37) T. confl., 9 déc. 2013, n° 3924, Pôle Emploi PACA, Lebon ; AJDA 2013. 2465 ; CE, 13 nov. 2013, n° 350428, Société Viamedis, Lebon ; AJDA 2013. 2287.
(38) Op. cit., p. 111 s.
(39) M. Fromont, op. cit., n° 5.
(40) Op. cit., p. 11.
(41) Par ex., H. Barthélémy, Traité élémentaire de < droit > < administratif >, 3e éd. 1905, p. 2
(42) P. Bon, « Peut-on parler de "pouvoir'< administratif >" ? », in Cinquantième anniversaire de la < Constitution > française, op. cit., p. 385, spéc. p. 391.
(43) Chapitre « La < Constitution > », in Traité de < droit > < administratif , op. cit., t. 1, p. 383 s., spéc. p. 395.

# SEANCE N° 7 :
# LES SOURCES INTERNATIONALES

Liste des documents :

- Document n° 1 : Conseil Constitutionnel, décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Interruption volontaire de grossesse
- Document n° 2 : CE Ass., 9 juillet 2010, *Mme Cheriet-Benseghir*, n° 317747
- Document n° 3 : CE Ass., 11 avril 2012, *GISTI et FAPIL*, n° 322326
- Document n° 4 : CE Ass., 30 octobre 2009, *Mme Perreux*, n° 298348.
- Document n° 5 : Conseil Constitutionnel, décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, *Secteur de l'énergie*.
- Document n° 6 : CE Ass., 8 février 2007, *Société Arcelor Atlantique et Lorraine*, n° 287110.
- Document n° 7 : CE Ass., 21 avril 2021, *Association French Data Network*, n° 393099 (extraits).

Exercice : cas pratique

*

## Document n° 1 : Conseil Constitutionnel, décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, *Interruption volontaire de grossesse*

1. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie." ;

3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l'article 61 de celle-ci;

4. Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l'article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu'il résulte de l'article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle ; qu'au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l'article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d'une part, à ce qu'elle est limitée au champ d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit s'apprécier le respect de cette condition ;

5. Considérant qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution,

6. Considérant qu'ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l'article 55 de la Constitution ne saurait s'exercer dans le cadre de l'examen prévu à l'article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ;

7. Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ;

8. Considérant, en second lieu, que la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu'il s'agisse d'une situation de détresse ou d'un motif thérapeutique ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

9. Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ;

10. Considérant qu'aucune des dérogations prévues par cette loi n'est, en l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l'enfant la protection de la santé, non plus qu'aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte ;

11. Considérant, en conséquence, que la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule non plus qu'aucun des articles de la Constitution ;

## **Document n° 2 : CE Ass., 9 juillet 2010, *Mme Cheriet-Benseghir***

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les visas de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins statuant en matière d'inscription au tableau de l'ordre doivent porter mention des textes relatifs à sa composition ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence, dans les visas

de la décision attaquée, de référence à des textes publiés relatifs à la composition de cette formation, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en matière d'inscription au tableau sur le recours administratif prévu par l'article L. 4112-4 du code; de la santé publique, se substituant à celle du conseil régional de l'ordre des médecins, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie tant devant le conseil départemental que devant le conseil régional de l'ordre des médecins sont inopérants à l'appui de conclusions dirigées contre la décision du Conseil national ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5. ; que, pour rejeter la demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins présentée par Mme A, de nationalité française, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré en 1997 par l'Institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales d'Oran, le Conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé, d'une part, sur le motif que ce diplôme n'était pas valable de plein droit en France sur le fondement de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie, faute d'application réciproque de cette déclaration par la partie algérienne, d'autre part, sur le motif que les attestations délivrées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur relatives à la valeur scientifique du diplôme de Mme A ne lui conféraient pas la qualité de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4111-1 précité du code de la santé publique ;

Considérant qu'aux termes du 14e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ; qu'au nombre de ces règles figure la règle pacta sunt servanda , qui implique que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu'une décision administrative a à tort, sur le fondement de la réserve énoncée à l'article 55, soit écarté l'application de stipulations d'un traité international, soit fait application de ces stipulations, de vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplie ; qu'à cette fin, il lui revient, dans l'exercice des pouvoirs d'instruction qui sont les siens, après avoir recueilli les observations du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, celles de l'Etat en cause, de soumettre ces observations au débat contradictoire, afin d'apprécier si des éléments de droit et de fait suffisamment probants au vu de l'ensemble des résultats de l'instruction sont de nature à établir que la condition tenant à l'application du traité par l'autre partie est, ou non, remplie

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie : Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examen, sont valables de plein droit dans les deux pays. / Des équivalences entre les grades et diplômes délivrés en Algérie et en France, dans des conditions différentes de programmes, de scolarité ou d'examens, seront établies par voie d'accords

particuliers ; que si le premier alinéa de cet article, qui produit des effets directs à l'égard des particuliers, ouvre le droit, dans le cas où un diplôme de médecine algérien a été délivré dans les mêmes conditions de programme, de scolarité et d'examen que les diplômes de médecine français, à l'inscription au tableau de l'ordre des médecins en France dans les conditions prévues par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique précité, ces stipulations ne créent aucune obligation, pour la France et l'Algérie, d'organiser des cursus identiques en termes de programme, de scolarité et d'examen ; que, par suite, la circonstance, avancée par l'administration et le Conseil national de l'ordre des médecins, selon laquelle, à compter de la fin des années mille neuf cent soixante, les conditions de programme, de scolarité et d'examen conduisant à la délivrance du diplôme de docteur en médecine auraient cessé d'être identiques dans les deux pays n'est pas de nature à établir que l'Algérie n'applique pas les stipulations précitées de la déclaration du 19 mars 1962 ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l'audience d'instruction tenue par la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, que des grades et diplômes d'enseignement de médecine délivrés en France dans les mêmes conditions de programme, de scolarité et d'examen qu'en Algérie n'y auraient pas été regardés comme valables de plein droit ; que, dès lors, le Conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en retenant que Mme A ne pouvait, faute que la condition de réciprocité posée par l'article 55 de la Constitution soit remplie, se prévaloir des stipulations précitées de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 et en s'abstenant, par suite, d'examiner si le diplôme de Mme A lui avait été délivré dans les mêmes conditions de programme, de scolarité et d'examen que celles existant en France ;

## **Document n° 3 : CE Ass., 11 avril 2012, *GISTI et FAPIL***

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011), désigné mandataire unique, et représenté par son président en exercice, et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION ET L'INSERTION PAR LE LOGEMENT (FAPIL), dont le siège est 221, boulevard Davout à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION ET L'INSERTION PAR LE LOGEMENT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) en tant que l'article R. 300-2 qu'il insère dans le code de la construction et de l'habitation fixe les conditions de la permanence de résidence mentionnées à l'article L. 300-1 du même code exigées des personnes de nationalité étrangère autres que les détentrices d'une carte de résident ou d'un titre conférant des droits équivalents et autres que les personnes relevant de l'article R. 300-1 du même code pour se voir ouvrir un droit au logement opposable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention internationale du travail n° 97 concernant les travailleurs migrants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
Vu le décret n° 54-794 du 4 août 1954 portant publication de la convention internationale du travail n° 97 concernant les travailleurs migrants ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat du Défenseur des droits ;
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat du Défenseur des droits ;

Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; que le décret attaqué n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant détermine, par l'article R. 300-2 ajouté au code de la construction et de l'habitation, pour les personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les conditions de permanence du séjour en France qui leur ouvrent un droit au logement opposable ; qu'en particulier, il établit, pour les personnes autres que celles détenant une carte de résident ou un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, une liste de cinq catégories de titres de séjour permettant à leurs détenteurs de demander le bénéfice du droit au logement opposable, sous la double condition d'une durée de résidence préalable de deux ans sur le territoire national et d'au moins deux renouvellements du titre de séjour détenu ; que cette liste ne comprend pas la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " salarié en mission ", ni la carte de séjour " compétences et talents " ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de la convention internationale du travail n° 97 du 1er juillet 1949 concernant les travailleurs migrants :

Considérant que les stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir ; que, sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer

s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ; que l'absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit ;

Considérant que l'article 6-1. de la convention internationale du travail n° 97 du 1er juillet 1949 concernant les travailleurs migrants, régulièrement ratifiée, et publiée par le décret du 4 août 1954, publié au Journal officiel de la République française du 7 août 1954 , stipule que : " Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes: / a) dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : (...) / iii) le logement (...) / d) les actions en justice concernant les questions mentionnées dans la convention ; " que l'article 11 de la convention définit le travailleur migrant comme la personne qui émigre d'un pays vers un autre en vue d'occuper un emploi autrement que pour son propre compte ; que l'engagement d'appliquer aux travailleurs migrants un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué aux ressortissants nationaux en matière de droit au logement et d'accès aux procédures juridictionnelles permettant de faire valoir ce droit ne saurait être interprété comme se bornant à régir les relations entre Etats et, ne requérant l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets, se suffit à lui-même ; que, par suite, les stipulations précitées peuvent utilement être invoquées à l'encontre du décret attaqué ; que celui-ci n'est pas compatible avec ces stipulations en tant, d'une part, qu'il subordonne le droit au logement opposable de certains travailleurs migrants au sens de cette convention à une condition de résidence préalable de deux ans sur le territoire national qui ne s'applique pas aux ressortissants nationaux, d'autre part, qu'il exclut de son champ d'application des titres de séjour susceptibles d'être attribués à des personnes pouvant avoir la qualité de travailleur migrant au sens de cette convention, tels que les travailleurs temporaires ou les salariés en mission ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;

Considérant que si le pouvoir réglementaire pouvait, dans les limites de l'habilitation donnée par le législateur et sous réserve du respect des principes à valeur constitutionnelle ainsi que des engagements internationaux de la France, fixer, s'agissant des ressortissants étrangers, des conditions leur ouvrant un droit au logement opposable distinctes selon les titres de séjour détenus par eux, il ne pouvait légalement le faire que pour autant que les personnes résidant en France sous couvert de ces titres se trouvent dans une situation

différente au regard de la condition de permanence du séjour sur le territoire national posée par l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation précité ou pour des motifs d'intérêt général en rapport avec cette même condition ; que la différence de traitement qui résulte du décret attaqué ne se justifie ni par un motif d'intérêt général, ni par une différence de situation au regard de la condition de permanence du séjour entre les personnes détentrices d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " salarié en mission ", ou d'une carte de séjour " compétences et talents ", d'une part, et les personnes détentrices d'autres titres de séjour temporaires inclus dans le champ du décret attaqué, d'autre part ; qu'il suit de là que le décret attaqué a méconnu le principe d'égalité en excluant du bénéfice du droit au logement opposable les détenteurs de ces trois catégories de titres de séjour ;

Considérant que les dispositions ainsi entachées d'illégalité sont indivisibles de l'ensemble des autres dispositions attaquées ; que, dès lors, le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES ET AUTRE sont fondés à demander l'annulation de ces dispositions ;

Sur les conséquences de l'illégalité du décret attaqué :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Considérant qu'au regard, d'une part, des conséquences de la rétroactivité de l'annulation du décret attaqué, qui produirait des effets manifestement excessifs tenant au vide juridique ainsi créé, d'autre part, de la nécessité de permettre au Gouvernement de prendre les dispositions assurant la continuité de la procédure du droit au logement opposable, et compte tenu tant de la nature des moyens d'annulation retenus que de celle des autres moyens soulevés par les associations requérantes et susceptibles d'affecter la légalité des dispositions attaquées, il y a lieu de prévoir que l'annulation prononcée par la présente décision ne prendra effet qu'à compter du 1er octobre 2012 et que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par les dispositions du décret attaqué antérieurement à son annulation seront regardés comme définitifs ;

D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l'association la Cimade, de l'association des familles victimes de saturnisme et de l'association Fédération droit au logement sont admises.
Article 2 : L'article 1er du décret du 8 septembre 2008 est annulé à compter du 1er octobre 2012 en tant que l'article R. 300-2 qu'il insère dans le code de la construction et de l'habitation fixe les conditions de la permanence de résidence mentionnées à l'article L. 300-1 du même code exigées des personnes de nationalité étrangère autres que celles détenant une carte de résident ou un titre conférant des droits équivalents et autres que les personnes relevant de l'article R. 300-1 du même code, pour se voir ouvrir un droit au logement opposable.

## **Document n° 4 : CE Ass., 30 octobre 2009, *Mme Perreux***

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Emmanuelle A, épouse C, demeurant ... ; Mme A, épouse C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du 24 août 2006 portant nomination dans la magistrature en tant qu'il la nomme vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal de grande instance de Périgueux et qu'il nomme Mme Eva B, épouse D, à l'administration centrale à compter du 1er septembre 2006, d'autre part, l'arrêté du 29 août 2006 portant nomination de Mme B, épouse D, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Périgueux, en qualité de chargée de formation à l'Ecole nationale de la magistrature à compter du 1er septembre 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et les articles 1er, 55 et 88-1 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, épouse C et du Syndicat de la magistrature,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

- les nouvelles observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, épouse C et du Syndicat de la magistrature ;

Considérant que Mme A a demandé, dans sa requête introductive d'instance, l'annulation, d'une part, du décret du 24 août 2006 portant nomination dans la magistrature en tant qu'il la nomme vice-présidente, chargée de l'application des peines, au tribunal de grande instance de Périgueux, et en tant que, selon elle, il nommerait Mme B au sein de l'administration centrale, d'autre part de l'arrêté du 29 août 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant nomination de Mme B, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Périgueux, en qualité de chargée de formation à l'Ecole nationale de la magistrature à compter du 1er septembre 2006 ; (…)

Sur la recevabilité des autres conclusions de Mme A :

Considérant qu'à la suite de ce désistement, Mme A a limité ses autres conclusions à l'encontre du décret du 24 août 2006 à la contestation de la nomination à l'administration centrale de Mme B ; qu'en l'absence d'une telle mesure dans le décret attaqué, que fait valoir à juste titre le garde des sceaux, ministre de la justice, ces conclusions ne sont pas recevables ; qu'en revanche Mme A a intérêt à agir contre l'arrêté du 29 août 2006, dès lors qu'elle est susceptible d'occuper la fonction à laquelle Mme B a été nommée par cet arrêté ; qu'ainsi ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont recevables ; (…)

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que Mme A soutient, à l'appui de sa requête, que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur de droit en écartant sa candidature au poste de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature en raison de son engagement syndical et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en préférant celle de Mme B ;

Considérant que la requérante invoque le bénéfice des règles relatives à la charge de la preuve fixées par l'article 10 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, dont le délai de transposition expirait le 2 décembre 2003, antérieurement à la date des décisions attaquées, alors que cette disposition n'a été transposée de manière générale que par l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles,

écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la directive du 27 novembre 2000 : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. / 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'adoption par les Etats membres de règles de la preuve plus favorables aux plaignants. / 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux procédures pénales. / 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à toute procédure engagée conformément à l'article 9, paragraphe 2. / 5. Les Etats membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'instance compétente. " ; qu'en vertu du cinquième paragraphe de cet article, les dispositions précitées relatives à l'aménagement de la charge de la preuve n'affectent pas la compétence laissée aux Etats membres pour décider du régime applicable aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ; que tel est l'office du juge administratif en droit public français ; qu'ainsi, eu égard à la réserve que comporte le paragraphe 5 de l'article 10, les dispositions de ce dernier sont dépourvues d'effet direct devant la juridiction administrative ;

Considérant toutefois que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses allégations, Mme A se fonde sur des éléments de fait, tenant tant à la qualité de sa candidature qu'à des procédures antérieures de recrutement à la fonction de chargé de formation pour l'application des peines à l'Ecole nationale de la magistrature, pour soutenir que cette candidature aurait été écartée en raison de ses responsabilités syndicales connues de l'administration ; que ces éléments de fait sont corroborés par une délibération en date du 15 septembre 2008 de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, que cette dernière a entendu verser au dossier de la procédure en application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 ; que, si ces

éléments peuvent ainsi faire présumer l'existence d'une telle discrimination, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments de comparaison produits en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice que la décision de nommer Mme B plutôt que Mme A au poste de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature repose sur des motifs tenant aux capacités, aptitudes et mérites respectifs des candidates ; que la préférence accordée à la candidature de Mme B procédait en effet d'une analyse comparée des évaluations professionnelles des deux magistrates et des appréciations que comportait l'avis motivé en date du 10 avril 2006 établi, conformément à l'article 12 du décret du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature, en vigueur à la date de la décision attaquée, par la commission de recrutement mise en place par l'école ; qu'elle était également en correspondance avec les critères fixés préalablement dans la description du poste publiée par l'école, tenant au fonctionnement et aux caractéristiques de l'équipe pédagogique, ainsi qu'aux capacités linguistiques requises par ses missions internationales ; que, dans ces conditions, ce choix, même s'il n'était pas celui du directeur de l'école, dont l'avis était prescrit par l'article 10 du même décret, doit être regardé comme ne reposant pas sur des motifs entachés de discrimination ; que, dès lors, il n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de Mme B est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le décret du 24 août 2006 en tant que ce décret la nomme vice-présidente, chargée de l'application des peines, au tribunal de grande instance de Périgueux.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention du Syndicat de la magistrature au soutien des conclusions dont Mme A s'est désistée.
Article 3 : L'intervention du Syndicat de la magistrature au soutien des autres conclusions de Mme A dirigées contre le décret du 24 août 2006 n'est pas admise.
Article 4 : L'intervention du Syndicat de la magistrature au soutien des conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté du 29 août 2006 est admise.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Emmanuelle A, épouse C, à Mme Eva B, épouse D, au Syndicat de la magistrature et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Une copie en sera adressée, pour information, à la Haute Autorité pour la lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

## **Document n° 5 : Conseil Constitutionnel, décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, *Secteur de l'énergie***

SUR L'ARTICLE 17 :

2. Considérant que l'article 17 de la loi déférée modifie l'article 66 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité et y insère un article 66-1 ayant le même objet pour le gaz naturel ; que le I des articles 66 et 66-1 rend ces tarifs applicables, pour un site donné, aux consommateurs non domestiques si ceux-ci ou une autre personne n'ont pas, sur ce site, fait usage de leur liberté de choisir un fournisseur d'énergie ; que le II de ces mêmes articles rend les tarifs réglementés applicables aux consommateurs domestiques si ceux-ci n'ont pas eux-mêmes exercé leur liberté de choix sur le site concerné ; que le III de ces mêmes articles oblige notamment les opérateurs historiques qui fournissent, pour un site donné, l'une des deux sources d'énergie à proposer aux consommateurs, à l'exception des plus importants, une offre au tarif réglementé pour les deux sources d'énergie dans les conditions prévues par le I et le II ; qu'en particulier, cette offre doit être faite aux consommateurs domestiques pour l'alimentation de nouveaux sites de consommation ; que l'ensemble de ces obligations n'est pas limité dans le temps ;

3. Considérant que ces dispositions s'insèrent dans une loi ayant pour objet de transposer les directives du 26 juin 2003 susvisées concernant le marché intérieur de l'électricité ainsi que celui du gaz naturel ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle ;

5. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite ;

6. Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ;

7. Considérant, en second lieu, que, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ; qu'en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel ;

8. Considérant qu'en vertu du 1 des articles 3 des directives susvisées, les États membres doivent veiller à ce que les entreprises d'électricité ou de gaz naturel « soient exploitées en vue de réaliser un marché concurrentiel » ; qu'ils doivent s'abstenir de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations

de ces entreprises ; que, si le 2 des mêmes articles prévoit que les États membres peuvent imposer des obligations à ces entreprises dans l'intérêt économique général, notamment en matière tarifaire, ces obligations doivent se rattacher clairement à un objectif de service public, être non discriminatoires et garantir un égal accès aux consommateurs nationaux ;

9. Considérant que les dispositions de l'article 17 de la loi déférée concernent les tarifs réglementés, qui se distinguent des tarifs spéciaux institués à des fins sociales pour le gaz par l'article 14 de la même loi et pour l'électricité par l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée ; qu'elles ne se bornent pas à appliquer les tarifs réglementés aux contrats en cours mais imposent aux opérateurs historiques du secteur de l'énergie, et à eux seuls, des obligations tarifaires permanentes, générales et étrangères à la poursuite d'objectifs de service public ; qu'il s'ensuit qu'elles méconnaissent manifestement l'objectif d'ouverture des marchés concurrentiels de l'électricité et du gaz naturel fixé par les directives précitées, que le titre premier de la loi déférée a pour objet de transposer ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à l'article 88-1 de la Constitution les II et III des nouveaux articles 66 et 66-1 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, ainsi que, par voie de conséquence, les mots « non domestique » figurant dans leur I concernant les contrats en cours ;

## **Document n° 6** : CE Ass., 8 février 2007, *Société Arcelor Atlantique et Lorraine*

Sur le cadre juridique du litige :

Considérant qu'afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 a établi un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne ; que l'annexe I de la directive fixe la liste des activités auxquelles elle s'applique ; qu'aux termes de son article 4 : " Les Etats membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation ne se livre à une activité visée à l'annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation (...) " ; qu'aux termes de son article 6, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre emporte notamment : " e) l'obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée (...) " ; que l'article 9 de la directive prévoit que, pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, puis pour les périodes de cinq ans suivantes, chaque Etat membre doit élaborer un plan national d'allocation de quotas précisant la quantité totale de quotas qu'il a l'intention d'allouer pour la période considérée ; qu'aux termes de son article 10 : " Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les Etats membres allocationnent au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, les Etats membres allocationnent au moins 90 % des quotas à titre gratuit " ; qu'en vertu de son article 11, il appartient à chaque Etat membre, sur la base de son plan national d'allocation des quotas, de décider, pour chaque période, de la quantité totale de quotas qu'il allouera et de l'attribution de ces quotas à l'exploitant de chaque installation, une partie de la quantité totale de quotas étant délivrée chaque année ; que son article 12 pose le principe selon lequel les quotas peuvent être transférés d'une personne à l'autre dans la Communauté ;

Considérant que l'ordonnance du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre a procédé à la transposition en droit interne de celles des dispositions de la directive du 13 octobre 2003 qui relèvent du domaine de la loi ; qu'elle a, à cette fin, introduit au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement une section 2, intitulée " Quotas d'émission de gaz à effet de serre ", comprenant les articles L. 229-5 à L. 229-19, dont les modalités d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat ; qu'a été pris, sur ce fondement, le décret n° 2004-832 du 19 août 2004, modifié par le décret n° 2005-189 du 25 février 2005 ; que, par ailleurs, le plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2005-2007 a été approuvé par le décret n° 2005-190 du 25 février 2005 ;

Considérant que la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et les autres requérants ont demandé le 12 juillet 2005 au Président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre délégué à l'industrie, à titre principal, l'abrogation de l'article 1er du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 en tant qu'il rend applicable ce décret aux installations du secteur sidérurgique et, à titre subsidiaire, celle des I et II de l'article 4 et de l'article 5 de ce décret ; que la présente requête tend à l'annulation des décisions implicites de rejet qui leur ont été opposées et à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de procéder aux abrogations en cause ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger l'article 1er du décret :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 août 2004 : " Le présent décret s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés dans l'annexe au présent décret, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés " ; qu'aux termes du point II-A de l'annexe au décret, sont visées au titre des activités de production et de transformation des métaux ferreux, les " installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré " et les " installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure " ;

Considérant que la soumission des activités de production et de transformation des métaux ferreux au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre est prévue par l'annexe I de la directive du 13 octobre 2003, dont l'annexe au décret du 19 août 2004 se borne à reprendre, à l'identique, le contenu ; qu'ainsi qu'il a été dit, la directive exclut la possibilité, pour un Etat membre, de soustraire des activités visées à l'annexe I au champ d'application du système ;

Considérant, en premier lieu, que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc, en l'espèce, se livrer à aucune appréciation quant au champ d'application du décret ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que celui-ci serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'est invoqué le moyen tiré de ce que l'article 1er du décret méconnaîtrait le principe de sécurité juridique en tant que principe général du droit communautaire ; que, toutefois, la circonstance que les entreprises du secteur sidérurgique ne pourraient prévoir à quel prix elles devront, le cas échéant, acheter des quotas ne saurait caractériser une méconnaissance de ce principe ;

Considérant, en troisième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que l'article 1er du décret méconnaîtrait plusieurs principes à valeur constitutionnelle ;

Considérant que si, aux termes de l'article 55 de la Constitution, " les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ", la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s'imposer, dans l'ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, selon lesquelles " la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ", dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles ; qu'alors, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué ; que, dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire ; qu'il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'en revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées ;

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que seraient méconnus le droit de propriété et la liberté d'entreprendre, dès lors que l'inclusion des entreprises du secteur sidérurgique dans le système les placerait dans une situation où elles seraient contraintes d'acquérir des quotas d'émission de gaz à effet de serre ; qu'en effet, le taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui leur est imposé serait supérieur aux

possibilités de réduction effective des émissions de gaz à effet de serre dont elles disposent en l'état des contraintes techniques et économiques ;

Considérant que le droit de propriété et la liberté d'entreprendre constituent des principes généraux du droit communautaire ; qu'ils ont, au regard du moyen invoqué, une portée garantissant l'effectivité du respect des principes et dispositions de valeur constitutionnelle dont la méconnaissance est alléguée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de rechercher si la directive du 13 octobre 2003, en tant qu'elle inclut dans son champ d'application les entreprises du secteur sidérurgique, ne contrevient pas elle-même à ces principes généraux du droit communautaire ;

Considérant que la seule circonstance que les entreprises du secteur sidérurgique soient incluses dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ne saurait être regardée comme portant atteinte aux principes généraux du droit communautaire qui garantissent le droit de propriété et la liberté d'entreprendre, dès lors qu'une telle atteinte ne pourrait résulter, le cas échéant, que du niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à ce secteur dans le cadre du plan national d'allocation des quotas prévu par l'article 8 de la directive et approuvé par un décret distinct du décret contesté ;

Considérant que les sociétés requérantes mettent en cause également la méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle d'égalité ;

Considérant qu'elles font valoir, tout d'abord, que les entreprises du secteur sidérurgique se trouveraient placées dans une situation différente de celles des autres entreprises soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et ne pourraient, dès lors, faire l'objet du même traitement ; que, cependant, le principe constitutionnel d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; qu'il suit de là que le moyen ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant, toutefois, que les sociétés requérantes soutiennent en outre que l'article 1er du décret attaqué méconnaît le principe d'égalité au motif que les entreprises relevant de secteurs concurrents, notamment du plastique et de l'aluminium, et émettant des quantités équivalentes de gaz à effet de serre, ne sont pas assujetties au système d'échange de quotas ;

Considérant que le principe d'égalité, dont l'application revêt à cet égard valeur constitutionnelle, constitue un principe général du droit communautaire ; qu'il ressort de l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que la méconnaissance de ce principe peut notamment résulter de ce que des situations comparables sont traitées de manière différente, à moins qu'une telle différence de traitement soit objectivement justifiée ; que la portée du principe général du droit communautaire garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect du principe constitutionnel en cause ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de rechercher si la directive du 13 octobre 2003, en tant qu'elle inclut dans son champ d'application les entreprises du secteur sidérurgique, ne contrevient pas à cet égard au principe général du droit communautaire qui s'impose à elle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les industries du plastique et de l'aluminium émettent des gaz à effet de serre identiques à ceux dont la directive du 13 octobre 2003 a entendu limiter l'émission ; que ces industries produisent des matériaux qui sont partiellement substituables à ceux produits par l'industrie sidérurgique et se trouvent donc placées en situation de concurrence avec celle-ci ; qu'elles ne sont cependant pas couvertes, en tant que telles, par le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre, et ne lui sont indirectement soumises qu'en tant qu'elles comportent des installations de combustion d'une puissance calorifique supérieure à 20 mégawatts ; que si la décision de ne pas inclure immédiatement, en tant que telles, les industries du plastique et de l'aluminium dans le système a été prise en considération de leur part relative dans les émissions totales de gaz à effet de serre et de la nécessité d'assurer la mise en place progressive d'un dispositif d'ensemble, la question de savoir si la différence de traitement instituée par la directive est objectivement justifiée soulève une difficulté sérieuse ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'abroger l'article 1er du décret contesté jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité de la directive du 13 octobre 2003 au regard du principe d'égalité en tant qu'elle rend applicable le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique, sans y inclure les industries de l'aluminium et du plastique ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger les I et II de l'article 4 et l'article 5 du décret :

Considérant qu'il résulte du sursis à statuer sur les conclusions principales des sociétés requérantes prononcé par la présente décision qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans l'attente de la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à la question préjudicielle qui lui est posée, de différer son examen des conclusions de la requête dirigées contre le refus d'abroger les I et II de l'article 4 et l'article 5 du décret du 19 août 2004 ;

## **Document n° 7 : CE Ass., 21 avril 2021, *Association French Data Network***

I. Sur le cadre juridique des litiges :

En ce qui concerne les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes :

3. En vertu de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ". Selon le paragraphe 3 de l'article 4 du traité sur l'Union européenne : " En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. / Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. / Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union ". La seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 19 du même traité assigne à la Cour de justice de

l'Union européenne la mission d'assurer " le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités ".

4. Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution. Il emporte l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens. En vertu des principes de primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte administratif.

5. Toutefois, tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier. Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent. Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.

6. Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement la transposition d'une directive européenne ou l'adaptation du droit interne à un règlement et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues par la directive ou le règlement, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité de l'acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte transpose ou le règlement auquel cet acte adapte le droit interne est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit de l'Union. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.

7. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un acte administratif relevant du champ d'application du droit de l'Union et qu'est invoqué devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives

qui en constituent la base légale ou pour l'application desquelles il a été pris, sont contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la Cour de justice d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation ou la validité de la disposition du droit de l'Union invoquée, d'écarter ce moyen ou d'annuler l'acte attaqué, selon le cas. Toutefois, s'il est saisi par le défendeur d'un moyen, assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'une règle de droit national, alors même qu'elle est contraire à la disposition du droit de l'Union européenne invoquée dans le litige, ne saurait être écartée sans priver de garanties effectives une exigence constitutionnelle, il appartient au juge administratif de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité de l'exigence constitutionnelle invoquée. Dans l'affirmative, il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à la Cour de justice, d'écarter cette argumentation avant de faire droit au moyen du requérant, le cas échéant. Si, à l'inverse, une telle disposition ou un tel principe général du droit de l'Union n'existe pas ou que la portée qui lui est reconnue dans l'ordre juridique européen n'est pas équivalente à celle que la Constitution garantit, il revient au juge administratif d'examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa contrariété avec le droit de l'Union européenne, il priverait de garanties effectives l'exigence constitutionnelle dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, d'écarter le moyen dont le requérant l'a saisi.

8. En revanche, et contrairement à ce que soutient le Premier ministre, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect, par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la Cour de justice elle-même, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres. Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l'Union des décisions de la Cour de justice et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union une portée excédant le champ d'application prévu par les traités.

*

**CAS PRATIQUE** : (EXTRAIT DU PARTIEL JANVIER 2024)

Dans le prolongement de l'arrêté du 31 août 2022 ayant créé le Conseil national professionnel (CNP) des aides-soignants, qui regroupe plusieurs structures associatives existant antérieurement, le législateur a créé un véritable ordre professionnel, sur le modèle de ceux existants pour les médecins ou les infirmiers, afin de répondre à un très ancien souhait de la profession.

La loi du 13 janvier 2024 prévoit notamment que :

- l'ordre sera composé de conseils départementaux et d'un conseil national dont les membres sont désignés par les aides-soignants eux-mêmes ;

- l'appartenance à l'ordre est obligatoire ;
- l'ordre aura pour mission, notamment : la régulation de l'accès à la profession, la contribution à la formation de ses membres, la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, une fonction de conseil sur les bonnes pratiques professionnelles et une fonction juridictionnelle pour sanctionner les manquements éventuels des professionnels à leurs obligations déontologiques ;
- les aides-soignants ne pourront exercer leur profession qu'après avoir été inscrits au tableau départemental de l'ordre par une décision prise par le conseil départemental ;
- seront inscrits les aides-soignants titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste qui sera établie par décret ;
- ces diplômes n'étant devenus obligatoires qu'en 2009, pourront également être inscrits les aides-soignants ayant commencé à exercer avant cette date, pourvu qu'ils justifient avoir exercé la profession pendant une durée minimale qui sera fixée par le décret.

Le décret d'application a été adopté le 22 janvier 2024.

L'ADPAS (Association pour la défense et la promotion des aides-soignants à laquelle adhère la majorité de ceux-ci) (…) a d'abord été alertée de la situation de Monsieur Szüt à qui il a été refusé le droit de s'inscrire au tableau de l'Ordre. L'article 10 du décret du 24 janvier 2024 précité, qui régit les modalités d'inscription, précise, en effet, que « L'inscription est subordonnée au fait d'être titulaire d'un diplôme national sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes ». M. Szüt, qui a la nationalité française, est titulaire d'un diplôme de « Soins et aide à la personne » délivré en 2017 par l'Université de Klöw, en Syldavie, et résidant depuis 5 en France, avait demandé, dès le 26 janvier 2022, son inscription au tableau de l'Ordre des aides-soignants. Le Conseil national a refusé cette inscription, par décision du 22 mars 2024, au motif, notamment, que le diplôme du pétitionnaire n'était pas au nombre de ceux lui permettant de s'inscrire au tableau de l'Ordre, au sens de l'article 10 du décret de janvier 2024. M. Szüt a formé un recours gracieux contre cette décision, le 25 mars 2024 ; une décision implicite de rejet est née du 25 mai 2024.

M. Szüt soutient que le décret français doit, en l'occurrence, être écarté au profit de la Convention de coopération culturelle entre la France et le Syldavie, signée le 22 mars 1954, et ratifiée le 12 mai 1955 par le Président de la République, aux termes de la laquelle « *Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Syldavie et en France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examen, sont valables de plein droit dans les deux pays* ».

1) L'ADPAS se demande s'il peut, selon vous, obtenir l'annulation de la décision refusant son inscription ? Elle s'interroge notamment sur l'argument, opposé par le conseil national de l'ordre des aides-soignants, selon lequel cette convention de coopération culturelle n'était pas opposable faute d'avoir été ratifiée ; que lui répondez-vous ?

# SEANCE N° 8 :

# CORRECTION DU GALOP D'ESSAI

# SEANCE N° 9 :
# LES LIMITES DU PRINCIPE DE LEGALITE

Liste des documents :

- Document n° 1 : CE, sect. 12 juin 2020, *GISTI*, n° 418142.
- Document n° 2 : CE, sect., 25 septembre 2015, *Mme B.*, n° 372624.
- Document n° 3 : CE, ass., 14 décembre 2007, *Boussouar*, n° 290420.
- Document n° 4 : CE, 3 octobre 2018, *M. B…*, n° 410611.
- Document n° 5 : CE, 27 janvier 2023, *Association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et autres*, n° 436099.
- Document n° 6 : CE, ass., 1er avril 2025, *Assoc. Ligue des droits de l'homme*, n° 494511.
- Document n° 7 : Th. PERROUD, « Liberté d'expression et circonstances exceptionnelles : le contrôle du Conseil d'Etat sur l'interdiction de TikTok et l'inauguration d'un contrôle de proportionnalité dynamique », *Legipresse* 2025, p.349
- Document n° 8 : P. Py, « Pouvoir discrétionnaire, compétence liée, pouvoir d'injonction », *Dalloz* 2000, p. 563

Exercice : Dissertation

*

## Document n° 1 : CE, sect. 12 juin 2020, *GISTI*, n° 418142.

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note d'actualité n° 17/2017 de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières du 1er décembre 2017 relative aux " fraudes documentaires organisées en Guinée (Conakry) sur les actes d'état civil " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

2. Il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure.

3. La " note d'actualité " contestée, du 1er décembre 2017, émanant de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières, vise à diffuser une information relative à l'existence d'une " fraude documentaire généralisée en Guinée (Conakry) sur les actes d'état civil et les jugements supplétifs " et préconise en conséquence, en particulier aux agents devant se prononcer sur la validité d'actes d'état civil étrangers, de formuler un avis défavorable pour toute analyse d'un acte de naissance guinéen. Eu égard aux effets notables qu'elle est susceptible d'emporter sur la situation des ressortissants guinéens dans leurs relations avec l'administration française, cette note peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur.

4. En premier lieu et en tout état de cause, la note contestée entre dans les attributions de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité dont elle émane. Et, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une décision, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la signature des décisions et aux mentions relatives à leur auteur ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après

toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La note contestée préconise l'émission d'un avis défavorable pour toute analyse d'acte de naissance guinéen et en suggère à ses destinataires la formulation. Elle ne saurait toutefois être regardée comme interdisant à ceux-ci comme aux autres autorités administratives compétentes de procéder, comme elles y sont tenues, à l'examen au cas par cas des demandes émanant de ressortissants guinéens et d'y faire droit, le cas échéant, au regard des différentes pièces produites à leur soutien. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du code civil doit donc être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que le GISTI n'est pas fondé à demander l'annulation du document qu'il attaque. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

---

Article 1er : La requête du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupe d'information et de soutien aux immigré.e.s et au ministre de l'intérieur.

## **Document n° 2 : CE, sect., 25 septembre 2015, *Mme B.*, n° 372624.**

Vu la procédure suivante :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 23 août 2011 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de l'unité territoriale de Paris, a décidé son changement d'affectation et, d'autre part, d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, de la réintégrer dans son ancienne affectation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1116493/5-2 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Mme B... a contesté ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris, dont le président, par une ordonnance n° 13PA02006 du 27 septembre 2013, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté le 27 mai 2013 à cette cour par Mme B....

Par ce pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février et 12 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la somme de 35 euros qu'elle a acquittée au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2015, présentée par Mme B... ;

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; que le jugement attaqué, qui comporte une erreur en ce qui concerne la date de lecture et mentionne trois dates d'audience différentes, méconnaît ces exigences ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il est irrégulier et doit être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., contrôleur du travail en fonction à la section d'inspection du travail C... de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France, a été affectée, par la décision contestée du 23 août 2013, à la section ... de cette direction ; que la mesure a été prise, dans l'intérêt du service, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles entre Mme B... et plusieurs de ses collègues ;

5. Considérant, en premier lieu, que ce changement d'affectation, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné pour Mme B... ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération ; qu'en second lieu, il est intervenu au sein de la même commune et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante ; que, par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de celle-ci, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de Mme B... est irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu enfin de laisser à la charge de cette dernière la contribution pour l'aide juridique qu'elle a

acquittée au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la présente affaire ;

D E C I D E :
---
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

## **Document n° 3 : CE, ass., 14 décembre 2007, *Boussouar*, n° 290420.**

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck A, demeurant au centre de détention de Nantes, 68, boulevard Einstein à Nantes (44316) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes par lequel celle-ci a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 août 2004 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice de la maison d'arrêt de Nantes du 12 juillet 2001 le déclassant de son emploi d'auxiliaire de cuisine dans cet établissement pénitentiaire ainsi que de la décision du 15 octobre 2001 du directeur régional des services pénitentiaires rejetant son recours hiérarchique ;
2°) statuant au fond, au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 août 2004 et d'annuler la décision de la directrice de la maison d'arrêt de Nantes du 12 juillet 2001 le déclassant de son emploi d'auxiliaire de cuisine au centre de détention ainsi que la décision du 15 octobre 2001 du directeur régional des services pénitentiaires rejetant son recours hiérarchique et d'enjoindre au directeur régional de l'administration pénitentiaire de réexaminer ses droits à rémunération et à remises de peines spéciales et de communiquer la décision à venir au magistrat chargé de l'application des peines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision en date du 12 juillet 2001, confirmée sur recours hiérarchique par le directeur régional des services pénitentiaires le 15 octobre 2001, la directrice de la maison d'arrêt de Nantes a, dans l'intérêt du service, déclassé M. A, alors détenu dans cet établissement, de son emploi d'auxiliaire de cuisine au service général ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 99 du code de procédure pénale : Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail./ L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi ; qu'aux termes de l'article D. 100 du même code : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus ; qu'aux termes de l'article D. 101 : Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser (...) ; qu'aux termes de l'article D. 102 : L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre ; qu'il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion ;

Considérant qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; qu'en jugeant que le déclassement de M. A, du fait des circonstances particulières dans lesquelles il était intervenu et notamment du délai dans lequel l'intéressé avait été reclassé, constituait une mesure d'ordre intérieur, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mesure de déclassement d'emploi contestée est de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de déclassement de M. A, précédée par un entretien au cours duquel l'intéressé a présenté ses observations écrites, mentionne l'ensemble des circonstances qui la justifient ; qu'ainsi, les moyens tirés de son insuffisante motivation et de ce que le requérant n'a pas été mis à même de présenter préalablement ses observations doivent être écartés ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées n'ont pas été signées par des autorités incompétentes ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le comportement de M. A, affecté aux cuisines de la maison d'arrêt de Nantes, se caractérisait, deux mois après son arrivée dans ce service, par une mauvaise volonté à accomplir les tâches qui lui étaient dévolues, en particulier s'agissant de l'aide aux autres détenus, ainsi que par le climat conflictuel qu'il entretenait par ses gestes et commentaires ; qu'en décidant, pour ces raisons, dans l'intérêt du service et non pour des motifs disciplinaires, le déclassement de l'intéressé sur le fondement de l'article D. 99 précité, la directrice de la maison d'arrêt de Nantes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt en date du 29 juin 2005 de la cour d'appel administrative de Nantes est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 4 août 2004 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

## **Document n° 4 : CE, 3 octobre 2018, *M. B…*, n° 410611.**

Vu la procédure suivante :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fautes commises par l'État français par l'abandon des harkis lors de l'indépendance alors même qu'ils étaient victimes de massacres et autres exactions en Algérie et dans les conditions d'accueil des harkis et de leurs familles rescapées dans des camps en France. Par un jugement n° 1109251 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE02837 du 14 mars 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mai 2017, 11 août 2017 et 3 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de faire droit à ses conclusions devant le juge du fond ramenant ses conclusions indemnitaires à un total de 100 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites " accords d'Evian " ;
- la loi n° 46-940 du 7 mai 1946 ;
- la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
- la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
- la loi n° 74-1044 du 9 décembre ;
- la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987;
- la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
- la loi de n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
- la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;
- la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 ;
- la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 ;
- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013;
- la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
- l'ordonnance n°62-25 du 21 juillet 1962 ;
- le décret n° 61-1201 du 6 novembre 1961 ;
- le décret du 31 mars 2003 ;
- le décret n° 2005-521 du 23 mai 2005 ;
- le décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 ;
- l'arrêté du 1er septembre 2012 fixant le montant des aides complémentaires à la formation ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. B...A...;
Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., fils d'un ancien supplétif de l'armée française en Algérie, est né en 1963 au camp " Joffre " de transit et de reclassement des anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et de leurs familles, situé à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), avant d'être transféré en 1964 au camp de Bias (Lot-et-Garonne), où il a vécu jusqu'en 1975. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la

condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'abandon des anciens supplétifs de l'armée française par la France après la signature des " accords d'Evian " du 19 mars 1962, du refus d'organiser leur rapatriement en France, ainsi que des conditions d'accueil et de vie qui ont été réservées aux anciens supplétifs et à leurs familles sur le territoire français.

*Sur l'intervention du Comité harkis et vérité :*

2. Le Comité harkis et vérité justifie d'un intérêt de nature à le rendre recevable à intervenir au soutien du pourvoi.

Sur les conclusions relatives aux préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et au défaut de rapatriement en France :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à l'appui de sa demande de réparation, M. A...a mis en cause la responsabilité pour faute de l'Etat en soutenant qu'étaient fautifs, d'une part, le fait de n'avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, en méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites " accords d'Evian " et, d'autre part, le fait de n'avoir pas organisé leur rapatriement en France. Cependant, les préjudices ainsi invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute.

4. Il suit de là que la cour administrative d'appel de Versailles, qui n'a pas méconnu les exigences découlant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en déclinant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la réparation de préjudices liés à l'absence d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française.

5. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la réparation de préjudices liés à l'absence de rapatriement en France des anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et de leurs familles.

*Sur les conclusions tendant à la réparation de préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles :*
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à l'appui de sa demande de réparation, M. A...a mis en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait des conditions d'accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles.

7. Après avoir caractérisé comme indignes les conditions de vie qui ont été réservées aux anciens supplétifs

de l'armée française en Algérie et à leurs familles dans des camps, comme le camp Joffre et le camp de Bias , ainsi que les restrictions apportées à leurs libertés individuelles, du fait, en particulier, du contrôle de leurs courriers et de leurs colis, de l'affectation de leurs prestations sociales au financement des dépenses des camps et de l'abscence de scolarisation des enfants dans des conditions de droit commun, la cour administrative d'appel de Versailles a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification en jugeant qu'avait ainsi été commise une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

8. Toutefois, pour rejeter les conclusions dont elle était saisie, la cour n'a pas recherché la valeur des préjudices dont M. A...demandait réparation, mais s'est bornée à faire état d'un ensemble de mesures d'ordre financier mises en place par l'Etat au bénéfice des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles ainsi que de la reconnaissance solennelle du préjudice qu'ils ont collectivement subi, notamment par la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, pour en déduire que ces mesures devaient être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, l'indemnisation des préjudices dont se prévalait le requérant. En statuant ainsi, la cour a, eu égard à la nature des préjudices invoqués, entaché son arrêt d'erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 14 mars 2017 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, en tant seulement qu'il statue sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices liés, d'une part, à l'absence de rapatriement des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles et, d'autre part, aux conditions de vie qui leur ont été réservées en France.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la réparation du préjudice lié à l'absence de rapatriement des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles. Le jugement du 10 juillet 2014 doit dès lors être annulé sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête. Il y a lieu d'évoquer, dans cette mesure, et, statuant immédiatement sur la demande présentée par M. A...à ce titre, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

12. En second lieu, il résulte de l'instruction que la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à M. A...entre sa naissance au camp " Joffre " en 1963 et son départ du camp de Bias en 1975, qui ont notamment fait obstacle à son apprentissage du français et entraîné des séquelles qui ont exigé un accompagnement médico-psycho-social. Dans les circonstances de l'espèce, et l'État n'ayant pas opposé la prescription quadriennale à la demande de l'intéressé, il sera fait une juste évaluation des préjudices matériel et moral qui ont été directement causés au requérant du fait des conditions dans lesquelles il a vécu entre sa naissance au camp " Joffre " en 1963 et son départ du camp de Bias en 1975 en fixant le montant de son indemnisation à 15 000 euros. Il en résulte que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de réparation qu'il a présentée à ce titre.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M.A....

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du Comité harkis et vérité est admise.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative de Versailles du 14 mars 2017 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices liés, d'une part, à l'absence de rapatriement des anciens supplétifs de l'armée française et de leurs familles et, d'autre part, aux conditions d'accueil et de vie qui leur ont été réservées en France.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 10 juillet 2014 est annulé en tant qu'il statue sur les deux chefs de préjudices mentionnés à l'article 2.
Article 4 : Les conclusions tendant à la réparation du préjudice lié à l'absence de rapatriement des anciens supplétifs de l'armée française présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. A...une somme de 15 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis du fait des conditions dans lesquelles il a vécu entre sa naissance au camp " Joffre " en 1963 et son départ du camp de Bias en 1975.
Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi, de la requête d'appel et de la demande de première instance de M. A...est rejeté.

## **Document n° 5 : CE, 27 janvier 2023, *Association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et autres*, n° 436099.**

Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
L'association Action sécurité éthique républicaines (ASER) a demandé au tribunal administratif de Paris, avant dire droit, d'enjoindre au Premier ministre de déclassifier et de verser à l'instance, après avis de la commission du secret de la défense nationale, d'une part, l'ensemble des licences délivrées aux pays membres de la coalition internationale impliquée dans la guerre au Yémen à compter du 26 mars 2015 et antérieurement, mais dont l'exécution serait postérieure, d'autre part, l'ensemble des délibérations et avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre afférents à ces licences et, enfin, toutes les informations susceptibles d'éclairer la juridiction et les parties sur la conformité aux engagements internationaux de la France des licences délivrées. Elle a également demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur sa demande du 1er mars 2018 tendant à la suspension des licences d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés à destination des pays impliqués dans la guerre au Yémen. Par un jugement n° 1807203 du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a admis l'intervention à l'instance de l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) et rejeté la demande de l'association ASER.

Par une ordonnance n° 19PA02929 du 26 septembre 2019, le premier vice-président, président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, a rejeté l'appel formé par l'association ASER contre ce jugement, ainsi que les interventions présentées au soutien de la requête par les associations Action contre la faim, Médecins du monde, Salam for Yemen et Sherpa.

Par une ordonnance n° 19PA02930 du 26 septembre 2019, le premier vice-président, président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, a rejeté l'appel formé par l'association ACAT contre ce même jugement.

Procédures devant le Conseil d'Etat :

I. Sous le n° 436098, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2019, 21 février 2020, 15 et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association ACAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 19PA02930 du 26 septembre 2019 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- La qualification d'acte de gouvernement des licences d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés est-elle compatible avec le droit au recours effectif garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne '
- Le juge interne est-il contraint d'exercer un contrôle de conformité de la politique nationale par rapport à la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires '
4°) avant dire droit, de surseoir à statuer et enjoindre au Premier ministre de déclassifier et communiquer au contradictoire, après avis de la Commission du secret de la défense nationale :
- l'ensemble des licences délivrées aux pays membre de la coalition impliquée dans la guerre au Yémen à compter du 26 mars 2015 et antérieurement mais dont l'exécution serait postérieure ;
- l'ensemble des délibérations et avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG) afférents aux licences susvisées ;
- plus généralement, toutes informations susceptibles de mettre le Conseil d'Etat et les parties en mesure d'apprécier la conformité des autorisations délivrées par rapport aux engagements internationaux de la France ainsi que la légalité des procédures suivies et le respect des conditions qui assortissent éventuellement le maintien des licences ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 436099, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2019, 21 février 2020, 8 janvier, 15 et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations ASER, Action contre la faim, Salam For Yemen, Médecins du monde et Sherpa demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 19PA02929 du 26 septembre 2019 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'admettre les interventions des associations Action contre la faim, Salam For Yemen, Médecins du monde et Sherpa, et de faire droit à l'appel de l'association ASER ;
4°) avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les mêmes questions préjudicielles que dans le pourvoi n° 436098 ;
5°) avant dire droit, de surseoir à statuer et enjoindre au Premier ministre de déclassifier et communiquer au contradictoire, après avis de la Commission du secret de la défense nationale, les mêmes documents et informations que ceux mentionnés dans les conclusions du pourvoi n° 436098 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la charte des Nations-Unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le commerce des armes signé à New York le 3 juin 2013 ;
- la position commune n° 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M.Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois n° 436098 et n° 436099 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Action sécurité éthique républicaines (ASER) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du Premier ministre de sa demande du 1er mars 2018 tendant à la suspension des licences d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés à destination des pays impliqués dans la guerre au Yémen. Par un jugement du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a admis l'intervention de l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) et a rejeté la demande de l'association ASER. Par deux ordonnances du 26 septembre 2019, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par les associations ACAT et ASER contre ce jugement ainsi que les interventions présentées au soutien de la requête de l'association ASER par les associations Action contre la faim, Médecins du monde, Salam for Yemen et Sherpa.

Sur le désistement de l'association Sherpa :

3. Le désistement de l'association Sherpa est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le pourvoi :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par lettre en date du 1er mars 2018, l'association ASER a demandé au Premier ministre " la suspension sans délai de l'ensemble des autorisations préalables d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés à destination de l'Arabie saoudite ". Le refus implicite opposé à cette demande de portée générale n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France, sans que puissent être utilement invoquées à cet égard les stipulations des articles 6 et 7 du traité sur le commerce des armes, de l'article 2 de la charte des Nations-Unies et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les dispositions des articles 1 et 2 de la position commune n° 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 et de l'article L. 2335-4 du code de la défense. Dès lors, l'auteur des ordonnances attaquées, qui ne sont pas entachées de contradiction de motifs, a pu juger, sans commettre d'erreur de droit ni inexactement qualifier les faits qui lui étaient soumis, que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus.

5. En second lieu, l'auteur des ordonnances attaquées, qui a implicitement mais nécessairement statué sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dont le 2° prévoit que les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative peuvent être rejetées par ordonnance, n'a pas fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ni de faire droit à la demande de déclassification et de communication de certains documents, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des ordonnances qu'elles attaquent.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de l'association Sherpa.
Article 2 : Les pourvois de l'association ACAT et de l'association ASER et autres sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, à l'association Action sécurité éthique républicaines, première dénommée sous le pourvoi n° 436099, à la Première ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

## **Document n° 6 : CE, ass., 1er avril 2025, *Association Ligue des droits de l'homme***

« Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 mai 2024, le Premier ministre a pris la décision, motivée par l'existence de < circonstances > < exceptionnelles >, d'interrompre l'accès au service de communication au public en ligne "TikTok" en Nouvelle-Calédonie. Cette décision a été appliquée à compter du lendemain en recourant à des dispositifs techniques mis en oeuvre notamment par l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre a mis fin à cette mesure le 29 mai 2024. Parallèlement, par un décret en conseil des ministres du 15 mai 2024, l'état d'urgence a été déclaré sur le territoire néo-calédonien à compter du même jour à 20 heures (heure de Paris). Il a pris fin, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, douze jours plus tard. La Ligue des droits de l'homme, l'association "La Quadrature du net" et M. C... et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'interruption de l'accès au service de communication au public en ligne "TikTok". Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ».

« Sur le cadre juridique :

2. En premier lieu, d'une part, la survenue de < circonstances > < exceptionnelles >, de nature, notamment, à entraver le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à compromettre de manière immédiate la santé de la population ou son accès aux services essentiels, ou à porter atteinte à l'ordre public, dans des conditions d'une particulière gravité, permet à l'autorité administrative de prendre, en urgence, toutes mesures pour pourvoir aux nécessités du moment, lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'agir selon les normes en vigueur, à la condition que de telles mesures soient indispensables au regard des < circonstances > prévalant à la date de la décision, sous l'entier contrôle du juge administratif.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence : "L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique." Aux termes de l'article 2 de la même loi : "L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. / Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret. / La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi." Il résulte enfin du II de l'article 11 de la même loi, dans sa version résultant de la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi nº 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, que : "II.- Le ministre de l'Intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie."

4. La déclaration de l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire national en application des dispositions citées au point 3, en étendant les pouvoirs de l'autorité administrative aux fins de remédier à un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou à un événement présentant le caractère de calamité

publique, institue un régime juridique qui lui confère, en principe, les moyens de faire face à de telles < circonstances >. Toutefois, elle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative use, lorsque des < circonstances > < exceptionnelles > l'exigent, des pouvoirs mentionnés au point 2 pour prendre d'autres mesures que celles relevant de la loi du 3 avril 1955, lorsqu'aucune de ces dernières mesures, pas davantage que celles relevant d'autres régimes d'exception ou de droit commun, n'est de nature à répondre aux nécessités du moment.

5. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi." La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés.

6. En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique, économique et sociale et l'expression des idées et des opinions, la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, implique la liberté d'accéder à ces services et de s'y exprimer.

7. Eu égard aux atteintes portées à la libre communication des pensées et des opinions, à la liberté d'expression et à tous les autres droits et libertés dont un service de communication au public en ligne permet l'exercice, notamment le droit à la vie privée et familiale et la liberté du commerce et de l'industrie, l'autorité administrative ne saurait décider, en dehors des cas prévus par la loi, de l'interruption de l'accès à un tel service. Elle peut cependant recourir à une telle mesure, en cas de < circonstances > < exceptionnelles >, si elle est indispensable pour répondre aux nécessités du moment. Dans ce cadre, une interruption complète du service en cause ne saurait être légalement décidée qu'à titre provisoire, à la condition, d'une part, qu'aucun moyen technique ne permette, dans l'immédiat, de prendre des mesures alternatives moins attentatoires aux droits et libertés en cause, et, d'autre part, que l'interdiction soit prise pour une durée n'excédant pas celle requise pour rechercher et mettre en oeuvre de telles mesures ».

« Sur les moyens des requêtes :

8. Il ressort des pièces du dossier que, à partir du 13 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie a connu une période de troubles à l'ordre public d'une gravité < exceptionnelle >, dans le contexte de l'examen du projet de révision constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Ces troubles se sont caractérisés par des émeutes ayant donné lieu à des affrontements violents du fait de groupes d'individus armés ayant conduit, les 14 et 15 mai 2024, au décès de plusieurs personnes, à des destructions et des dégradations de bâtiments publics et d'infrastructures et à une mutinerie s'étant accompagnée de tentatives d'évasion au centre pénitentiaire de Nouméa. De nombreuses voies de circulation ont été bloquées en raison de la mise en place de barrages, lesquels ont donné lieu à des agressions ou à des affrontements directs avec les personnes tentant de les traverser.

9. En premier lieu, les dispositions du II de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 citées au point 3, qui permettent au ministre de l'Intérieur de prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie, ne faisaient pas obstacle, par principe, à ce que le Premier ministre mette en oeuvre, à compter du 15 mai 2024, simultanément à l'état d'urgence, l'interruption du service de communication au public en ligne "TikTok" décidée la veille, pour des motifs autres que ceux relatifs à la lutte contre le terrorisme, sous réserve qu'eu égard aux < circonstances > < exceptionnelles > prévalant sur le territoire néo-calédonien, aucune des autres mesures prévues par la loi du 3 avril 1955, non plus qu'aucune des mesures de droit commun susceptibles d'être prises, ne fût de nature à pourvoir aux nécessités du moment. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale, au motif que les conditions prévues par le II de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 n'étaient pas remplies pour procéder à l'interruption du réseau social "TikTok", et que le Premier ministre était incompétent pour procéder à la suspension de ce service. L'association "La Quadrature du net" n'est pas davantage fondée, en tout état de cause, à soutenir que l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquels les restrictions à la liberté d'expression doivent être prévues par la loi, feraient obstacle à ce qu'il soit porté atteinte à cette liberté sur le fondement de < circonstances > < exceptionnelles >, dès lors que la possibilité ouverte à l'autorité administrative de prendre des mesures excédant le champ normal de ses compétences, en cas de survenue de telles < circonstances >, dans les conditions rappelées au point 2, résulte d'une jurisprudence bien établie constituant, par suite, une base légale suffisamment prévisible au sens et pour l'application de ces stipulations.

10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'alors que la Nouvelle-Calédonie connaissait, ainsi qu'il a été dit au point 8, des troubles à l'ordre public d'une particulière gravité, le service de communication au public en ligne "TikTok" a été utilisé pour diffuser des contenus incitant au recours à la violence et se propageant très rapidement, compte tenu des algorithmes auxquels recourt ce réseau auprès de ses utilisateurs. Le Premier ministre, faisant le constat que l'utilisation de ce service était de nature à aggraver la situation et à compromettre le rétablissement de l'ordre public, était en droit, au vu des < circonstances > < exceptionnelles > prévalant alors, et en l'absence d'autres moyens techniques immédiatement disponibles, de décider de l'interruption provisoire du service de communication au public en ligne "TikTok", pour une durée déterminée n'excédant pas celle nécessaire à la recherche et à la mise en oeuvre, le cas échéant en lien avec le fournisseur du service, de mesures alternatives permettant d'atteindre l'objectif recherché et moins attentatoires aux droits et libertés en cause, telles, notamment, que le blocage de certaines fonctionnalités du réseau. Or la décision attaquée procède à une interruption totale du service pour une durée indéterminée, liée seulement à la persistance des troubles à l'ordre public, sans subordonner son maintien à l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures alternatives. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que le Premier ministre a ainsi porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, à la liberté de communication des idées et opinions et à la liberté d'accès à l'information.

11. Il résulte de ce qui précède que la Ligue des droits de l'homme, l'association "La Quadrature du net" et M. C... et autres sont fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent.

12. Il y a lieu, dans les < circonstances > de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 € à verser respectivement à la Ligue des droits de l'homme, à l'association "La Quadrature du net" et à M. C... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ».

« DÉCIDE :

Article 1er : La décision du Premier ministre du 14 mai 2024 interrompant l'accès au service de communication au public en ligne "TikTok" en Nouvelle-Calédonie est annulée.

Article 2 : L'État versera respectivement, sous le n° 494511, à la Ligue des droits de l'homme, sous le n° 494583, à l'association "La Quadrature du net" et, sous le n° 495174, à M. C... et autres, une somme de 3 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

## **Document n° 7 : Th. Perroud, « Liberté d'expression et circonstances exceptionnelles : le contrîole du Conseil d'Etat sur l'interdiction de TikTok et l'inauguration d'un contrpole de proportionnalité dynamique », *Légipresse* 2025, p. 347.**

Il faut préciser d'emblée l'absence de portée pratique de l'arrêt commenté du Conseil d'État du 1er avril 2025. Il s'agit d'une décision intéressante uniquement pour le droit puisque, l'ensemble des recours en urgence ayant été rejeté à la suite de la décision prise par le Premier ministre le 14 mai 2024, sur le fondement de la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles >, d'interrompre l'accès au service de communication au public en ligne TikTok en Nouvelle-Calédonie pendant quatorze jours, ce réseau social a effectivement été banni pendant la période indiquée. Cette décision n'est donc pas une victoire pour les libertés, mais pour le droit. Ce n'est pas le seul exemple dans la jurisprudence du Conseil d'État d'arrêt « de façade » : il faut se rappeler que, dans la fameuse affaire Benjamin (1), qui a amené le Conseil d'État à bannir les mesures d'interdiction en matière de liberté publique - ici la liberté de réunion -, l'auteur en question n'a pas pu faire sa conférence, l'arrêt étant intervenu plusieurs années après et la décision de police étant immédiatement exécutoire. C'est le même problème ici. Il s'agit donc d'un arrêt pour la beauté du geste, mais qui fixe néanmoins des principes importants.

Inutile de préciser les faits à l'origine de cette affaire, ils sont suffisamment connus ; Le Monde s'est d'ailleurs récemment fait l'écho des ravages économiques(2) provoqués par les émeutes ayant affecté la Nouvelle-Calédonie, dans un contexte décolonial qu'il faut avoir à l'esprit, puisque la toile de fond de ces événements est la question de l'indépendance. La réalité des troubles à l'ordre public à l'origine de cette décision n'est donc pas discutée.

Le complexe de décisions à l'origine du litige est le suivant : le 15 mai 2024, à la suite d'un conseil de défense, le président de la République déclencha l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-

Calédonie(3). En dehors de ce cadre juridique, le Premier ministre a souhaité aller plus loin dès le 14 mai, en considérant que l'organisation des exactions était « largement facilitée par l'utilisation des réseaux sociaux et, particulièrement, du fait de ses caractéristiques spécifiques, du réseau social TikTok », et a donc suspendu l'accès à ce réseau depuis la Nouvelle-Calédonie, à compter du 15 mai et jusqu'au 29 mai 2024, et ce, par une décision non formalisée, révélée dans la presse(4).

La gestion de la crise en Nouvelle-Calédonie a donc procédé, d'une part, des pouvoirs dont l'administration dispose en vertu du régime de l'état d'urgence (loi du 3 avr. 1955) et, d'autre part, de la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles >. Mais il faut signaler d'emblée la curiosité de la situation juridique : l'emploi des < circonstances > < exceptionnelles > par le Premier ministre s'est aussi manifesté par l'absence de formalisation de la décision, qui s'est traduite par un ordre adressé aux fournisseurs d'accès à internet et à l'Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie de bloquer l'accès à TikTok.

Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) dont, notamment, la Ligue des droits de l'homme et la Quadrature du Net, ont formé un recours contre cette décision, motif pris de son illégalité, car portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication.

L'apport de cette décision est double. D'une part, elle prend position sur la source du pouvoir du Premier ministre, et sur la possibilité pour celui-ci d'invoquer la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles > pour fonder sa décision. Elle retient que cette décision est légale : le Premier ministre pouvait, en effet, utiliser cette < théorie > pour prendre cette décision. C'est d'ailleurs l'intérêt le plus grand de cet arrêt que de prendre position sur l'articulation entre les différentes sources des pouvoirs de crise de l'administration et la façon dont la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles > peut venir les compléter. D'autre part, cette décision précise le degré de contrôle du juge sur les décisions prises sur le fondement de cette < théorie >. C'est sur cet aspect que la décision tombe : le Conseil d'État annule cette décision non formalisée, estimant qu'elle a porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales. L'interdiction posée par le Premier ministre fut totale et de durée indéterminée ; ce faisant, elle ne passe pas le test de nécessité, caractéristique du contrôle de proportionnalité qui impose à l'autorité publique de choisir, parmi l'ensemble des mesures qui permettent de contenir un trouble à l'ordre public, celle qui est la moins attentatoire aux droits et libertés. Ici, il n'était pas prouvé que des mesures moins restrictives n'auraient pas suffi.

Ainsi, si le ministre pouvait utiliser la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles > pour interdire l'accès aux réseaux sociaux (I), la mesure est néanmoins jugée disproportionnée (II).

I - Une mesure fondée sur l'application de la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles >
La décision du Premier ministre est fondée sur la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles >. Elle intervient cependant dans le champ de l'état d'urgence. Pouvait-il utiliser les pouvoirs qu'il tient de cette < théorie >, alors même qu'un régime législatif < exceptionnel > est déclenché ? Telle est la question que doit résoudre le Conseil d'État.

Il convient d'abord de présenter les quatre régimes d'exception, dont deux sont de rang constitutionnel, un de rang législatif et le dernier tient sa source dans la jurisprudence. Le premier, de rang constitutionnel, est

l'état de siège prévu à l'article 36 de la Constitution. Ce régime est d'abord consacré pour la première fois dans deux lois, du 9 août 1849 et du 3 avril 1878, avant d'être constitutionnalisé en 1946. Il figure depuis à l'article 36 de la Constitution de 1958. C'est le régime le plus attentatoire aux libertés publiques puisque, décrété en Conseil des ministres en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée, il entraîne la substitution de l'autorité militaire à l'autorité civile pour l'exercice du pouvoir de police.

Le deuxième est l'article 16 de la Constitution. Il est entre les mains du président de la République. La Constitution précise les conditions limitatives et graves en vertu desquelles il peut être déclenché, sur lesquelles aucun contrôle juridictionnel ne peut être exercé, le Conseil d'État ayant jugé que la décision de mettre en oeuvre l'article 16 est un acte de gouvernement et que, de surcroît, si les mesures prises par le président de la République dans ce cadre entrent dans le champ de l'article 34, elles ont valeur législative, ce qui exclut de fait sa compétence(5). Le seul contrôle juridictionnel possible est celui du Conseil constitutionnel qui peut être saisi après trente jours d'exercice de ces pouvoirs pour vérifier que les conditions posées par la Constitution à son utilisation sont bien réunies. Il n'a connu qu'une seule application.

Le troisième, de rang législatif, est l'état d'urgence prévu par la loi du 3 avril 1955. Il peut être déclenché en cas de péril imminent ou de calamité publique. Il est mis en oeuvre par décret en Conseil des ministres, et ne peut être prorogé au-delà de douze jours par la loi. Il accroît les pouvoirs de police administrative en permettant à cette autorité de prendre des décisions qui sont normalement de la compétence de l'autorité judiciaire, étant attentatoires aux droits et libertés, et particulièrement à la liberté d'aller et venir, à la protection du domicile (assignation à résidence, perquisitions, interdictions de réunion, etc.). Le juge administratif exerce désormais un contrôle entier sur les mesures individuelles prises dans ce cadre(6).

Enfin, le dernier régime d'exception est la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles >, d'origine jurisprudentielle(7). Comme l'explique la rapporteure publique, Esther de Moustier, suivie en cela par le Conseil d'État, l'application de ce régime requiert que soient réunies cinq conditions :

- deux conditions tiennent à la nature des < circonstances > qui doivent, d'une part, être < exceptionnelles > et, d'autre part, mais de façon non limitative (« notamment », dit le Conseil d'État), porter atteinte de façon grave à certains intérêts listés par le juge : entraver le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, compromettre de manière immédiate la santé de la population ou son accès aux services essentiels, ou porter atteinte à l'ordre public. Au titre de cette condition, il y a donc un critère temporel (un cas < exceptionnel >), un critère matériel ouvert et, enfin, un critère de gravité ;

- une condition tient au but à atteindre, qui est de « pourvoir aux nécessités du moment ». Le Conseil d'État est, ici, volontairement vague ;

- enfin, et de façon liée, le type et le degré de contrôle lient l'ensemble de ces conditions : « Les mesures doivent être indispensables au regard des < circonstances > prévalant à la date de la décision, sous l'entier contrôle du juge administratif ». Le juge exerce donc un contrôle de proportionnalité sur l'adéquation, la nécessité et la proportionnalité de la mesure.

Il y a donc quatre régimes d'exception, dont deux sont en jeu dans cette affaire. L'intérêt principal de l'arrêt est de réfléchir et de donner une solution à l'articulation entre l'état d'urgence et la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles >, et ce, en ces termes : « [La déclaration d'état d'urgence] ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative use, lorsque des < circonstances > < exceptionnelles > l'exigent, des pouvoirs mentionnés au point 2 [qui procèdent de l'utilisation de la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles >] pour prendre d'autres mesures que celles relevant de la loi du 3 avril 1955, lorsqu'aucune de ces dernières mesures, pas davantage que celles relevant d'autres régimes d'exception ou de droit commun, n'est de nature à répondre aux nécessités du moment ».

Comment s'articulent ces deux régimes ? En cas d'application concurrente, la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles > ne peut avoir qu'un rôle subsidiaire. Il faut que l'administration se trouve dans l'impossibilité d'agir dans un cadre légal, que celui-ci soit un régime d'exception. On se trouve ici dans un cas d'exception au carré, qui explique la rigueur du contrôle que l'on verra plus loin. L'administration doit non seulement prouver l'existence de < circonstances > < exceptionnelles >, mais en plus qu'elle était dans l'impossibilité d'utiliser le régime légal de l'état d'urgence - régime qui, dans notre cas, sera déclenché le lendemain de la mesure examinée.

La difficulté ici tenait au fait que la mesure en question - l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux - est une mesure prévue par l'article 11-II de la loi de 1955 sur l'état d'urgence : « Le ministre de l'Intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ».

Les requérants invoquaient donc une forme de critère de préemption : la mesure étant prévue par la loi de 1955 dans un contexte unique, elle fait obstacle à son utilisation sur le fondement de la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles >. Cet argument est rejeté par le juge. Il ressort de cette jurisprudence la vigueur de la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles > qui peut en réalité être invoquée en complément, pour approfondir, pour compléter, mais aussi éventuellement contre la loi de 1955 - c'est l'hypothèse qu'envisage la rapporteure publique - du moment que les < circonstances > le justifient.

La < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles > est une < théorie > pragmatique qui instaure un régime d'exception, dont la légitimité repose entièrement sur la nature des < circonstances > qui l'appellent, donc sur l'impossibilité pour l'administration d'y faire face autrement. Sa légitimité tient aussi à la rigueur du contrôle juridictionnel du Conseil d'État, dont nous avons un exemple éclatant ici - bien que platonique - puisque la mesure est annulée.

II - Une mesure objet d'un contrôle de proportionnalité dynamique

Nous avons précisé plus haut le standard de contrôle. Il est ici d'autant plus rigoureux que la mesure en question porte sur un droit fondamental éminent : la liberté d'accéder à internet procède pour le Conseil constitutionnel de l'article 11 de la Déclaration de 1789. Il avait considéré « qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des

idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services [internet] »(8). Dans deux décisions plus récentes, le Conseil constitutionnel a ajouté à la liberté d'accès à internet, la liberté de s'y exprimer(9). On se rappelle en effet que dans sa décision HADOPI 1, celui-ci a censuré la possibilité pour l'administration de prononcer une sanction administrative de coupure d'internet en cas de téléchargement illégal.

Le Conseil d'État s'aligne ici complètement sur le raisonnement du Conseil constitutionnel et copie quasiment mot pour mot le considérant de ce dernier : « En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique, économique et sociale et l'expression des idées et des opinions, la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, implique la liberté d'accéder à ces services et de s'y exprimer ».

Qu'ajoute le Conseil d'État ? Il estime que l'accès à internet participe non seulement de la vie démocratique - comme le Conseil constitutionnel - mais aussi de la vie économique et sociale. Ensuite, il reprend le considérant le plus récent du Conseil constitutionnel pour estimer que l'article 11 implique non seulement le droit d'accéder à internet, mais aussi de s'y exprimer. Ce dernier ajout est important pour les réseaux sociaux, bien sûr.

Le Conseil d'État se place ici nettement dans les pas du Conseil constitutionnel. Dans ce cadre, le contrôle du juge ne pouvait être que rigoureux. Le Conseil d'État précise que l'administration ne peut recourir à une telle mesure, en cas de < circonstances > < exceptionnelles >, que « si elle est indispensable pour répondre aux nécessités du moment ». Elle doit être provisoire et mettre en oeuvre un strict test de nécessité ; le Conseil d'État précise les deux conditions cumulatives du contrôle : d'une part, aucun moyen technique ne doit pouvoir permettre, dans l'immédiat, de prendre des mesures alternatives moins attentatoires aux droits et libertés en cause, et, d'autre part, l'interdiction doit être prise pour une durée n'excédant pas celle requise pour rechercher et mettre en oeuvre de telles mesures.

Ce test est décisif, car il met bien en évidence tout le poids que le juge attache à la liberté de communication, par ce double test, qui met en place une sorte de réponse graduée en matière de liberté de communication. D'une part, il incombe à l'administration la charge de la preuve qu'elle a, avant de prendre la mesure, mis sur la table et pesé les avantages et les inconvénients de chaque option qui pouvait atteindre l'objectif recherché - à savoir mettre fin aux troubles - et qu'elle a pris, parmi l'ensemble de ces options, la mesure la plus respectueuse de la liberté en cause. Elle devra donc prouver au juge qu'elle a recherché l'ensemble des options politiques disponibles.

D'autre part, le Conseil d'État impose, pour prendre une analogie guerrière, une forme de réponse graduée : si jamais l'administration prenait la mesure d'interdiction, celle-ci devrait être strictement limitée dans le temps, pour laisser progressivement la place aux mesures moins attentatoires à la liberté de communication que l'administration n'aurait pas manqué de repérer au titre de la première étape du test. C'est en ce sens que l'on peut parler d'un contrôle de proportionnalité renforcé, car le contrôle porte sur la durée.

Pour reprendre les termes de la rapporteure publique : « Au triple test de proportionnalité que vous appliquez aux mesures de police administrative classiques, nous vous proposons ainsi d'ajouter une exigence, eu égard aux effets de la mesure en cause, consistant à subordonner sa légalité à l'absence de mesures moins attentatoires non seulement à la date de son adoption, mais aussi le temps de son application, ce, malgré les efforts de l'administration ».

Dans l'hypothèse envisagée par la rapporteure publique, ce contrôle de proportionnalité dynamique impose d'adapter dans le temps l'intensité de la mesure avec l'évolution des < circonstances > : l'administration a identifié l'ensemble des mesures disponibles, leur efficacité par rapport à l'objectif et le niveau d'atteinte qu'elles portent à la liberté de communication ; il serait indiqué, si les < circonstances > le justifient, qu'elle commence par la mesure la moins attentatoire, pour graduer ensuite sa réponse en fonction de l'évolution des < circonstances >. Gageons que cette façon de faire permettrait de remplir pleinement les conditions du test en montrant la volonté de l'administration de considérer la liberté de communication à sa juste valeur.

Au cas d'espèce, le Conseil d'État reproche au Premier ministre plusieurs choses, qui scellent le sort de la décision : celui-ci n'a pas cherché, en concertation avec le fournisseur de service, à bloquer certaines fonctionnalités du réseau. Le Conseil d'État reproche ainsi à la décision de procéder « à une interruption totale du service pour une durée indéterminée, liée seulement à la persistance des troubles à l'ordre public, sans subordonner son maintien à l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures alternatives ». Comme l'explique Esther de Moustier, il est au fond reproché au Premier ministre de n'avoir pas essayé de dialoguer avec le fournisseur de service pour lui permettre de réagir. Elle constate ainsi qu'« aucune demande ou mise en demeure [...] n'a été adressée aux représentants de TikTok, ne serait-ce que pour lui enjoindre d'intensifier la modération prévue par ses propres conditions générales d'utilisation ». Esther de Moustier estime que « la décision est viciée ab initio, dans sa conception, faute d'être envisagée comme une solution de dernier recours, motivée non par la seule existence de troubles, mais aussi par l'absence d'autres possibilités techniques, ou d'être accompagnée, dans les faits, d'une recherche de solutions alternatives ». La rapporteure publique le dit : faute pour cette décision d'avoir été formalisée, le Premier ministre ne peut pas apporter la preuve du souci qu'il a eu de protéger la liberté de communication.

Il faut en conclure deux choses. D'une part, que l'absence de formalisation d'une décision interdit dans ce cas - on le comprend facilement - de pouvoir administrer la preuve requise par le test imposé par le Conseil d'État. D'autre part - c'est décisif - que la mise en demeure à un réseau social d'intensifier sa modération, est une mesure qui peut faire partie de la réponse graduée dans le cadre de l'utilisation de la < théorie > des < circonstances > < exceptionnelles > lorsque celle-ci viole la liberté de communication.

La solution réjouira les défenseurs des libertés publiques. Mais, au fond, cette belle décision, ne procède-t-elle pas d'une autre logique ? Beaucoup d'éléments dans le dossier montrent la précipitation et d'abord l'absence de formalisation de la décision. N'est-ce pas une preuve flagrante de l'urgence ? Si l'administration est en possibilité de suivre le test du Conseil d'État et de mettre en place « un plan de guerre », une stratégie graduée conciliant liberté et ordre public, est-on vraiment en < circonstance > < exceptionnelle > ? Le test du Conseil d'État est de bonne administration. Mais a-t-il une portée pratique réelle en situation d'urgence ?

Ne faut-il pas ranger cette décision dans l'ensemble de celles prises dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir désincarné et platonique puisque, rappelons-le, l'interdiction a bien été mise en oeuvre ?

Pour filer la même image que celle que dessina Maurice Hauriou, la décision en recours pour excès de pouvoir, à la différence de l'étoile justement, est peut-être d'autant plus lumineuse qu'elle est éloignée des faits(10).

**

(1) CE 19 mai 1933, n° 17413, Benjamin et Syndicat d'initiative de Nevers, Lebon.
(2) M. Derel, Sur le Caillou, une réforme économique et fiscale bloquée faute de consensus, Le Monde, 7 mai 2025.
(3) Décr. n° 2024-436 du 15 mai 2024 portant application de la loi du 3 avr. 1955 (pour une période de 12 jours).
(4) V. concl. de Mme de Moustier sous cet arrêt.
(5) CE, ass., 2 mars 1962, nos 55049, 55055, Rubin de Servens, Lebon.
(6) CE, sect., 11 déc. 2015, n° 395009, Lebon avec les concl. ; AJDA 2016. 247, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; ibid. 2015. 2404 ; AJCT 2016. 202, étude J.-C. Jobart ; RFDA 2016. 105, concl. X. Domino ; ibid. 123, note A. Roblot-Troizier.
(7) CE 28 juin 1918, n° 63412, Heyriès, Lebon.
(8) Cons. const. 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, AJDA 2009. 1132 ; D. 2009. 1770, point de vue J.-M. Bruguière ; ibid. 2045, point de vue L. Marino; ibid. 2010. 1508, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; Dr. soc. 2010. 267, chron. J.-E. Ray ; RFDA 2009. 1269, chron. T. Rambaud et A. Roblot-Troizier ; Constitutions 2010. 97, obs. H. Périnet-Marquet ; ibid. 293, obs. D. de Bellescize ; RSC 2009. 609, obs. J. Francillon ; ibid. 2010. 209, obs. B. de Lamy ; ibid. 415, étude A. Cappello ; RTD civ. 2009. 754, obs. T. Revet ; ibid. 756, obs. T. Revet ; RTD com. 2009. 730, étude F. Pollaud-Dulian.
(9) Cons. const. 18 juin 2020, n° 2020-801 DC, Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, § 4,Légipresse 2020. 336 et les obs. ; ibid. 2021. 240, étude N. Mallet-Poujol ; ibid. 291, étude N. Mallet-Poujol ; AJDA 2020. 1265 ; D. 2020. 1297, et les obs. ; ibid. 1448, entretien C. Bigot ; AJ pénal 2020. 407, note N. Droin ; Dalloz IP/IT 2020. 542, étude F. Potier ; ibid. 577, obs. B. Bertrand et J. Sirinelli.
(10) M. Hauriou, Recevabilité de la tierce opposition contre une décision sur recours pour excès de pouvoir, note ss CE 29 nov. 1912, n° 45893, Boussuge, Lebon.

## <u>Document n° 8</u> : P. Py, « Pouvoir discrétionnaire, compétence liée, pouvoir d'injonction », Dalloz 2000, p. 563

1 - La distinction entre pouvoir discrétionnaire et compétence liée est une des plus traditionnelles et des plus classiques du droit administratif français puisque c'est à la suite de Laférière que les auteurs de droit administratif opposent ces deux situations antithétiques (1).

L'homogénéité du contenu des définitions est constante et s'inspire de celle proposée par Michoud dans un article paru en 1914 : « Il y a < pouvoir > < discrétionnaire > toutes les fois qu'une autorité agit librement sans que la conduite à tenir lui soit dictée à l'avance par une règle de droit » (2) et il y a compétence liée (3) lorsque l'Administration « prend des décisions qui sont d'avance dictées par la loi. Elle n'a d'autres tâches que d'appliquer la loi au cas particulier qui motive sa décision ».

Sous la diversité des formules la distinction proposée par Michoud est reprise et précisée par la plupart des auteurs depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Mais, si la distinction entre pouvoir discrétionnaire et compétence liée est clairement exposée par l'ensemble de la doctrine, elle est relativisée (4), ce qui conduit à une confusion de ces concepts.

2 - La doctrine ne traduit pas la distinction pouvoir discrétionnaire /compétence liée par un dualisme catégorique des actes administratifs. Le Doyen Vedel expose le caractère purement théorique de l'opposition : « Lorsqu'elle prend une décision, l'Administration peut idéalement se trouver dans une situation de compétence liée ou de pouvoir discrétionnaire ... En réalité, l'Administration ne se trouve jamais dans une situation de pur pouvoir discrétionnaire ou de pure compétence liée » (5). La démonstration de l'absence de pur pouvoir discrétionnaire et de pure compétence liée est reprise par la grande majorité de la doctrine et elle aboutit à établir la frontière de la compétence liée et du pouvoir discrétionnaire à l'intérieur des actes administratifs ainsi qu'à l'idée de degrés de la compétence liée.

3 - Or, s'il est certain qu'il n'existe plus d'actes discrétionnaires depuis le début du siècle (6), il existe des actes liés correspondant au sens strict de la notion de compétence liée qui n'est pas une situation « idéale », mais bien réelle dans laquelle peut se trouver l'Administration. Il existe donc un dualisme catégorique du pouvoir discrétionnaire et de la compétence liée, dualisme qui n'était qu'indirectement révélé et mis en œuvre avant le pouvoir d'injonction octroyé au juge administratif par la loi n° 95-125 du 8 févr. 1995 (7) relative à l'organisation des juridictions civile, pénale et administrative et qui l'est directement depuis l'entrée en vigueur de cette loi.

## I - Le dualisme catégorique du pouvoir discrétionnaire et de la compétence liée

La distinction entre le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée ne se traduit pas par une différence de degré entre deux extrêmes au sein des actes administratifs, mais par l'existence de deux catégories d'actes administratifs : les actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire et les actes liés. Mais ce dualisme catégorique était masqué par l'absence d'un pouvoir d'injonction conféré au juge administratif.

Partant d'une opposition exacte entre pouvoir discrétionnaire et compétence liée, la doctrine, en refusant d'admettre la réalité concrète de cette opposition et en appliquant la notion de compétence liée à chaque élément de l'acte administratif, a assimilé la notion de compétence liée et le principe de légalité : « A cette thèse, très généralement admise, que la notion de compétence liée « se rattache traditionnellement au principe de légalité », il faut apporter quelques précisions. Il semble en effet qu'elle aboutit chez certains auteurs à une confusion totale entre la notion de compétence liée et le principe de légalité alors que si la notion de compétence liée est, certes, un aspect du principe de légalité, elle en est en vérité un aspect

extrêmement particulier » (8).

Cette confusion entre compétence liée et principe de légalité ou entre compétence liée et compétence réglementée disparaît si l'on situe l'opposition entre compétence liée et pouvoir discrétionnaire au niveau des actes administratifs et non pas à l'intérieur de ceux-ci.

Une telle démarche est adoptée par M. Letourneur qui s'efforce de classer les actes administratifs au regard des pouvoirs de contrôle du juge, c'est-à-dire au regard de leur condition de légalité (9). M. Letourneur propose de classer les actes administratifs en trois catégories :

- les actes pour lesquels l'Administration a compétence liée ;
- les actes pour lesquels elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire ;
- les actes pour lesquels l'action de l'Administration est subordonnée au respect de certaines conditions imposées par la loi, conditions qui limitent sa liberté (10).

On adoptera la même démarche en répartissant toutefois les actes administratifs en seulement deux catégories : les actes liés et les actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la troisième catégorie isolée par M. Letourneur n'étant qu'une variété de la seconde. Mais cette classification dualiste est restée, jusqu'à la mise en vigueur de la loi du 8 févr. 1995, masquée par l'absence d'un pouvoir d'injonction conféré au juge administratif.

A - La distinction entre les actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire et les actes liés

La distinction entre les actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire et les actes liés correspond à la distinction entre les actes exercice d'un pouvoir de vouloir et les actes exécution d'une obligation de vouloir que l'on proposait dans une étude sur le rôle de la volonté dans les actes administratifs unilatéraux (11). Si l'on modifie la qualification des deux catégories d'actes administratifs, c'est que ces nouvelles dénominations paraissent plus explicites.

On exposera sommairement la distinction, l'objet de cet article étant essentiellement de montrer comment elle est consacrée par l'avènement du pouvoir d'injonction conféré au juge administratif. Le dualisme catégorique des actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire et des actes liés était déjà souligné par Carré de Malberg qui montrait qu'il y a lieu de faire entre les actes pris à la suite des lois par les autorités publiques « une distinction générale selon qu'ils se bornent à reproduire, en l'appliquant à une espèce actuelle, une règle de droit fixée de toute pièce et *ne varietur*, pour toutes les espèces de ce genre soit par la loi, soit par un autre acte antérieur à eux et qui leur impose sa supériorité, ou qu'au contraire ils édictent une mesure ou une décision dont l'adoption dépendait plus ou moins librement de facultés d'appréciations propres appartenant à leur auteur en vertu des règles de droit en vigueur. Il est manifeste, à tout le moins, que la portée créatrice de l'activité exercée par les autorités compétentes n'est pas la même dans les deux cas » (12).

Ainsi, toutes les fois que la règle posée par la loi fixe par elle-même et intégralement sur le point qu'elle vise le droit qu'auront à appliquer les autorités subordonnées au législateur, « il y a lieu ...de substituer à la théorie

de la gradation de la formation du droit la constatation d'une gradation qui ne porte que sur les états successifs du droit créé par la loi et s'acheminant vers son exécution » (13).

Les propos de Carré de Malberg nous invitent donc à distinguer les actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui ont un caractère créatif des actes liés ayant un caractère déclaratif et obligatoire.

*1 - Le caractère créatif des actes exercice d'un* pouvoir discrétionnaire

La norme juridique organisatrice d'un pouvoir discrétionnaire laisse toujours subsister une faculté de choix pour l'auteur de l'acte. Au minimum, elle prévoit l'existence d'un pouvoir octroyé à une volonté : si une règle de droit n'a pas attaché à une manifestation de volonté la possibilité de produire des effets de droit, ceux-ci ne pourront valablement se produire.

Mais, nécessaire, la norme juridique joue dans les actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire un rôle limité : elle fournit seulement les éléments nécessaires à l'action de la volonté de l'auteur de l'acte. Dans ces actes, la naissance de la situation juridique des effets de droit dépend uniquement de la volonté de l'auteur de l'acte. La réaction que constitue tout acte juridique en face d'une situation objective de fait ou de droit est déterminée librement, dans le cadre de la réglementation, par la volonté de l'auteur de l'acte.

*2 - Le caractère déclaratif et obligatoire des actes liés*

La norme juridique organisatrice d'une compétence liée crée une obligation de résultat et ne laisse à l'autorité compétente aucune faculté pour échapper aux effets de l'obligation qu'elle crée. Ainsi, M. Letourneur range dans la catégorie des actes pour lesquels l'Administration a une compétence liée « les actes pour lesquels l'autorité administrative est, par la loi, d'une part, tenue d'agir, d'autre part, tenue d'agir dans un sens déterminé » (14).

Si l'acte est ainsi lié, c'est parce que le rapport de droit existant entre l'administré et l'Administration est créé directement par la norme organisatrice de la compétence liée. Ainsi, dans les actes liés, la volonté de l'auteur de l'acte ne joue qu'un rôle formel. Elle met fin à l'inefficacité pratique et juridique dont était entaché un droit ou une obligation en les constatant. La constatation d'un droit ou d'une obligation consiste dans le constat par l'auteur de l'acte de la situation objective qui leur donne naissance et dans le fait de tirer les conséquences nécessaires de ce constat. C'est bien ce que fait l'autorité administrative lorsqu'elle prend un acte lié qui de ce fait est purement déclaratif et obligatoire puisque cette autorité est tenue d'agir.

La distinction entre les actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire et les actes liés correspond donc bien à une réalité ancienne, mais elle était masquée par l'absence d'un pouvoir d'injonction conféré au juge administratif.

<u>B - L'absence d'un pouvoir d'injonction masque de la distinction entre les actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire et les actes liés</u>

Les limitations des pouvoirs du juge administratif et notamment l'absence d'un pouvoir d'injonction sont source pour l'Administration d'un pouvoir discrétionnaire anormal qu'il faut distinguer du pouvoir discrétionnaire normal. Le caractère anormal de ce pouvoir discrétionnaire, qui rend floue la distinction entre les actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire et les actes liés, n'a pas empêché le juge administratif de consacrer indirectement, en l'absence d'un véritable pouvoir d'injonction, la distinction des actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire et des actes liés.

*1 - Le dualisme du pouvoir discrétionnaire*

Le pouvoir discrétionnaire « normal » constitue un pouvoir octroyé par la norme organisatrice de ce pouvoir. L'idée du pouvoir discrétionnaire est celle de « l'autonomie de l'Administration, de pouvoirs indépendants à elle attribués » et « l'idée de pouvoir discrétionnaire postule pour l'Administration l'indépendance dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus, la liberté d'action à l'intérieur des limites tracées par la règle de droit » (15). Cette idée est occultée par la doctrine classique qui voit dans le pouvoir discrétionnaire une résistance à l'hégémonie de la loi (16).

Au contraire, dans la mesure où le pouvoir discrétionnaire est un pouvoir de libre appréciation, il convient de substituer « à la conception classique, essentiellement négative, une conception positive du pouvoir discrétionnaire » (17). Mais à côté de ce pouvoir discrétionnaire « normal », il existe un pouvoir discrétionnaire « anormal » quand l'Administration est dans une situation de compétence liée.

Dans une telle hypothèse, l'Administration continue « à manifester son pouvoir, à user de son aptitude légale à émettre un acte juridique » (18). En effet, « il est des actes dont on a besoin qu'ils soient faits, même s'ils sont obligatoires pour leurs auteurs : autorisations, nominations, délivrance de décisions. La compétence de l'Administration est à leur sujet l'expression d'un pouvoir par rapport aux administrés ; ces derniers ont besoin, pour obtenir satisfaction et que leur situation juridique soit modifiée dans le sens demandé, que l'acte juridique soit édicté » (19). Sans l'intervention des actes liés, les droits des administrés seront inefficaces, entravés dans leur exercice.

Mais la compétence liée est source d'un droit à l'acte pour les administrés. « L'expression de « droit à l'acte » traduit une réalité qui est caractéristique de la compétence liée » (20).

Si un pouvoir discrétionnaire de l'Administration subsiste dans les hypothèses de compétence liée, c'est parce que « le juge ne pouvant, en principe, donner d'injonction à l'Administration ni se substituer à elle, l'inertie des pouvoirs publics, leur refus d'utiliser le pouvoir qu'ils détiennent ne peuvent être palliés » (21). Ainsi, « la portée de ce « droit à l'acte » se trouve singulièrement réduite lorsque l'Administration fait preuve d'une inertie obstinée, car le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction alors même que l'Administration a compétence liée » (22).

La prohibition du pouvoir d'injonction, qui est sans contexte une des règles les mieux établies du droit administratif français (23), est généralement fondée sur le principe de séparation de la juridiction

administrative et de l'Administration active : « D'une part, l'indépendance de l'Administration active l'empêcherait de recevoir des ordres formels de la part du juge administratif... D'autre part, en adressant des ordres à l'Administration, le juge administratif s'immiscerait dans le fonctionnement des services publics et deviendrait l'administrateur supérieur » (24). Mais le pouvoir discrétionnaire fondé sur le principe de séparation de la juridiction administrative et de l'Administration active n'apparaît pas seulement différent du pouvoir discrétionnaire fondé sur la norme organisatrice d'un tel pouvoir : il est totalement anormal. En effet, « aucun obstacle réel ne s'oppose en fait à la reconnaissance du pouvoir d'injonction en faveur des juridictions administratives. Loin d'être incompatible avec le statut de juge, l'injonction est inhérente à ce statut » (25).

Ainsi l'affirmation implicite sous forme de question du professeur F. Moderne est-elle justifiée : « Etrangère au pouvoir du juge, l'injonction, pourquoi le serait-elle ? » (26).

En l'absence de pouvoir d'injonction, le juge s'est efforcé de faire disparaître le pouvoir discrétionnaire anormal dont disposait l'Administration en matière d'acte lié en consacrant indirectement la distinction des actes liés et des actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire.

*2 - La consécration indirecte de la distinction entre les actes liés et les actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire*

La consécration de la distinction entre ces deux catégories d'actes administratifs a consisté à dégager le régime des actes liés, c'est-à-dire à imposer toutes les conséquences des deux obligations, d'agir et d'agir dans un sens déterminé, que la compétence liée établit à la charge de l'Administration (27).

En l'absence de pouvoir d'injonction plusieurs techniques ont été utilisées par le juge administratif pour imposer les actes liés. La première technique est celle de la substitution de base légale ou de motif : « D'une manière générale, le juge n'est en droit de substituer, ni une base légale à la base légale donnée par l'Administration à son acte, ni un motif légal à un motif illégal invoqué par l'auteur de l'acte, or par exception à ce principe aujourd'hui constant le juge peut opérer une substitution de base légale ou de motifs dans les cas où l'Administration a compétence liée » (28).

La deuxième technique utilisée par le juge administratif pour concrétiser le régime des actes liés est celui du recours à la théorie des moyens inopérants, c'est-à-dire des moyens qui ne peuvent exercer aucune influence sur le sort réservé à l'acte par le juge.

Une troisième technique pour obliger l'Administration à édicter des actes liés consiste pour le juge administratif à rédiger les motifs de ses décisions de telle manière que l'Administration sache exactement comment les exécuter (29) : « il agit un peu dans ce cas comme une autorité de tutelle adressant des instructions officieuses aux organes qu'elle contrôle pour les guider dans leur activité et l'analogie avec un véritable pouvoir d'instruction est frappante » (30).

Une quatrième technique permettant au juge d'imposer indirectement à l'Administration un acte lié peut être évoquée, la formule du renvoi à l'autorité administrative pour faire ce que de droit.

Une dernière technique est employée par le juge administratif pour sanctionner la compétence liée, la mise en jeu de la responsabilité de l'Administration. « Lorsque l'administré a subi un dommage parce que l'Administration n'a pas observé la liaison de compétence qui lui était imposée, il peut en obtenir réparation. En effet, l'Administration commet une faute en ne respectant pas sa compétence liée et, de cette faute, naît pour l'intéressé qui a subi un préjudice le droit d'obtenir des dommages-intérêts » (31).

Toutes ces techniques montrent bien que le juge administratif entend imposer à l'Administration les actes liés, mais elles ne le permettent que de façon indirecte et limitée. La substitution de motifs ou de base légale et la théorie des moyens inopérants supposent qu'un acte lié ait été édicté. La jurisprudence *Rodière* est limitée et se borne à une information de l'Administration. Le renvoi pour faire que de droit est proche de l'injonction, mais il ne s'agit pas d'un ordre direct et contraignant assorti d'une sanction. La mise en jeu de la responsabilité de l'Administration ne permet pas directement aux administrés d'obtenir l'acte lié auquel ils ont droit. Seul l'octroi au juge administratif d'un pouvoir d'injonction pouvait permettre au juge de consacrer directement les obligations de l'Administration quand la légalité lui impose des actes liés. A cet égard la loi n° 95-125 du 8 févr. 1995 constitue bien une révolution.

## II - La consécration et la mise en œuvre du dualisme catégorique du pouvoir discrétionnaire et de la compétence liée par le juge administratif doté d'un pouvoir d'injonction

La prohibition du pouvoir d'injonction du juge administratif à l'égard de l'Administration était aussi fermement condamnée par la doctrine (32) qu'elle était affirmée par la jurisprudence (33). Ainsi, la révolution ne semblait < pouvoir > venir que de la loi et c'est en tout cas d'elle qu'elle est venue. Les art. 62 et 77 de la loi du 8 févr. 1995 introduisent en effet un pouvoir d'injonction et d'astreinte au profit des juridictions administratives en vue de l'exécution des jugements.

La doctrine a, dans son ensemble, salué le caractère novateur et bénéfique de la réforme, même si certains auteurs nuancent sa portée (34). L'octroi au juge d'un pouvoir d'injonction pour l'exécution des jugements présente en tous les cas un intérêt fondamental pour la théorie du pouvoir discrétionnaire et de la compétence liée. Elle permet au juge de consacrer directement et expressément le dualisme catégorique des actes liés et des actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Mais la mise en œuvre de ce dualisme se révèle délicate pour les actes liés.

### A - La consécration du dualisme catégorique des actes liés et des actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire par le juge administratif doté du pouvoir d'injonction

L'art. L. 8-2 c. trib. adm., introduit par l'art. 62 de la loi du 8 févr. 1995, distingue clairement les hypothèses de compétence liée et de pouvoir discrétionnaire (35). L'alinéa 1er de cet article qui vise les hypothèses de compétence liée dispose : « Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même

jugement ou le même arrêt ». L'alinéa 2 de l'art. L. 8-2 qui concerne les hypothèses de pouvoir discrétionnaire prévoit : « Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».

L'art. L. 8-3 c. trib. adm. dispose que le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'art. L. 8-2 d'une astreinte. Par ailleurs, l'art. L. 8-4 organise un pouvoir d'injonction et d'astreinte *a posteriori* et l'art. 6-1 de la loi du 16 juill. 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, issu de l'art. 77 de la loi du 8 févr. 1995, donne au Conseil d'Etat les mêmes pouvoirs en matière d'injonction et d'astreinte que ceux attribués aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel.

L'ensemble de ces dispositions, issues de la loi du 8 févr. 1995, a permis aux juridictions administratives de mettre en œuvre la distinction entre les actes liés et les actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire en faisant disparaître le pouvoir discrétionnaire anormal de l'Administration et en assurant l'obligation pour elle d'exercer son pouvoir discrétionnaire.

*1 - La disparition du* pouvoir discrétionnaire *anormal de l'Administration*

La disparition du pouvoir discrétionnaire anormal de l'Administration qui subsistait à l'égard des actes liés supposait que le juge puisse sanctionner le droit à l'acte en imposant celui-ci à l'Administration. Elle supposait également que soit supprimé le choix du moment dans lequel la majorité de la doctrine voit le minimum de pouvoir discrétionnaire existant dans tous les actes administratifs. LeS nouveaux pouvoirs du juge administratif permettent de réaliser cette double condition.

1°) *Le* pouvoir *d'injonction sanctionne le droit à l'acte* - Ainsi que nous l'avons vu, l'acte lié est à la fois déclaratif et obligatoire. La consécration du droit à l'acte lié suppose donc que le juge constate le droit ou l'obligation de l'Administration objet de l'acte et l'impose à l'Administration. Telle est bien l'action du juge administratif quand il utilise son pouvoir d'injonction dans les hypothèses de compétence liée.

*a) La constatation du droit du requérant ou de l'obligation de l'Administration* - Le prononcé de l'illégalité de l'acte de l'Administration en situation de compétence liée implique la constatation de l'existence d'un droit dont le requérant est créancier ou d'une obligation dont l'Administration est débitrice, indépendamment de la volonté de l'Administration, car ce droit ou cette obligation résulte de règles qui s'imposent à celle-ci.

Les exemples dans lesquels le juge administratif constate l'existence d'un droit du requérant ou d'une obligation de l'Administration impliqué par un jugement sont nombreux. Dans le contentieux de la fonction publique, l'annulation de la révocation ou du licenciement d'un agent implique son droit à réintégration dans

ses fonctions à la date de son éviction. Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que l'annulation d'un arrêté prononçant la révocation de M. Kavvadias implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction (36). Ce droit à la réintégration a été affirmé par le Conseil d'Etat dans plusieurs autres affaires (37) et est complété parfois par le droit à la reconstitution de carrière (38).

Le contentieux de la police des étrangers comprend l'annulation ou le sursis à exécution de reconduites à la frontière, d'arrêtés d'expulsion ou de refus de visa impliquant le droit à diverses autorisations de séjours. Le Tribunal administratif de Paris a par exemple considéré que, eu égard au motif de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'exécution du jugement implique qu'un titre de séjour soit délivré à Mme Ben Guertouh Khadidja (39).

Le Tribunal administratif de Lyon a admis qu'un jugement prononçant le sursis d'un arrêté d'expulsion implique nécessairement que l'intéressé soit autorisé à séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que le préfet statue sur sa demande de renouvellement de titre de séjour (40). Le Conseil d'Etat a jugé qu'un refus de visa illégal entraînait la prescription de la délivrance d'un visa d'entrée en France, reconnaissant ainsi le droit du requérant à ce visa (41) (42).

Le contentieux des inscriptions universitaires a donné au Tribunal administratif de Rennes l'occasion de consacrer le droit à l'inscription des étudiants à certaines conditions (43).

Le contentieux des examens a conduit le Tribunal administratif de Rennes à prononcer le droit à la réorganisation des épreuves d'examen impliqué par l'annulation de la décision du jury prononçant l'ajournement du requérant à l'examen (44). Le contentieux de la loi du 17 juill. 1978 a conduit le Conseil d'Etat à annuler la décision d'un maire refusant de communiquer au requérant les mandats de paiement émis par une commune pendant une période de six années et a enjoint à la commune de communiquer les documents demandés, consacrant ainsi le droit à la communication de ces documents (45). On citera enfin, parmi cette liste non exhaustive de décisions constatant des droits des requérants ou des obligations de l'Administration, un arrêt du Conseil d'Etat considérant qu'il résulte des dispositions de l'art. L. 318-3 c. communes que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, l'attribution d'un local constitue pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale un droit que le maire est tenu de satisfaire dans un délai raisonnable (46).

*b) L'imposition de l'acte lié à l'Administration* - L'imposition de l'acte lié à l'Administration est l'objet même du < pouvoir > d'injonction conféré aux juridictions administratives. Elle est la conséquence du constat du droit du requérant ou de l'obligation de l'Administration. Le juge administratif a ainsi prononcé des injonctions avec ou sans astreintes dans les affaires évoquées ci-dessus. Le juge administratif a notamment ordonné ou prescrit : la réintégration de fonctionnaires (47), la délivrance d'un titre de séjour (48), la délivrance d'un récépissé valant autorisation de séjour (49), l'octroi d'un visa d'entrée en France (50), l'inscription des requérants en première année de DEUG STAPS (51), la réorganisation d'épreuves d'examen dans une université (52), la communication des documents demandés (53).

Ainsi, le pouvoir d'injonction permet au juge administratif d'imposer une obligation de vouloir à

l'Administration et transforme le recours pour excès de pouvoir à l'égard des actes liés en action en déclaration de droit (54). L'action en déclaration de droit « consiste à demander au juge de constater que le requérant est juridiquement fondé à demander à l'Administration compétente de prendre un acte administratif (généralement individuel) déterminé. En d'autres termes, dans le cadre de cette action, le juge administratif déclare que l'Administration a l'obligation légale d'émettre tel acte administratif » (55).

La révolution est d'autant plus importante que disparaît le dernier refuge du pouvoir discrétionnaire dans les actes liés : le choix du moment.

2°) *Le* pouvoir *d'injonction supprime le choix du moment* - L'art. L. 8-2 c. trib. adm. dispose que le juge, saisi de conclusions en ce sens, prescrit la mesure d'exécution impliquée nécessairement par un jugement ou un arrêt assorti, le cas échéant, d'un délai d'exécution. Le juge administratif ne s'est pas privé d'utiliser ce pouvoir de compléter l'obligation de vouloir qu'il impose à l'Administration d'un délai d'exécution soit directement (56), soit en fixant le point de départ de l'astreinte (57). Ainsi disparaît le < pouvoir > de l'Administration du choix du moment et qui selon la grande majorité de la doctrine empêchait que l'Administration soit en situation de pure compétence liée.

*2 - L'obligation pour l'Administration d'exercer son pouvoir discrétionnaire*

L'obligation d'exercer son pouvoir discrétionnaire peut être imposée à une autorité administrative en application de l'art. L. 8-2, al. 2, c. trib. adm. En application de ces dispositions, l'autorité administrative devra simplement prendre une autre mesure après instruction pour tenir compte d'une situation impliquée par le jugement. Elle devra donc exercer son pouvoir discrétionnaire en prenant une nouvelle décision dans un délai déterminé.

Ainsi que l'expose le professeur Guettier, « le domaine dans lequel l'injonction doit se borner à contraindre l'Administration à réexaminer le dossier dans un délai déterminé recoupe essentiellement des hypothèses d'annulation de refus opposé à un administré qui sollicitait un avantage quelconque » (58). L'annulation d'un refus ne correspond pas toujours à des hypothèses de compétence liée.

Deux espèces illustrent des hypothèses dans lesquelles l'Administration possédait un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de l'acte réclamé par le requérant à la suite de l'annulation d'un refus opposé par l'Administration à une demande. Dans la première, le Tribunal administratif de Lyon a annulé un refus de permis de construire, a considéré que cette annulation n'implique pas nécessairement que le maire délivre un permis, mais que l'exécution du jugement implique nécessairement que le maire, saisi à nouveau de plein droit, dès la date de sa lecture, de la demande de permis prenne une décision sur celle-ci après une nouvelle instruction et a prescrit au maire de statuer sur la demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision (59).

Dans la seconde, le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit une décision du ministre de l'Education nationale refusant de renouveler un professeur associé et a considéré que le jugement n'implique pas nécessairement le renouvellement du requérant dans ses fonctions, mais qu'il saisit à nouveau le ministre

chargé de l'Enseignement supérieur de la proposition émanant des instances compétentes de l'université (60). Dans cette affaire, le juge n'a pas prononcé d'injonction imposant à l'autorité compétente de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé car il n'avait pas été saisi de conclusion en ce sens. Ainsi, dans les hypothèses de compétence discrétionnaire, le juge administratif ne peut renvoyer à l'autorité administrative afin qu'elle exerce son pouvoir d'appréciation sur la mesure à prendre, mais elle peut imposer à cette autorité d'exercer dans un certain délai son pouvoir.

B - La mise en œuvre du dualisme catégorique des actes liés et des actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire par le juge administratif doté d'un pouvoir d'injonction

Cette mise en oeuvre soulève des difficultés à l'égard des actes liés. D'une part, la notion d'acte lié a été rendue complexe par le dualisme des sources de la compétence liée. D'autre part, l'appréciation du moment d'appréciation de la liaison de la compétence soulève des difficultés.

*1 - Le dualisme des sources de la compétence liée*

La compétence liée peut trouver sa source dans le texte organisant le < pouvoir > de l'Administration en même temps que le droit d'un administré et l'obligation de l'autorité administrative. Un exemple de cette hypothèse, outre ceux que nous avons rencontrés plus haut, est fourni par l'art. L. 318-3 c. communes qui dispose : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local ». Le Conseil d'Etat n'a pas eu de mal à déduire de ces dispositions que, dans ces communes, l'attribution d'un local constitue pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale un droit que le maire est tenu de satisfaire dans un délai raisonnable (61).

Mais, la compétence liée peut résulter aussi, de manière moins évidente, de l'application par le juge du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation et du principe de conciliation. L'utilisation de la technique de l'erreur manifeste d'appréciation a eu lieu dans deux espèces.

La première concernait un arrêté de reconduite à la frontière. Le Tribunal administratif de Paris a commencé par considérer dans son arrêt que l'autorité compétente disposait bien d'un pouvoir discrétionnaire : « Considérant qu'il est constant que Mme Ben Guertouh, ressortissante marocaine, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'art. 22 de l'ordonnance du 2 nov. 1945 modifiée, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière » (62). Mais le tribunal considéra « que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à l'intérêt de sa présence en France pour ses enfants avec lesquels elle a conservé des liens étroits, la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre le 25 oct. 1995 par le préfet de Paris doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de Mme Ben Guertouh Khadidja ; que celle-ci est, par suite, fondée à en demander l'annulation » et considéra surtout que, eu égard au motif de l'annulation prononcée ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique qu'un titre de séjour soit délivré à Mme Ben Guertouh Khadidja. Ainsi l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la décision de reconduite à la frontière, s'est traduite par l'imposition à l'autorité compétente d'un acte lié, un titre de séjour.

Le Tribunal administratif de Strasbourg a érigé en principe les conséquences de l'erreur manifeste d'appréciation sur la transformation d'un acte exercice d'un pouvoir discrétionnaire en acte lié : «Considérant que, lorsqu'une décision refusant la délivrance d'une autorisation a été annulée par le juge administratif en raison de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'Administration lors de l'examen de la demande, l'autorité administrative qui n'a fondé son refus d'autorisation que sur l'appréciation jugée erronée par la juridiction est tenue, pour assurer une exécution complète du jugement d'annulation, à défaut d'invoquer tout autre élément pouvant justifier le refus ou des circonstances nouvelles, de délivrer ladite autorisation » (63).

La deuxième technique utilisée par le juge pour lier la compétence des autorités administratives est le principe de proportionnalité. Un exemple caractéristique du recours à cette technique est fourni par l'affaire *Epx Bourezak* (64). Dans cette affaire, le Conseil d'Etat commence par rappeler le pouvoir discrétionnaire dont disposait l'Administration : « Considérant que si la venue en France de M. Bourezak, ressortissant algérien, dont l'épouse était titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avait été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir, qui lui appartient, de refuser son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ». Mais l'application du principe de proportionnalité impose un acte lié à l'autorité compétente : « Que toutefois, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvaient justifier les requérants, la décision attaquée a porté une atteinte au respect de leur vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa a été opposé à M. Bourezak, et, par suite, a méconnu les stipulations de l'art. 8 Conv. EDH ». En conséquence, la décision du ministre des Affaires étrangères confirmant le refus du consul général de France de délivrer un visa à M. Bourezak est annulée et il est prescrit à l'autorité compétente la délivrance à M. Bourezak, dans un délai d'un mois, d'un visa d'entrée en France. Ainsi le principe de proportionnalité transforme un acte exercice d'un pouvoir discrétionnaire en un acte lié.

*2 - Le moment de l'appréciation de la liaison de la compétence*

Les conséquences d'une annulation, et par conséquent la liaison de la compétence, doivent être déterminées compte tenu des circonstances de droit ou de fait prévalant à la date à laquelle le juge statue. Le Conseil d'Etat a clairement formulé ce principe dans les affaires *Leveau* et *Bourezak* en précisant que, lorsqu'il est saisi de conclusions présentées sur le fondement de l'art. 6-1 de la loi du 16 juill. 1980, il lui appartient d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de la décision (65).

Une telle solution paraît logique : l'acte lié est un acte déclaratif de droit ou d'obligation de l'Administration et il n'existe pas s'il n'y a plus de droit ou d'obligation à déclarer. Or, la légalité d'un acte administratif s'apprécie au moment de son adoption et l'illégalité de cet acte peut impliquer au moment où il est édicté un acte lié qui ne s'impose plus au moment du jugement. L'affaire *Leveau* en offre un exemple caractéristique. A la date de la décision attaquée, M. Leveau, conseiller municipal minoritaire, avait droit à voir satisfaite sa demande de mise à disposition de son groupe d'un local, conformément à l'art. L. 318-3 c. communes, et

l'annulation de la décision du maire le lui refusant impliquait nécessairement qu'il soit enjoint au maire de mettre un local à disposition du groupe. Mais l'instruction révéla que, à la suite des élections municipales qui se sont tenues le 18 juin 1995, le groupe Action et Progrès auquel appartenait M. Leveau avait cessé d'appartenir à la minorité du conseil municipal. Le Conseil en a déduit « que, en raison de ce changement dans les circonstances de fait, l'annulation de la décision du maire n'implique plus nécessairement la prise d'une décision dans un sens déterminé » et « que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au maire de Garges-lès-Gonesse d'affecter un local au groupe Action et Progrès ne sont pas susceptibles d'être accueillies » (66).

Mais la jurisprudence se devrait d'être plus nuancée : « Bien que la jurisprudence en ce sens soit constante et qu'elle s'appuie sur de solides arguments tirés du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, elle peut conduire à des résultats choquants. A la suite de l'annulation d'un refus de visa sollicité pour un mineur au titre du regroupement familial, l'Administration pourrait prendre une nouvelle décision de refus en constatant simplement que l'étranger, qui était mineur à la date du refus illégal, est devenu majeur entre-temps, c'est-à-dire pendant le délai de jugement, et qu'il n'a plus droit au regroupement familial » (67).

La jurisprudence, selon laquelle la liaison de la compétence s'apprécie au jour du jugement, devrait prendre en compte les droits acquis : « Plus généralement, dans tous les cas où la décision illégalement refusée aurait créé des droits en faveur de ses destinataires si la demande avait été accueillie, il n'est guère satisfaisant d'admettre que, à la suite de l'annulation, l'Administration pourra fonder un nouveau refus sur une évolution des circonstances de droit ou de fait, notamment sur une modification des dispositions réglementaires ou législatives applicables » (68). Déjà la jurisprudence prend en compte les droits acquis des fonctionnaires à la suite de l'annulation d'une mesure de révocation. Dans une telle hypothèse, il y a toujours lieu pour l'Administration de prendre une décision réintégrant l'intéressé dans ses fonctions à la date de son éviction, puis de reconstituer sa carrière.

L'octroi au juge administratif d'un pouvoir d'injonction améliore la protection des droits des administrés et permet d'achever la construction de la théorie du pouvoir discrétionnaire et de la compétence liée en mettant directement au jour le dualisme des actes exercice d'un pouvoir discrétionnaire et des actes liés.

Permettant de consacrer des droits des administrés ou des obligations, le pouvoir d'injonction donne au recours pour excès de < pouvoir > un aspect subjectif. « On comprend que, quant à la demande d'injonction, le juge se prononce dans un contentieux de pleine juridiction » (69).

Ira-t-on plus loin et permettra-t-on un jour au juge administratif de se substituer à l'Administration ?

La théorie de la compétence liée y inclinerait. « Une partie de la doctrine a toujours souhaité voir reconnaître au juge administratif la possibilité de prendre une décision à la place de l'administrateur, dans un seul cas précis, celui de la compétence liée. Hauriou et Jèze ont défendu cette solution en limitant il est vrai son domaine d'application aux hypothèses où l'Administration doit juridiquement prendre une décision positive, par exemple en accordant une autorisation. En déclarant qu'en pareil cas, d'une part, le silence gardé par

l'Administration équivaut non à une décision de rejet mais à une acceptation, d'autre part, l'annulation par le juge équivaut à une annulation de droit, on remédierait aux conséquences les plus néfastes de la carence administrative. L'Administration, en cas de compétence liée, n'a aucun pouvoir d'appréciation ; ce n'est donc pas porter atteinte à son indépendance que de permettre au juge d'accomplir l'acte obligatoire à sa place » (70).

# SEANCE N° 10 :
# LA REPARTITION DES COMPETENCES JURIDICTIONNELLES

Liste des documents :

- Document n° 1 : Conseil Constitutionnel, décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
- Document n° 2 : TC, 17 juin 2013, *Bergoend c/ ERDF,* n° C3911
- Document n° 3 : TC, 9 décembre 2013, *M. et Mme Panizzon*, n° 3931.
- Document n° 4 : Article 13 de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
- Document n° 5 : TC, 17 octobre 2011, *SCEA Chéneau*, n° C3828

Exercice : Cas pratique

*

## Document n° 1 : Conseil Constitutionnel, décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence

(…) *Sur le transfert à la juridiction judiciaire du contrôle des décisions du Conseil de la concurrence* :
15. Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle ; que, néanmoins, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ;
16. Considérant cependant que, dans la mise en œuvre de ce principe, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction

judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé ;
17. Considérant que, si le conseil de la concurrence, organisme administratif, est appelé à jouer un rôle important dans l'application de certaines règles relatives au droit de la concurrence, il n'en demeure pas moins que le juge pénal participe également à la répression des pratiques anticoncurrentielles sans préjudice de celle d'autres infractions intéressant le droit de la concurrence ; qu'à des titres divers le juge civil ou commercial est appelé à connaître d'actions en responsabilité ou en nullité fondées sur le droit de la concurrence ; que la loi présentement examinée tend à unifier sous l'autorité de la cour de cassation l'ensemble de ce contentieux spécifique et ainsi à éviter ou à supprimer des divergences qui pourraient apparaître dans l'application et dans l'interprétation du droit de la concurrence ;
18. Considérant dès lors que cet aménagement précis et limité des règles de compétence juridictionnelle, justifié par les nécessités d'une bonne administration de la justice, ne méconnaît pas le principe fondamental ci-dessus analysé tel qu'il est reconnu par les lois de la République (…)

## **Document n° 2 : TC, 17 juin 2013, *Bergoend c/ ERDF***

Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 février 2013, l'expédition de l'arrêt du 6 février 2013 par lequel la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par M. A...B...contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2011 par la cour d'appel de Chambéry dans le litige l'opposant à la société ERDF Annecy Léman, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 14 mars 2013, le mémoire présenté pour M. B...tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que le juge judiciaire est compétent pour ordonner le déplacement d'un poteau électrique implantée sans titre sur une propriété privée, même en l'absence de voie de fait, en application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, et que, en l'espèce, la société ERDF a commis une voie de fait, aucune prescription acquisitive n'étant applicable et lui-même n'ayant donné aucun accord en bonne et due forme à l'implantation litigieuse ;
Vu, enregistré le 18 mars 2013, le mémoire présenté pour la société ERDF Annecy Léman tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, aucune voie de fait ne pouvant être caractérisée, faute pour les propriétaires successifs du terrain d'implantation d'avoir jamais contesté l'implantation de l'ouvrage public litigieux ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 66 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et, notamment, son article 12 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 (…)

Considérant que M. B...est devenu propriétaire le 15 juin 1990 d'une parcelle sur laquelle Electricité de France, aux droits de laquelle vient la société ERDF Annecy Léman, avait implanté un poteau en 1983, sans se conformer à la procédure prévue par le décret du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946, ni conclure une convention avec le propriétaire du terrain ; que, par acte du 24 août 2009, il a fait assigner la société ERDF devant le tribunal de grande instance de Bonneville, afin que soit ordonné le déplacement du poteau litigieux, sous astreinte, aux frais de la société ; que, par un jugement du 21 janvier 2011, le tribunal de grande instance a décliné sa compétence ; qu'en appel, la cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 6 octobre 2011, a également jugé que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître du litige engagé par M.B... ; que, saisie par l'intéressé d'un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration ;

Considérant qu'un poteau électrique, qui est directement affecté au service public de la distribution d'électricité dont la société ERDF est chargée, a le caractère d'un ouvrage public ; que des conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression d'un tel ouvrage relèvent par nature de la compétence du juge administratif, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; que l'implantation, même sans titre, d'un tel ouvrage public de distribution d'électricité, qui, ainsi qu'il a été dit, ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public, n'aboutit pas, en outre, à l'extinction d'un droit de propriété ; que, dès lors, elle ne saurait être qualifiée de voie de fait ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement du poteau électrique irrégulièrement implanté sur le terrain de M. B...relèvent de la juridiction administrative ;

D E C I D E :
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. B... à la société ERDF Annecy Léman.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution

## **Document n° 3 : TC, 9 décembre 2013, *M. et Mme Panizzon*, n° 3931.**

Vu l'expédition du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. et Mme X... d'une demande de condamnation de la commune de Saint-Palais-sur-Mer à réparer le préjudice

résultant de l'occupation, par cette collectivité, d'une parcelle leur appartenant, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 19 mai 2010 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande de M. et Mme X... ;
Vu le mémoire présenté pour la commune de Saint-Palais-sur-Mer qui fait valoir qu'en l'absence d'identité de litige, le Tribunal n'est pas régulièrement saisi ;
Vu le nouveau mémoire par lequel la commune de Saint-Palais-sur-Mer fait état d'un protocole transactionnel conclu avec M. et Mme X... ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Odent-Poulet pour la commune de Saint-Palais-sur-Mer,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Batut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention conclue le 16 décembre 2002, M. et Mme X... ont mis à disposition de la commune de Saint-Palais-sur-Mer une parcelle de terrain leur appartenant, pour une durée de quatre ans, afin de lui permettre d'y aménager une aire de sport ; que la commune s'est cependant maintenue dans les lieux après l'expiration de cette convention ; que, par délibérations de son conseil municipal des 15 mai 2008 et 28 janvier 2009, la commune a entendu prolonger la convention initiale, ce que M. et Mme X... n'ont pas accepté ; que ces derniers ont assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Saintes, en invoquant l'existence d'une voie de fait, en vue d'obtenir l'expulsion de la commune ainsi que l'indemnisation de leur préjudice ; que, par une ordonnance du 19 mai 2010, le juge de la mise en état de ce tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune au profit de la juridiction administrative ; que les requérants ont alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de Saint-Palais-sur-Mer avait rejeté leur demande de restitution de leur terrain, à ce qu'il soit enjoint à la commune de le leur restituer sous astreinte, ainsi qu'à la condamnation de cette collectivité à réparer le préjudice résultant de l'occupation illégale de leur terrain ; que, si le tribunal administratif a fait droit à leurs conclusions sur les deux premiers points, il a, sur le troisième, estimé être en présence d'une emprise irrégulière et en a déduit que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice correspondant relevaient de la compétence de l'autorité judiciaire ;

Sur la saisine du Tribunal des conflits :

Considérant, d'une part, que, devant le tribunal de grande instance comme devant le tribunal administratif, M. et Mme X... demandaient une indemnité en réparation du préjudice qu'ils imputent à l'occupation illégale

de leur terrain ; qu'ainsi, les deux juridictions ont été saisies du même litige, alors même que les requérants ont saisi la première en invoquant une voie de fait, tandis que la seconde a retenu l'existence d'une emprise irrégulière ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Palais-sur-Mer, le tribunal administratif a régulièrement renvoyé au Tribunal des conflits, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant, d'autre part, que si la commune a ultérieurement produit un protocole transactionnel conclu avec M. et Mme X... et si les parties s'y engagent à se désister sous la condition du versement du prix de vente de la parcelle en cause, aucun acte par lequel les requérants se seraient désistés purement et simplement de leur demande présentée au tribunal administratif de Poitiers n'a été produit devant le Tribunal des conflits ; que, dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur la question de compétence renvoyée par le tribunal administratif ;

Sur la compétence :

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; que cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ;

Considérant que, si l'occupation de la parcelle de terrain appartenant à M. et Mme X... par la commune de Saint-Palais-sur-Mer a porté atteinte au libre exercice de leur droit de propriété sur ce bien, elle n'a pas eu pour effet de les en déposséder définitivement ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif, compétent pour se prononcer sur la décision du maire refusant de libérer cette parcelle et pour enjoindre à la commune d'y procéder, l'est également pour statuer sur leurs conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de cette occupation irrégulière ;

D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions de M. et Mme X... tendant à la réparation du préjudice résultant de l'occupation, par la commune de Saint-Palais-sur-Mer, d'une parcelle leur appartenant.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 juin 2013 est déclaré nul et non avenu, en tant qu'il concerne les conclusions mentionnées à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

## **Document n° 4 : Article 13 de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.**

I.-La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'Etat est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;
2° Le titre IV est abrogé, à l'exception de l'article 25, qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur du présent I
3° Les articles 1er à 16 sont ainsi rétablis :

« Art. 1.-Les conflits d'attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

« Art. 2.-Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :
« 1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« 2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;
« 3° Deux suppléants élus, l'un par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l'autre par l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.
« Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu'à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.

« Art. 3.-Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.
« En cas d'empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.
« En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. 4.-Deux membres du Conseil d'Etat, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.
« Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

« Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

« Art. 5.-Sous réserve de l'article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.

« Art. 6.-Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n'ont pu se départager, l'affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2, de deux conseillers d'Etat en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus, dans les conditions définies aux mêmes 1° et 2°, lors de l'élection des membres de la formation ordinaire.
« Les règles de suppléance sont applicables.
« Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

« Art. 7.-Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.

« Art. 8.-Le délibéré des juges est secret.

« Art. 9.-Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.
« Elles sont rendues en audience publique.

« Art. 10.-Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s'impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l'autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d'ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 11.-Les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

« Art. 12.-Le Tribunal des conflits règle le conflit d'attribution entre les deux ordres de juridiction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Lorsque le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité a élevé le conflit dans le cas prévu à l'article 13 ;
« 2° Lorsque les juridictions de l'un et l'autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître d'un litige ayant le même objet ;
« 3° Lorsqu'une juridiction de l'un ou l'autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.

« Art. 13.-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d'un litige ou d'une question préjudicielle portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

« Art. 14.-Le conflit d'attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.
« Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l'action civile dans les cas mentionnés à l'article 136 du code de procédure pénale.

« Art. 15.-Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.
« Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l'égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

« Art. 16.-Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. »

II.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président ».
III.-1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
2. Les modalités de désignation prévues à l'article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.
Jusqu'à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l'article 25 de ladite loi.
3. Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.
Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l'article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.
IV.-Sont abrogées :
1° L'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ;
2° L'ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d'Etat et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits, à l'exception des appels comme d'abus, des mises en jugement des fonctionnaires, et des autorisations de plaider demandées par les communes et établissements publics, et qui crée un ministère public au sein du comité de justice administrative ;
3° La loi du 4 février 1850 portant sur l'organisation du Tribunal des conflits ;

4° La loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.

## **Document n° 5 : TC, 17 octobre 2011, *SCEA Chéneau*, n° C3828**

(…) Considérant que les dispositions de l'article 55 de la Constitution conférant aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois ne prescrivent ni n'impliquent aucune dérogation aux principes, rappelés ci-dessus, régissant la répartition des compétences entre ces juridictions, lorsque est en cause la légalité d'une disposition réglementaire, alors même que la contestation porterait sur la compatibilité d'une telle disposition avec les engagements internationaux ;
Considérant toutefois, d'une part, que ces principes doivent être conciliés tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable ; qu'il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ;
Considérant, d'autre part, que, s'agissant du cas particulier du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne ;
Considérant que, si la contestation soulevée par la SCEA du Chéneau et autres et par M. Cherel et autres met nécessairement en cause la légalité des actes administratifs qui ont rendu obligatoires les cotisations litigieuses, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire, compétemment saisie du litige au principal, de se prononcer elle-même, le cas échéant après renvoi à la Cour de justice, sur un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne ; que c'est dès lors à tort que le conflit a été élevé (…)

**CAS PRATIQUE**

M. Dupond est propriétaire d'un petit terrain en friche près de Bormes-les-Mimosas depuis plus de 20 ans, terrain qu'il n'a pas vraiment l'habitude de visiter (ni d'exploiter d'ailleurs). En vacances dans le sud, il se rend compte avec stupéfaction qu'une ligne électrique est en cours d'édification par ERDF et que deux « *immondes poteaux* » ont déjà été implantés sur sa parcelle. M. Dupond, qui n'a jamais été informé de cette décision d'implantation et n'a signé aucune convention, estime qu'il ne pourra « *plus vendre son bien au même prix qu'avant* », même s'il concède qu'il n'est pas totalement dépossédé de son droit de propriété…

Pourtant, selon ses dires, cette décision est une « *emprise irrégulière* », voire une « *véritable voie de fait administrative* », qui viole son droit « *sacré* » de propriété. Il compte donc « *saisir la justice* » afin de faire cesser cette « *occupation irrégulière de son terrain* » et qu'ERDF lui répare le préjudice subi.

Mme Duchamp est une ministre en colère. Elle a pris un arrêté réglementaire (sur habilitation du 1er ministre) le 14 janvier dernier qui rendait des cotisations professionnelles obligatoires, en contradiction évidente il est vrai avec plusieurs normes du droit de l'Union européenne. Le juge judiciaire, saisi d'un contentieux entre personnes privées et visant au remboursement de ces cotisations, s'est permis d'apprécier lui-même – mais de manière incidente – la régularité de son arrêté. Si elle ne conteste pas la nature privée du litige principal, Mme Duchamp fulmine : on lui avait en effet appris en deuxième année de droit que le juge judiciaire n'avait « *en aucun cas le droit d'apprécier la légalité d'un arrêté* »…

**Question n° 1** : L'occupation du terrain de M. Dupond est-elle constitutive d'une voie de fait ou d'une « simple » emprise irrégulière ? Quel ordre de juridiction est en conséquence compétent pour *faire cesser* cette situation et pour en *faire réparer* les conséquences ?

**Question n° 2** : Le juge judiciaire avait-il le droit d'apprécier la régularité de l'arrêté ministériel ?